



สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง
กรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ศาลยุติธรรม
และคำวินิจฉัยตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง
พฤษภาคม ๒๕๕๐

**สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง
กรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา :
ศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ศาลยุติธรรม
และคำวินิจฉัยตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุด**

**สำนักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง
พฤษภาคม ๒๕๕๐**

คำนำ

โดยที่ในปัจจุบัน หน่วยงานทางปกครองมีการทำสัญญาว่าจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยงานทางปกครองมักต้องประสบกับปัญหาขัดข้องในลักษณะต่างๆ จากกรณีที่เอกชนคู่สัญญาจำนวนไม่น้อยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น ไม่เริ่มเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด ส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่เข้าแก้ไขงานที่มีความชำรุดบกพร่องตามข้อกำหนดในสัญญา เป็นต้น ซึ่งในทุกกรณีย่อมก่อให้เกิดความเสียหายไม่เฉพาะแก่หน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น แต่ย่อมมีผลกระทบต่อถึงประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการสาธารณะ รวมตลอดไปถึงประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

จากสภาพการณ์ดังกล่าว จึงเป็นการสมควรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้กระทำการแทนหน่วยงานทางปกครองต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สิทธิเรียกร้องอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเกิดขึ้น รวมทั้งมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองในฐานะคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างเพื่อให้การปฏิบัติตามสัญญาบรรลุผลสมตามเจตนารมณ์ของสัญญา และโดยที่ในปัจจุบันสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งต่างๆ ในลักษณะข้างต้นนั้น ส่วนใหญ่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง อันมีผลทำให้เกิดคิฟิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครองกรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและผลทางกฎหมายของสัญญาทั้งตามแนวคิดของต่างประเทศและของไทย รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในกรณีต่างๆ ตามที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และของศาลฎีกา รวมทั้งของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้มีการให้ความเห็นในการตอบข้อหารือแก่หน่วยงานทางปกครองต่างๆ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาจ้างของทางราชการได้ในระดับหนึ่ง

(นางสาวพรทิพย์ ทองดี)

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สารบัญ

บทนำ	หน้า
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการปฏิบัติ ตามสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายปกครองของ ต่างประเทศและของไทย	๑ ๕
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๕
๒. แนวคิดของฝรั่งเศสเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและผลของ สัญญาทางปกครอง	๗
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามทฤษฎีบริการ สาธารณะ	๗
๒.๑.๑ หลักความต่อเนื่อง	๗
๒.๑.๒ หลักการปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่าง สม่ำเสมอ	๘
๒.๑.๓ หลักความเสมอภาคในการบริการสาธารณะ	๘
๒.๒ ผลของสัญญาทางปกครอง	๘
๒.๒.๑ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง	๙
๒.๒.๒ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน	๑๓
๒.๓ การสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง	๑๗
๓. แนวคิดของเยอรมันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและผลของ สัญญาทางปกครอง	๑๘
๓.๑ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖	๑๘
๓.๑.๑ ประเภทของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองของ เยอรมัน	๒๐
๓.๑.๒ ประเภทของสัญญาทางปกครองของเยอรมัน	๒๐
๓.๒ ผลของสัญญาทางปกครอง	๒๓
๓.๒.๑ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา	๒๓
๓.๒.๒ การสิ้นสุดของสัญญา	๒๗
๔. แนวคิดของไทยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและผลทาง กฎหมายของสัญญาทางปกครอง	๓๒

	หน้า
บทที่ ๓. คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของ หน่วยงานทางปกครองกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา	๑๑๖
กรณีที่เป็นสิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง	๑๑๗
๑. สิทธิเรียกค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า โดยผู้ว่าจ้าง มิได้บอกเลิกสัญญา	๑๑๗
๒. สิทธิในเรื่องต่างๆ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	๑๒๑
๓. สิทธิไม่จ่ายค่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง	๑๓๐
๔. สิทธิเรียกค่าเสียหายกรณีทีมงานซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบเกิดความ ชำรุดบกพร่อง	๑๓๐
๕. สิทธิสั่งลงโทษผู้รับจ้างให้เป็นผู้ทำงาน	๑๓๑
กรณีที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครอง	๑๓๔
๑. กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเดิมภายหลังจาก ที่สัญญาสิ้นสุดแล้วจะถือวันสิ้นสุดอายุสัญญาตามวัน สิ้นสุดสัญญาเดิมไม่ได้	๑๓๔
๒. กรณีที่ความล่าช้าในการส่งมอบงานเกิดจากปัญหา การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง	๑๓๖
บทที่ ๔. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	๑๔๓
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
- ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙	(ก)
- ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘	(ก)
- ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองกลาง พ.ศ. ๒๕๔๙	(ก)
- ดัชนีคำพิพากษาศาลฎีกา	(ข) - (ง)
- ดัชนีคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด	(จ) - (ฉ)

บทนำ

สัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองและมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชน หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “สัญญากับทางราชการ” อาจจัดเป็นสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนดหรือสัญญาทางปกครองโดยสภาพก็ได้ ลักษณะของสัญญาทางปกครองทั้งสองประเภทดังกล่าวปรากฏอยู่ในมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ ที่ว่า “...สัญญาใดจะเป็นสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นั้น ประการแรก จะต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐ ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือ เข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล...”

จากมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์สำคัญเบื้องต้นในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนดและสัญญาทางปกครองโดยสภาพ ก็คือ **หลักเกณฑ์ด้านคู่สัญญา** กล่าวคือ จะต้อง มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ประการอื่นๆ ประกอบด้วย กล่าวคือ หากเป็นสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนด จะต้องเป็นสัญญาประเภทที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนให้เป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้กำหนดไว้ ๔ ประเภทสัญญา คือ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ จะต้องพิจารณาที่ **หลักเกณฑ์ด้านวัตถุประสงค์แห่งสัญญา** โดยต้องเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง หรือ **หลักเกณฑ์ด้านข้อกำหนดในสัญญา** โดยต้องเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ หากสัญญานั้นๆ มีหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียวจากสองหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็เพียงพอที่จะเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพได้แล้ว

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ ที่จัดทำระหว่างหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างและเอกชนผู้รับจ้างเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอันเป็นสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนดตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อาทิ สัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑๔/๒๕๔๕) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาล (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๕๔/๒๕๔๗) สัญญาจ้างก่อสร้างทางพิเศษ

(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙/๒๕๕๖) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือที่ทำการของหน่วยงานทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๔๓/๒๕๕๕ ที่ ๒๕/๒๕๕๘ ที่ ๑๑๕/๒๕๕๘ และที่ ๑๙๙/๒๕๕๘ ฯลฯ) สัญญาจ้างก่อสร้างหอบังคับการบิน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๘/๒๕๕๘) สัญญาจ้างวางหรือขยายระบบประปาหรือระบบระบายน้ำเสีย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๕๖/๒๕๕๖ ที่ ๔๐๒/๒๕๕๖ ที่ ๔๔๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๑๙/๒๕๕๗ ฯลฯ) ส่วนสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ อาทิ สัญญาจ้างก่อสร้างหลักเทียบเรือของกองทัพเรือ (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๒๑/๒๕๕๖) สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS/DME พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ระบบไฟฟ้าสำรอง เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและ UPS (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๔๘/๒๕๕๗) สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๔/๒๕๕๔) สัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๑๓/๒๕๕๖) สัญญาจ้างก่อสร้างเรือตรวจการณ์ปืน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๙๒/๒๕๕๖) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างฉบับหนึ่งๆ อาจเป็นได้ทั้งสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนดและสัญญาทางปกครองโดยสภาพในฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของสัญญาซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป อาทิ สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล (คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ ๑๐/๒๕๕๕) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๕๕/๒๕๕๖) สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกิจการประปา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๙/๒๕๕๗) สัญญาจ้างเหมามาخذสระน้ำ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙๙/๒๕๕๙) เป็นต้น แต่ไม่ว่าสัญญาจ้างก่อสร้างนั้นๆ จะเข้าลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนดหรือเป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพก็ตาม คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาเหล่านี้ก็ล้วนอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งสิ้น

ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการต่างๆ ของภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดทำระหว่างหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างและเอกชนผู้รับจ้างมีสาเหตุมาจากเอกชนผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการก่อสร้างล่าช้า หรือไม่เข้าทำงานหรือทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาในที่สุด ผลกระทบที่ตามมาก็คือ นอกจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องหยุดชะงักหรือชะลอการก่อสร้างออกไปแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างยังต้องเริ่มต้นดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนและอาจต้องเสียค่าจ้างมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้ทางราชการต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างของทางราชการโดยส่วนมากมักเป็นโครงการขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของภาคเอกชนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ทำให้ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก และไม่สามารถปล่อยให้หยุดชะงักเป็นเวลานานได้เพราะจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ เอกสารทางวิชาการฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ “สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างในกรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา” ด้วยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ กล่าวคือ *ประการแรก* สัญญาจ้างก่อสร้างของทางราชการโดยทั่วไปเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นตาม

แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะมีข้อความที่ให้อำนาจหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเข้าควบคุมเอกชนผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา และลงโทษเอกชนผู้รับจ้างด้วยการเรียกค่าปรับเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาเมื่อเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญา อาทิ เมื่อเอกชนผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือลงโทษเอกชนผู้รับจ้างด้วยการเรียกค่าเสียหายเมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนในราคาที่สูงขึ้น หรือลงโทษด้วยการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวเมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่เอกชนผู้รับจ้างจะทำงานให้แล้วเสร็จ เป็นต้น การที่สัญญาจ้างก่อสร้างของทางราชการมีข้อสัญญาที่เอื้อให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถควบคุมและลงโทษเอกชนผู้รับจ้างดังได้กล่าวมาแล้ว ย่อมเป็นเครื่องช่วยป้องกันมิให้ส่วนราชการต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและยังช่วยจำกัดขอบเขตปัญหาพิพาทระหว่างกันได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะขยายตัวรุนแรงจนถึงขั้นต้องนำคดีมาสู่ศาล แต่ข้อสัญญาเหล่านี้จะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดเป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเพื่อให้ได้รับผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาในสัญญา ซึ่งย่อมหมายความว่า หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต้องเข้ากำกับและควบคุมเอกชนผู้รับจ้างให้เคารพและปฏิบัติตามสัญญานับตั้งแต่เมื่อมีการลงนามในสัญญาจนถึงขั้นตอนการตรวจรับมอบงานและชำระค่าจ้าง รวมทั้งมีการลงโทษเมื่อเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา และประการที่สองในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลเมื่อเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้สิทธิหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีต่างๆ เพื่อให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งบางเรื่องก็มีความยุ่งยากซับซ้อนจนทำให้บางครั้งหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างอาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในกฎหมายและระเบียบดังกล่าว หรืออาจใช้สิทธิเรียกร้องไม่ถูกต้องเพราะอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องอย่างไรและเรียกร้องอะไรได้บ้าง ทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยชน์ที่ควรได้รับตามสิทธิที่มีอยู่ ดังตัวอย่างเช่น เรื่องการแจ้งสงวนสิทธิปรับตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อ ๑๓๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับในเวลาที่มีการชำระหนี้ กรณีนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติว่า เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาและส่งมอบงานล่าช้า หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างควรต้องแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเมื่อใดจึงจะมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาแม้จะมีการขยายระยะเวลาออกไปแล้วก็ตาม เมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องบอกเลิกสัญญาจ้างในที่สุดนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างควรต้องแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเมื่อใดจึงจะสามารถเรียกค่าปรับได้ หรือผลในทางกฎหมายจะเป็นเช่นใด หากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิได้แจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ก่อน เป็นต้น จากสภาพปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกค่าปรับดังกล่าวมานี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาและข้อกำหนดกฎหมายด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบบกพร่องของงาน

ที่ได้ส่งมอบไปแล้ว ผู้ว่าจ้างก็ต้องทราบด้วยว่าจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ถูกต้องอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปในสัญญาจ้างของทางราชการจะมีข้อสัญญากำหนดเรื่องความรับผิดชอบการประกันผลงานไว้เสมอ เพราะสัญญาของทางราชการโดยส่วนใหญ่เป็นสัญญาสำเร็จรูปตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งยังมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ว่าจ้างในเรื่องดังกล่าวไว้ตามมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ออกส่งมอบ หรือในบางครั้งสัญญาอาจตกลงกันให้ระยะเวลาเพื่อความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องนานกว่า ๑ ปี ก็ได้ โดยอาจเป็น ๒ ปี หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ตามแต่จะตกลงกัน เพียงแต่เมื่อปรากฏความชำรุดบกพร่องขึ้นภายหลังจากวันที่ได้รับมอบงานแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เอกชนผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดนับแต่วันส่งมอบงาน หากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้เอกชนผู้รับจ้างเข้าแก้ไขงานหรือชดเชยค่าเสียหายภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ปล่อยปละละเลยจนล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างย่อมไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ จากผู้รับจ้าง ได้อีก กรณีดังกล่าวก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทางราชการต้องเสียประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างที่มีได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้เอกชนผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างของทางราชการดังที่กล่าวมาข้างต้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาและผลของสัญญาทางปกครองจากงานเขียนของนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนรวมทั้งได้ศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆ ของผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตลอดจนแบบสัญญาจ้างแบบท้ายระเบียบดังกล่าว ควบคู่กับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับคดีพิพาทประเภทดังกล่าว แต่ด้วยเหตุที่ศาลปกครองเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ดำเนินงานมาเพียง ๖ ปีเศษเท่านั้น ทำให้มีปริมาณคำวินิจฉัยของศาลปกครองในขณะที่ทำการศึกษานี้เพื่อนำมาใช้ประกอบในรายงานฉบับนี้ยังมีจำนวนน้อย กล่าวคือ มีจำนวนคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาตามที่ปรากฏในระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙ (ครึ่งปีแรก) จำนวน ๑๒ คดี และคำพิพากษาศาลปกครองกลางตามที่ปรากฏในปี ๒๕๔๙ จำนวน ๖ คดี ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น จึงได้ศึกษาแนวคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องจากคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ค้นคว้าได้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๕ และคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดในการตอบข้อหารือให้กับหน่วยงานทางปกครองต่างๆ ที่ปรากฏในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๙ เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางปกครองในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาสหสิทธิประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษาเช่นเดียวกัน

บทที่ ๑

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครอง ในระบบกฎหมายปกครองของต่างประเทศและของไทย

๑. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาอาจแบ่งออกได้เป็นสองระบบ ได้แก่

- ระบบสัญญาตามกฎหมายเอกชน ซึ่งหมายถึง สัญญาทางแพ่ง และ
- ระบบสัญญาตามกฎหมายมหาชน ซึ่งหมายถึง สัญญาทางปกครอง

สำหรับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common law) มิได้มีการแบ่งแยกระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมายมหาชนออกจากกันอย่างชัดเจน เพราะยึดแนวคิดว่าคุณคนทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายปกครองต่างอยู่ภายใต้บังคับของระบบกฎหมายเอกชนอย่างเท่าเทียมกันและข้อพิพาทต่าง ๆ ล้วนอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียว ดังนั้น สัญญาต่าง ๆ ที่จัดทำระหว่างเอกชนด้วยกันหรือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานราชการ ย่อมเป็นสัญญาธรรมดาที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชนทั้งสิ้น

แต่ในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย เช่น ฝรั่งเศส ซึ่งมีการพัฒนาระบบกฎหมายมหาชนแยกจากระบบกฎหมายเอกชนอย่างชัดเจน ได้แบ่งแยกสัญญาที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายทั้งสองระบบนี้ออกจากกันเป็นสัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพ่งตามลำดับ โดยฝ่ายปกครองสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อจัดทำสัญญาภายใต้ระบบกฎหมายทั้งสองระบบดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสัญญา^๑ ว่าจะมีความมุ่งหมายประการใด ในกรณีที่ฝ่ายปกครองเข้าผูกพันนิติสัมพันธ์กับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในสัญญาทางแพ่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครอง”^๒ ที่มีวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ยังไม่ถึงขนาด

^๑ นักวิชาการทางกฎหมายมหาชนของไทยบางท่าน เช่น ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ใช้ว่า “วัตถุประสงค์ของสัญญา” โดยอธิบายว่าเป็นหน้าที่คู่สัญญาต้องชำระตอบแทนกันเหมือนในสัญญาทางแพ่ง (โปรดอ่านใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๕ (๒๕๒๙), หน้า ๘๕.)

^๒ รองศาสตราจารย์ ดร. โภคิน พลกุล ใช้ว่า “สัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครอง” ส่วนนักกฎหมายท่านอื่นๆ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ใช้ว่า “สัญญาของฝ่ายปกครอง” หรือ “สัญญาของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเอกชน” (โปรดอ่านใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๖, หน้า ๒๙๘.) ในขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ใช้คำว่า “สัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครองที่ใช้กฎหมายเอกชนบังคับ” โดยอธิบายว่า สัญญาของฝ่ายปกครองมีสองประเภท คือ สัญญาทางปกครองที่ใช้กฎหมายมหาชนบังคับและสัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครองที่ใช้กฎหมายเอกชนบังคับ เพราะฝ่ายปกครองทำสัญญาแบบหลังเช่นเดียวกับที่เอกชนทำ (โปรดอ่านใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๘๗.)

เป็นการมอบอำนาจให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจัดทำหรือเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง เช่น สัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น สภาพบังคับของสัญญาทางแพ่ง^๓ จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาซึ่งแตกต่างจากสภาพบังคับตามสัญญาทางปกครองและต้องอยู่ภายใต้บังคับของระบบกฎหมายเอกชน ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพ่งจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนในกรณีที่ฝ่ายปกครองเข้าผูกนิติสัมพันธ์ในสัญญาทางปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ สภาพบังคับของสัญญาทางปกครองจะต้องมุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายปกครอง มิใช่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเอกชนทั้งหมดดังเช่นสัญญาทางแพ่ง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

อนึ่ง ด้วยเหตุที่สัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงมีลักษณะพิเศษบางประการที่มีได้เป็นไปตามหลักของสัญญาทางแพ่ง ดังนี้

(๑) ฝ่ายปกครองไม่มีเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา เพราะต้องเลือกคู่สัญญาโดยใช้วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วิธีประกวดราคาหรือวิธีสอบราคา เป็นต้น

(๒) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มีสิทธิร่วมกำหนดข้อสัญญาตามหลักความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา เพราะสัญญาทางปกครองโดยส่วนใหญ่เป็นสัญญาสำเร็จรูป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สัญญาแบบ” (contrats types) ที่มีการกำหนดรายละเอียดของข้อสัญญา ไว้ก่อนแล้ว

(๓) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถนำหลักสัญญาต่างตอบแทนมาใช้กับสัญญาทางปกครองในกรณีที่ฝ่ายปกครองกระทำผิดสัญญา เพราะหลักสัญญาต่างตอบแทนอาจส่งผลกระทบต่อที่เป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไปและใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายในภายหลัง (ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับหลักความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ)

(๔) ฝ่ายปกครองไม่ใช่หลักการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา (immutabilité du contrat) โดยต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เนื่องจากฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิ์ในการแก้ไขข้อสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายเอกชน หากการแก้ไขข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะ

จากหลักพิเศษต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจสรุปได้ว่ามีพื้นฐานอยู่บนการดำเนินบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีผู้ให้ข้อสังเกตว่า “หลักพิเศษดังกล่าวเป็นหลักที่มีผลบังคับโดยกฎหมายและอาจขัดแย้งโดยตรงกับข้อความในสัญญาและเจตนาของคู่สัญญาตั้งแต่แรก แต่เป็นหลักที่ศาลปกครองสร้าง

^๓ รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ อธิบายว่า การมีสภาพบังคับของสัญญาในระบบกฎหมายเอกชนจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา หากคู่สัญญามีได้แสดงความประสงค์ใดๆ ในสัญญาแล้ว สัญญานั้นก็จะขาดสภาพบังคับ (โปรดอ่านใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๖, หน้า ๒๙๗-๒๙๘.)

ขึ้นมาเพื่อผสมผสานประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนคู่สัญญาให้อยู่ในดุลยภาพที่เหมาะสม”^๔

เมื่อนิติสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในสัญญาทางปกครองอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชนดังได้กล่าวมาแล้วในตอนแรก สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจึงมีที่มาจากระบบกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกัน ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงไม่มีโอกาสต่อรองกับฝ่ายปกครองได้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในสัญญาทางแพ่งในเรื่องนี้นักกฎหมายชาวอังกฤษ ได้แก่ Brown และ Garner ให้ข้อสังเกตว่า “เรื่องการบังคับและปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองนี้เองที่กฎหมายปกครองฝรั่งเศสได้สร้างหลักพิเศษอันเกิดจากแนวความคิดที่จำเป็นต้องยอมรับความสำคัญสูงสุดของประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์สาธารณะต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใด แม้ว่าประโยชน์ดังกล่าวจะขัดกับความขัดแย้งแห่งสัญญา ทฤษฎีนี้เป็นหลักที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายและไม่ขึ้นอยู่กับการเจตนาของคู่กรณี”^๕

๒. แนวคิดของฝรั่งเศสเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและผลของสัญญาทางปกครอง

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามกฎหมายบริการสาธารณะ

ตามแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสได้วางเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นสัญญาทางปกครองไว้สองประการ คือ สัญญาทางปกครองโดยกฎหมายกำหนด และสัญญาทางปกครองโดยสภาพ ซึ่งสัญญาทางปกครองทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาทางแพ่งเฉพาะในส่วนที่เป็นการแสดงเจตนาร่วมกันของฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชน มิใช่ฝ่ายปกครองใช้อำนาจบังคับแต่เพียงฝ่ายเดียว สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสมีพื้นฐานมาจาก *ทฤษฎีบริการสาธารณะ* (Théorie de Service Public) เป็นสำคัญ ดังปรากฏในงานเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซึ่งสามารถสรุปหลักการสำคัญอันมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีดังกล่าว ได้ดังนี้

๒.๑.๑ หลักความต่อเนื่อง ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องจัดให้มีหรือจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประชาชนส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการบริการสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมด้วยความผาสุกและสงบเรียบร้อย ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถยุติการจัดทำบริการสาธารณะหรือไม่สามารถจัดทำได้โดยคุณภาพ ทั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใดๆ เนื่องจากความบกพร่องในการดำเนินการของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ในขณะที่ฝ่ายเอกชน (ซึ่งต่อไปใน

^๔ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๗๔-๗๕.

^๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๘๕.

^๖ โปรดอ่านรายละเอียดใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๘๕-๘๗.

เอกสารการศึกษานี้จะเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายเอกชน”) ในฐานะคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองด้วยการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคที่รุนแรงมากเพียงใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติตามสัญญานั้นจะเป็นไปไม่ได้เพราะมีเหตุสุดวิสัย (force majeure) ซึ่งในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยความยากลำบาก หรือมีเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้น ฝ่ายปกครองจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายค่าทดแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย หรือแม้แต่ในกรณีที่ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็ไม่สามารถอ้างหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาต่างตอบแทนเพื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา (exceptio non adimpliti contractus) เพราะจะทำให้การบริการสาธารณะต้องหยุดชะงัก แต่สามารถเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายปกครองเป็นการชดเชยได้

๒.๑.๒ หลักการปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาการบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม ในขณะเดียวกันคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในสัญญาทางปกครองจะต้องยินยอมเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการบริการสาธารณะหากวัตถุประสงค์ของสัญญาทางปกครองนั้นๆ เป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะยืนยันการปฏิบัติตามข้อสัญญาเดิมไม่ได้ มิฉะนั้นฝ่ายปกครองสามารถใช้สิทธิแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียวหรือบอกเลิกสัญญาได้

๒.๑.๓ หลักความเสมอภาคในการบริการสาธารณะ หลักการนี้ถือว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิและหน้าที่อย่างเสมอภาคกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น สิทธิได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว

๒.๒ ผลของสัญญาทางปกครอง

ในระยะแรกของการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายมหาชน นักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสในยุคแรกๆ เช่น ศาสตราจารย์ Gaston Jèze เห็นว่า “สัญญาทางปกครองมิได้แตกต่างไปจากสัญญาในระบบกฎหมายเอกชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ในสัญญา”^๗ แต่ต่อมาเมื่อนักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจนมีความเข้มแข็งแล้ว กลับสะท้อนให้เห็นว่าสัญญาทางปกครองมีลักษณะที่แตกต่างจากสัญญาในระบบกฎหมายเอกชนหลายประการ ได้แก่

^๗ นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, อ่างแล้ว, หน้า ๒๙๙.

หลักเอกสิทธิ์^๔ ของฝ่ายปกครอง ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างฝ่ายปกครองและคู่สัญญา ฝ่ายเอกชน รวมทั้งผลของสัญญาทางปกครองก็มีได้คล้ายคลึงกับผลของสัญญาในระบบกฎหมายเอกชน เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในสัญญาทางปกครองย่อมต้องผูกพันตนว่า จะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดทำบริการสาธารณะ แต่จะต้องช่วยส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญา ที่มุ่งเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ เป็นต้น ด้วยสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสมีแนวคิดมาจาก ทฤษฎีบริการสาธารณะซึ่งมีหลักการสำคัญได้แก่ หลักความต่อเนื่อง หลักการปรับปรุงการ บริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ และหลักความเสมอภาคในการบริการสาธารณะ ดังนั้น การ ศึกษาเกี่ยวกับผลของสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสจึงอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีบริการ สาธารณะเป็นสำคัญ ซึ่งจากหลักการตามทฤษฎีดังกล่าวก่อให้เกิดผลอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ของคู่สัญญาทางปกครอง ดังนี้

๒.๒.๑ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง

๑) สิทธิของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง

ตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิของคู่สัญญาฝ่ายปกครองซึ่งสมควรกล่าวถึงนั้น ได้แก่เรื่องของ “เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง” โดยในเรื่องนี้ตามแนวคิดของระบบกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสยึดถือว่าฝ่ายปกครองมีอำนาจมหาชน อันเป็นเอกสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มีเอกสิทธิ์ดัง กล่าว และฝ่ายปกครองสามารถสงวนเอกสิทธิ์นั้นไว้ในขณะจัดทำสัญญาทางปกครองกับคู่ สัญญาฝ่ายเอกชนได้อันมีผลทำให้ในสัญญาทางปกครองอาจมีข้อสัญญาบางข้อที่แสดงถึงความ ไม่เท่าเทียมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปรากฏอยู่ โดยอาจเรียกข้อสัญญาดังกล่าวได้ว่า “ข้อสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงการมีเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน” เช่น ข้อสัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายปกครองบังคับคดีได้โดยไม่ต้องนำคดีมาสู่ศาล อาทิ การริบทรัพย์ออกขายทอดตลาด ฯลฯ และข้อสัญญาที่ให้ฝ่ายปกครองสามารถเลิกสัญญา ฝ่ายเดียวได้แม้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ได้กระทำความผิดสัญญา เป็นต้น ข้อสัญญาเหล่านี้เป็น

^๔ คำว่า “เอกสิทธิ์” นี้ นักกฎหมายมหาชนไทยใช้ถ้อยคำในงานเขียนทางวิชาการที่แตกต่างกัน เช่น ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ใช้คำว่า “สิทธิพิเศษ” “เอกสิทธิ์” และ “เอกสิทธิ์พิเศษ” ปะปนกัน (โปรดอ่านใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, สัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส, อ่างแล้ว, หน้า ๘๗-๘๙.) ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ใช้คำว่า “เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครอง” “อำนาจพิเศษ” “ข้อกำหนด ที่มีลักษณะพิเศษที่ให้สิทธิแก่ฝ่ายปกครองอย่างมาก” (โปรดอ่านใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปก ครอง, อ่างแล้ว, หน้า ๓๗๓.) ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร. โภคิน พลกุล ใช้คำว่า “เอกสิทธิ์” (โปรดอ่านใน โภคิน พลกุล, “สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย”, ใน นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, อ่างแล้ว, หน้า ๔๗๗.) สำหรับในเอกสารการศึกษานี้จะใช้คำว่า “เอกสิทธิ์” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

“ข้อสัญญาที่ไม่อาจพบเห็นได้ในสัญญาทางแพ่งและเป็นข้อสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองอย่างมาก” (une clause exorbitant du droit commun)^๔ ซึ่งหากข้อสัญญาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสัญญาทางแพ่งย่อมขัดต่อกฎหมายและมีผลทำให้สัญญาเป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม นอกจากฝ่ายปกครองจะกำหนดข้อสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอย่างมากแล้ว ฝ่ายปกครองยังมีเอกสิทธิ์ประการอื่นๆ ตามหลักกฎหมายปกครองที่อาจไม่ปรากฏในข้อสัญญาด้วย ได้แก่

(๑) อำนาจในการกำกับและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาอย่างใกล้ชิด เช่น ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ฝ่ายปกครองมีอำนาจเข้าไปควบคุมดูแลการทำงานของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยอาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานแทนก็ได้ หรือควบคุมการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง หรือการควบคุมดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการก่อสร้าง เป็นต้น

(๒) อำนาจในการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อรักษาความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ โดยฝ่ายปกครองมีอำนาจสั่งลงโทษคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเมื่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วยการเรียกให้ชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายตามแต่กรณี เช่น ไม่เข้าทำงานภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงานชำรุดบกพร่อง โอนงานไปให้บุคคลที่สามดำเนินการแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครอง เป็นต้น ตลอดจนฝ่ายปกครองสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและทิ้งงานไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

อย่างไรก็ตาม เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองที่จะบังคับเอากับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเมื่อมีการกระทำผิดสัญญาหรือปฏิบัติผิดไปจากข้อสัญญานั้น ไม่ได้มีเพียงอำนาจเรียกค่าเสียหายหรือตอบโต้ด้วยการไม่ชำระหนี้ที่ต้องชำระตอบแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเท่านั้น แต่ฝ่ายปกครองยังสามารถบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปฏิบัติตามสัญญาได้เองในเบื้องต้นโดยไม่ต้องนำคดีมาสู่ศาลตามหลักเอกสิทธิ์การบังคับฝ่ายเดียวไปก่อนโดยไม่ต้องไปศาล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริการสาธารณะ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม ใยมะประยูร ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้อำนาจบังคับของฝ่ายปกครองในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนผิดสัญญาว่า “ฝ่ายปกครองมีอำนาจในการดำเนินการที่ค่อนข้างกว้างขวางซึ่งได้แก่

(ก) สั่งให้มีการปรับ

(ข) สั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหาย

(ค) จัดหาบุคคลอื่นเข้ามาทำงานแทนโดยให้เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด อันเป็นมาตรการเฉพาะเรื่องและชั่วคราวซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกรณีที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลอย่างร้ายแรงเท่านั้น

^๔ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครอง และการกระทำทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, ๒๕๔๙, หน้า ๒๔๖.

(ง) บอกเลิกสัญญา ซึ่งกรณีนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาได้โดยตรง เนื่องจากการบอกเลิกสัญญามีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดลงไปเลยทีเดียว”^{๑๐}

(๓) อำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาฝ่ายเดียวได้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ฝ่ายปกครองจำเป็นต้องปรับปรุงกิจการสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประโยชน์มหาชน แต่ต้องไม่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ^{๑๑} และต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาฝ่ายเดียวที่มากเกินไปจนขนาดหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญจนอาจสร้างความไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญา มิฉะนั้นคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิเลิกสัญญาได้ เช่น ฝ่ายปกครองขอให้เพิ่มปริมาณวัสดุก่อสร้างจากที่กำหนดไว้เดิมในสัญญาถึงสามเท่า แต่ไม่สามารถชี้แจงได้ว่ามีเหตุผลความจำเป็นเพียงใดที่ต้องเพิ่มปริมาณวัสดุก่อสร้างและจะเป็นผลดีต่อประโยชน์สาธารณะอย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของสัญญาให้แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของสัญญานับเดิมจนกลายเป็นสัญญานับใหม่ เป็นต้น

อนึ่ง เกี่ยวกับการใช้อำนาจฝ่ายเดียวแก้ไขสัญญาทางปกครองมี ข้อสังเกตดังนี้

๑.๓.๑) หลักการใช้อำนาจฝ่ายเดียวแก้ไขข้อสัญญาจะใช้กับสัญญาทางปกครองทุกประเภท แต่ที่พบมากที่สุด คือ ในสัญญาก่อสร้างสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ

๑.๓.๒) ฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้อำนาจฝ่ายเดียวแก้ไขข้อสัญญาเพื่อลดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน

๑.๓.๓) เมื่อฝ่ายปกครองใช้สิทธิแก้ไขข้อสัญญาแล้วมีผลเป็นการเพิ่มภาระให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ฝ่ายปกครองต้องจ่ายค่าทดแทน^{๑๒} หรือขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แก่เอกชนคู่สัญญาเป็นการชดเชย

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าอำนาจบังคับของฝ่ายปกครองในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นอำนาจที่ฝ่ายปกครองมีอยู่ตามหลักกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครองจึงสามารถใช้อำนาจดังกล่าวบังคับเอากับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดไปจากข้อสัญญาได้เองในเบื้องต้นโดยไม่ต้องนำปัญหาไปสู่ศาลปกครองแม้ว่าในข้อสัญญาจะไม่ได้กำหนดอำนาจของฝ่ายปกครองดังกล่าวไว้ก็ตาม แต่กระนั้น การใช้อำนาจของ

^{๑๐} พนม เอี่ยมประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” รวมบทความในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๒๐ ปีของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๓๑, หน้า ๑๕๙.

^{๑๑} โปรดอ่านรายละเอียดใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๙๘-๙๙.

^{๑๒} ค่าทดแทน หมายถึง ค่าทดแทนความเสียหายที่มีอยู่จริงทั้งหมด คือ การขาดทุนจริง ๆ เท่านั้น การขาดทุนกำไร การขาดรายได้เพิ่ม ไม่ใช่ค่าเสียหายที่แท้จริง (โปรดดูใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๒.)

ฝ่ายปกครองดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครอง^{๓๓} ดังนั้น หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเห็นว่าฝ่ายปกครองใช้อำนาจบังคับเอาที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชดเชยค่าเสียหายได้

นอกจากนี้ ในการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ว่าฝ่ายปกครองจะต้องได้แจ้งเตือนให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปฏิบัติตามสัญญา ก่อน หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนยังเพิกเฉยก็อาจสั่งให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนชดเชยค่าเสียหาย และถ้าจำเป็นอาจเข้าทำการแทนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเองหรือให้บุคคลที่สามซึ่งเป็นเอกชนเข้ามาทำการแทนโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่กระทำผิดสัญญาต้องชำระค่าใช้จ่าย หรือในกรณีที่ฝ่ายปกครองเห็นควร ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็สามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นอยู่กรณีเดียว คือ เรื่องสัญญาสัมปทาน ซึ่งการวินิจฉัยว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนผิดสัญญาสัมปทานอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นต้องเลิกสัญญาหรือไม่ จะต้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยเพราะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอาจได้รับความเสียหายมาก

๒) หน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง

ตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาโดยทั่วไปกำหนดให้คู่สัญญาต่างมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน โดยในสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาจ้างก่อสร้างที่ฝ่ายปกครองว่าจ้างคู่สัญญาฝ่ายเอกชนให้ดำเนินการก่อสร้างให้แก่ทางราชการหรือรัฐ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนผลงานที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามจำนวนเงินและภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญา นอกเหนือจากหน้าที่ในการชำระค่าตอบแทนแล้ว ฝ่ายปกครองยังมีหน้าที่ประการอื่นๆ ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากหน้าที่ของคู่สัญญาตามสัญญาทางแพ่ง เช่น หน้าที่จ่ายค่าทดแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเมื่อประสบปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญาหรือต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยความยากลำบากเพราะมีเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้น เพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนพ้นจากสภาวะขาดทุน หรือหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้อำนาจแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียวที่เป็นการสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมากขึ้นเป็นต้น โดยค่าตอบแทนที่ฝ่ายปกครองจ่ายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องมีความเหมาะสม และได้ดูผลพวงกับภาระที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องแบกรับด้วย ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ให้คำอธิบายไว้ว่า “หลักกฎหมายที่ใช้กับสัญญาทางปกครองได้ให้เอกสิทธิ์พิเศษบางอย่างแก่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเท่ากับจำกัดเสรีภาพของเอกชน และกำหนดหน้าที่พิเศษบางประการแก่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดเสรีภาพของฝ่ายปกครอง แต่ก่อให้เกิดสิทธิแก่เอกชน”^{๓๔} ดังนั้น เพื่อให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของฝ่ายปกครองได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

^{๓๓} พนม เอี่ยมประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” รวมบทความในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปีของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์, อ่างแล้ว, หน้า ๑๕๙.

^{๓๔} บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ่างแล้ว, หน้า ๙๑.

จึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวควบคู่กับสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนดังจะได้กล่าวถึงในเนื้อหาดังต่อไปนี้

๒.๒.๒ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน

๑) สิทธิของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน

แม้ในสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองจะมีสถานะเหนือกว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชน แต่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็ยังมีสิทธิบางประการที่คู่สัญญาในสัญญาทางแพ่งธรรมดาด้วยกันไม่มี ได้แก่

๑.๑) สิทธิครอบครองที่ดินของเอกชนอื่นเป็นการชั่วคราวในกรณีจำเป็น เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองให้เอกสิทธิ์ของตนแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ด้วยความเรียบร้อย เช่น ผู้รับจ้างก่อสร้างในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสามารถครอบครองที่ดินของเอกชนอื่นในกรณีจำเป็นเพื่อสร้างที่ทำการชั่วคราว ซึ่งสัญญาที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนดังกล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสัญญาทางปกครองที่ให้ความสำคัญแก่ประโยชน์สาธารณะได้อย่างชัดเจน

๑.๒) สิทธิเด็ดขาดที่จะไม่ให้ฝ่ายปกครองปรับลดค่าตอบแทน ในการเข้าทำสัญญาทางปกครอง คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิเด็ดขาดที่จะไม่ยินยอมให้ฝ่ายปกครองใช้อำนาจแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียวเพื่อลดจำนวนค่าตอบแทนลง

๑.๓) สิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยตามหลักดุลยภาพทางการเงิน แม้ฝ่ายปกครองจะมีเอกสิทธิ์ในการใช้อำนาจแก้ไขข้อสัญญาฝ่ายเดียวได้ แต่จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนในจำนวนที่เหมาะสมให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเพื่อให้สมดุลกับภาระที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องแบกรับเพิ่มขึ้นตามหลัก “ดุลยภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง” (équilibre financier du contrat) ซึ่งมีหลักการสำคัญที่พอสรุปได้โดยสังเขปดังนี้^{๑๕}

^{๑๕} ตัวอย่างที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องหลักดุลยภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง ได้แก่ คำสรุปของพนักงานผู้รับผิดชอบสำนวน Léon Blum ที่ว่า “เป็นที่แน่ชัดว่าบริการสาธารณะประเภทนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประโยชน์สาธารณะ เมื่อรัฐให้สัมปทานการขนส่งไปแล้ว ก็เชื่อว่ารัฐจะไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะขนส่งนั้นอีก เพราะอย่างไรเสียกิจการนี้ยังเป็นบริการสาธารณะ การให้สัมปทานเป็นการให้เอกชนทำแทน กล่าวคือ เป็นวิธีหนึ่งในการดำเนินบริการสาธารณะโดยทางอ้อม ไม่ใช้การละเลยหรือการเพิกเฉย ดังนั้น รัฐจึงอาจเข้าแทรกแซงกำหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องเพิ่มบริการจากที่กำหนดไว้ได้โดยอาศัยอำนาจไม่เพียงตามข้อสัญญาเท่านั้น แต่โดยอาศัยอำนาจมหาชนที่เป็นของฝ่ายปกครองตามหลักกฎหมายมหาชนได้.....แต่ถ้าฝ่ายปกครองผู้ให้สัมปทานใช้อำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวแล้วทำให้ประโยชน์ทางการเงินในสัญญาของผู้รับสัมปทานเสียไป.....เกิดการเสียดุลยภาพระหว่างประโยชน์ตอบแทนกับภาระที่เพิ่มขึ้น.....ไม่มีอะไรห้ามเอกชนผู้รับสัมปทานที่จะร้องขอให้ศาลตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาฝ่ายเดียวที่ขัดด้วยกฎหมายและกฏใหม่ให้เอกชนนั้นทำให้เขาเสียหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายให้” แต่ต้องเข้าใจต่อไปว่า “ค่าทดแทน” (indemnité) นี้ หมายถึงค่าทดแทนความเสียหายที่มีอยู่จริงทั้งหมด คือ การขาดทุนจริงๆ เท่านั้น การขาดทุนกำไร การขาดรายได้เพิ่ม ไม่ใช่ค่าเสียหายที่แท้จริง” (โปรดอ่านรายละเอียดใน บรรทัดที่ อูรรัตนโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑-๑๐๒.)

๑.๓.๑) ในกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้สิทธิแก้ไขสัญญาทางปกครอง ฝ่ายเดียวจนทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีภาระที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเพิ่มขึ้น ฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าทดแทนสำหรับภาระที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยค่าทดแทนดังกล่าวนี้ไม่ใช่ค่าเสียหายเพราะไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดสัญญาของฝ่ายปกครอง

๑.๓.๒) การจ่ายค่าทดแทนของฝ่ายปกครองจะอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีเหตุอันเกิดจากการกระทำของฝ่ายปกครอง (Théorie du fait du prince) ซึ่งมีหลักการว่า หากความเสียหายที่เกิดแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีเหตุมาจากการกระทำของฝ่ายปกครองอันเนื่องมาจากการใช้เอกสิทธิ์จนทำให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญายุ่งยากขึ้น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ฝ่ายปกครองต้องชดเชยค่าทดแทนเต็มจำนวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน แต่หลักการนี้ไม่ใช่ในกรณีที่ฝ่ายปกครองอื่นที่มีคู่สัญญาเป็นผู้ก่อภาระพิเศษในการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน เช่น กรณีที่รัฐออกกฎหมาย หรือคำสั่งเฉพาะเรื่องออกมาแล้วมีผลเป็นการก่อภาระเพิ่มขึ้นให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเอกชนดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับเทศบาล^{๑๖} โดยในกรณีเช่นนี้จะต้องบังคับตามทฤษฎีเหตุอันมีอาจคาดหมายได้แทน

๑.๓.๓) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ปฏิบัติตามสัญญาไปแล้ว หากปรากฏเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้นจนทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยความยากลำบากและอาจต้องประสบปัญหาการขาดทุนล้มละลาย ฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าทดแทนเพื่อช่วยให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนหลุดพ้นจากสภาวะการขาดทุนที่สืบเนื่องมาจากเหตุเช่นนั้น โดยเป็นไปตามทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ (Théorie de l'imprévision) ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าวไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่ทำให้สัญญาทางปกครองมีจุดเด่นเฉพาะที่แตกต่างจากสัญญาทางแพ่งโดยสิ้นเชิง เนื่องจากในสัญญาทางแพ่งนั้น หากไม่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยแล้ว แม้จะมีเหตุนอกเหนือความคาดหมายที่ทำให้คู่สัญญาต้องชำระหนี้ด้วยความยากลำบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากจนประสบสภาวะการขาดทุนอย่างหนักเพียงใดก็ตาม คู่สัญญาก็ยังต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป แต่ในกรณีของสัญญาทางปกครอง หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องล้มละลายเพราะมีเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดแล้ว ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าทดแทนเพื่อให้ดุลยภาพทางการเงินของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่เสียไปกลับคืนมา ซึ่งจะทำให้คู่สัญญา ฝ่ายเอกชนสามารถดำเนินบริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพิจารณาว่ากรณีใดที่ ฝ่ายปกครองสมควรต้องจ่ายค่าทดแทนอันเนื่องมาจากเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้นั้น มีเงื่อนไข ในการพิจารณา ดังนี้

(๑) คู่สัญญาต้องไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น อันกระทบถึงการปฏิบัติตามสัญญาอย่างรุนแรงและเหตุนั้นเป็นเหตุไม่ปกติ เช่น วิกฤตการณ์ร้าย

^{๑๖} บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส, เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๐๕.

แนวทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่การกระทำของฝ่ายปกครองอื่นที่มีผลเป็นการทั่วไป เช่น การลดค่าเงิน การห้ามขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น

(๒) เหตุที่เกิดขึ้นต้องเป็นเหตุที่นอกเหนือเจตนาของคู่สัญญา ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม ใยมะประยูร ให้คำอธิบายว่า “จะต้องเป็นเหตุที่มีได้เกิดจากการกระทำของทั้งเอกชนคู่สัญญา (คู่สัญญาฝ่ายเอกชน) และไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดจากการกระทำของส่วนราชการคู่สัญญา (ฝ่ายปกครอง) ด้วย มิฉะนั้นจะถือเป็นเหตุอันเกิดจากการกระทำของ คู่สัญญาฝ่ายปกครอง (ฝ่ายปกครอง)”^{๑๗}

(๓) เหตุที่เกิดขึ้นต้องเป็นเหตุที่คู่สัญญาไม่อาจป้องกันขัดขวางได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม

(๔) เหตุที่เกิดขึ้นต้องก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความร้ายแรงดังกล่าวต้องถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องประสบภาวะขาดทุนอย่างมากและนานเกินกว่าที่บุคคลธรรมดาจะคาดหมายได้ โดยศาลปกครองจะกำหนดอัตราความเสี่ยงต่อการขาดทุนไว้เป็นความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องแบกรับ ส่วนที่เกินความเสี่ยงที่คนธรรมดาอาจคาดหมายได้เมื่อต้องปฏิบัติตามสัญญาจึงจะเป็นค่าทดแทนที่ฝ่ายปกครองต้องชดใช้^{๑๘} สำหรับผลทางกฎหมายตามทฤษฎีเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ ก็คือ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนยังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไปและได้รับค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผลทางกฎหมายดังกล่าวจะมีอยู่เป็นการชั่วคราวเท่านั้น มิใช่ตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการรักษาความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการมุ่งบรรเทาเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้กลับเปลี่ยนเป็นเหตุที่ถาวร ฝ่ายปกครองก็ต้องชดใช้ค่าทดแทนอีกต่อไปนับตั้งแต่วันที่เหตุนั้นได้กลายเป็นเหตุถาวรอันมีผลทำให้คู่สัญญาต้องเลิกสัญญากันโดยปริยาย โดยถือเสมือนว่าสัญญานั้นตกเป็นพ้นวิสัย ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิได้ค่าทดแทนเป็นเงินจากฝ่ายปกครอง ศาลปกครองจะไม่พิพากษาให้ฝ่ายปกครองชำระค่าทดแทนทันที แต่จะให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนตกลงทำสัญญากันใหม่ก่อน หากคู่สัญญาตกลงกันไม่ได้ ศาลจึงจะกำหนดค่าทดแทนให้ แต่ค่าทดแทนในกรณีนี้จะไม่ใช่ค่าทดแทนเต็มจำนวนดังเช่นกรณีเหตุที่เกิดจากการกระทำของฝ่ายปกครอง โดยศาลจะคำนวณค่าทดแทนให้นับตั้งแต่วันที่เริ่มเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ อันส่งผลกระทบต่อสัญญา และจะกำหนดค่าทดแทนให้เฉพาะในกรณีที่ต้องขาดทุนเกินไปกว่า

^{๑๗} พนม ใยมะประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” รวมบทความในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปีของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์, อ่างแล้ว, หน้า ๑๖๒.

^{๑๘} โปรดอ่าน ไนบวร์คดี อูร์รณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ่างแล้ว, หน้า ๑๐๖-๑๐๗ และ พนม ใยมะประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” รวมบทความในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปีของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์, อ่างแล้ว, หน้า ๑๖๒-๑๖๕.

อัตราความเสี่ยงต่อการขาดทุนธรรมดา โดยจะเฉลี่ยการขาดทุนส่วนใหญ่ให้เป็นภาระของฝ่ายปกครองและให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนรับภาระการขาดทุนเล็กน้อย^{๑๙}

๑.๔) สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนเนื่องจากต้องรับภาระติดพันซึ่งมิได้รับไว้ในสัญญา (Les sujétions imprévues) ซึ่งภาระติดพันดังกล่าวจัดเป็นปัญหายากเกี่ยวกับเงื่อนไขที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องประสบในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างและมีลักษณะที่ผิดปกติดังกล่าว โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจมิได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของปัญหาดังกล่าวมาก่อนและในขณะที่ทำสัญญาก็ไม่คาดคิดว่าจะมีปัญหาลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น เช่น ปัญหาความอ่อนตัวของดิน แอ่งน้ำขนาดใหญ่ใต้ผิวดิน แนวหินแข็ง เป็นต้น ทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าปกติ ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถใช้สิทธิเรียกค่าทดแทนได้เต็มจำนวน

๒) หน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน

ดังได้กล่าวแล้วว่าสัญญาทางปกครองมีวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะและการจัดทำบริการสาธารณะจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเอกชนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาดังกล่าวจึงมีหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามสัญญาทุกประการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นการปฏิบัติตามสัญญาไม่อาจกระทำได้นี้เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้การชำระหนี้ตามสัญญาตกเป็นพ้นวิสัยโดยมิใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สัญญาจึงยอมเลิกไปโดยผลของกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาสามารถหลุดพ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับหลักในการพิจารณาว่ากรณีใดถือเป็นเหตุสุดวิสัย นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม ใยมะประยูร ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า ต้องมีสาระสำคัญ ๔ ประการ คือ เหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ (imprévue et imprévisible) เหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมิได้เกิดจากการกระทำของเอกชนคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางใด (absolument indépendant de la volonté du cocontractant) เหตุที่เกิดขึ้นนั้นเอกชนคู่สัญญาไม่อาจป้องกันขัดขวางได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว และเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง (avoir rendu radicalement impossible l'exécution) ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยถือเอาตามที่สุดวิสัยจะป้องกันได้ ไม่จำกัดว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะอย่างไร ถ้าผู้ประสบไม่สามารถจะป้องกันความเสียหายอันเกิดจากภัยนั้นได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยทั้งสิ้น^{๒๐} จากหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อพิจารณาโดยผิวเผินแล้วอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับทฤษฎีเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ แต่หากพิจารณาในแง่หลักการแล้ว ทั้งเหตุสุดวิสัยและเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้มีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าเหตุสุดวิสัยจะมีผลถึงขนาดทำให้การปฏิบัติตามสัญญาต้องตกเป็นพ้นวิสัยไปเลย

^{๑๙} บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๗.

^{๒๐} พนม ใยมะประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” รวมบทความในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปีของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๑.

ในขณะที่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้นั้น ยังพอมีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป เพียงแต่จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

๒.๓ การสิ้นสุดของสัญญาทางปกครอง

โดยทั่วไปการสิ้นสุดของสัญญาทางปกครองตามแนวคิดของฝรั่งเศสอาจสิ้นสุดลงได้ในหลายกรณีด้วยกัน เช่น เมื่อมีการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว หรือเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญานั้นเอง หรือคู่สัญญาพร้อมใจกันเลิกสัญญา หรือเมื่อการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย เป็นต้น แต่กรณีนั้นสัญญาทางปกครองก็อาจสิ้นสุดลงตามหลักการเฉพาะอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ให้คำอธิบายว่า “การเลิกสัญญาเป็นหลักเฉพาะของสัญญาทางปกครอง”^{๒๑} ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

๒.๓.๑ การเลิกสัญญาโดยฝ่ายปกครอง เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้สิทธิเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้แม้จะไม่มีข้อสัญญากำหนดไว้เช่นนั้นก็ตาม แต่ต้องมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังนี้

๑) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกระทำผิดสัญญาอย่างร้ายแรง

๒) เป็นการบอกเลิกสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนอาจจะไม่ได้กระทำผิดสัญญาแต่ประการใด การเลิกสัญญาในกรณีนี้ฝ่ายปกครองอาจทำเป็นคำสั่งเฉพาะเรื่อง หรือกฎ หรือข้อบังคับก็ได้ และเมื่อมีการเลิกสัญญากันแล้วฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเต็มจำนวน เพราะการใช้อำนาจเลิกสัญญาฝ่ายเดียวดังกล่าวมีลักษณะเป็นการขยายอำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองออกไป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การใช้เช่นเดียวกับการใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาของฝ่ายปกครอง

๒.๓.๒ การเลิกสัญญาโดยศาลปกครอง ศาลปกครองสามารถวินิจฉัยให้สัญญาทางปกครองเลิกกันได้กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีคำร้องขอ เนื่องจากฝ่ายปกครองกระทำผิดสัญญาอย่างร้ายแรงหรือเมื่อฝ่ายปกครองใช้อำนาจฝ่ายเดียวแก้ไขข้อสัญญาจนเกินขนาดหรือเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น

๒) เมื่อฝ่ายปกครองมีคำร้องขอ โดยเฉพาะการเลิกสัญญาสัมปทานซึ่งฝ่ายปกครองไม่มีสิทธิดำเนินการเอง

๓) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำร้องขอในกรณีที่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ได้กลายเป็นเหตุการณ์

^{๒๑} บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๘-๑๐๙.

๓. แนวคิดของเยอรมันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง^{๒๒} และผลของสัญญาทางปกครอง

๓.๑ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖^{๒๓}

เยอรมันเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแม่แบบของระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับฝรั่งเศสและมีการพัฒนาระบบกฎหมายมหาชนแยกออกจากระบบกฎหมายเอกชน รวมทั้งแบ่งแยกสัญญาที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายทั้งสองระบบดังกล่าวออกจากกันเป็นสัญญาทางปกครองและสัญญาทางแพ่งเช่นเดียวกับฝรั่งเศส แต่แนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของทั้งสองประเทศนี้กลับมิได้มีความคล้ายคลึงกันแต่ประการใด ทั้งนี้ เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีบริการสาธารณะเป็นสำคัญดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายปกครองของเยอรมันถือว่า “สัญญาทางปกครองเป็นผลิตผลของกระบวนการพิจารณาเรื่องทางปกครองอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับคำสั่งทางปกครอง....และถือว่าสัญญาทางปกครอง

^{๒๒} ในงานเขียนของนักวิชาการไทยที่เขียนเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครองของเยอรมันได้ใช้คำเรียกสัญญาทางปกครองของเยอรมันแตกต่างกัน โดยในงานเขียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกววงศ์ ใช้คำว่า “สัญญาตามกฎหมายมหาชน” (กมลชัย รัตนสกววงศ์, “ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทย ในภาพรวม,” วารสารกฎหมายปกครอง เล่มที่ ๑๗ ตอน ๓ (ธันวาคม ๒๕๔๑), หน้า ๑๖.)

แต่ในงานเขียนของ ดร. มานิตย์ วงศ์เสรี และรองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ใช้คำว่า “สัญญาทางปกครอง” โดยในส่วนของ ดร. มานิตย์ วงศ์เสรี ได้ให้เหตุผลว่า “หากสัญญาทางปกครองมีความหมายกว้างและครอบคลุมไปถึงสัญญาทุกประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน กล่าวคือ จะหมายความรวมไปถึงสัญญาระหว่างรัฐกับรัฐหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากถ้าพิจารณาจากขอบเขตการใช้บังคับโดยทั่วไปของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ ในมาตรา ๑ (๑) ซึ่งกล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมหาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งกล่าวถึงความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแล้ว จะเห็นได้ว่าคำว่า “สัญญาตามกฎหมายมหาชน” นั้น มีเจตนารมณ์ให้หมายความถึงสัญญาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ตกลงทำสัญญาและภายในขอบเขตของกฎหมายปกครองเท่านั้น ดังนั้น คำว่า “oeffentlich-rechtliche Vertrag” ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครอง จึงหมายถึง “สัญญาตามกฎหมายปกครอง” ซึ่งก็คือ “สัญญาทางปกครอง” สัญญาทางปกครองจึงหมายถึงสัญญาที่มีเนื้อหาระยะเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครองอันเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง หรือระงับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครอง” (มานิตย์ วงศ์เสรี, หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน, สำนักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๕, หน้า ๔-๕.)

ดังนั้น หากข้อความใดที่เอกสารการศึกษานี้ได้อ้างอิงมาจากการเขียนของนักวิชาการดังกล่าวโดยปรากฏว่ามีการใช้คำทั้งสองคำนี้ปะปนกัน ย่อมแสดงว่ามีเจตนาให้หมายถึง “สัญญาทางปกครอง” เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ตามความมุ่งหมายของเอกสารการศึกษานี้ประสงค์จะใช้คำว่า “สัญญาทางปกครอง” เพราะเป็นคำที่นักกฎหมายหรือผู้ที่ศึกษากฎหมายสามารถเข้าใจได้ตรงกันว่าหมายถึงสัญญาประเภทใด

^{๒๓} กมลชัย รัตนสกววงศ์ ใช้ในชื่อว่า “กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาเรื่องในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (VwVfG) ค.ศ. ๑๙๗๖”

เป็นเครื่องมือในการก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกนิติสัมพันธ์ทางปกครองได้เช่นเดียวกับคำสั่งทางปกครอง”^{๒๔} หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ฝ่ายปกครองใช้สัญญาเป็นเครื่องมือในการก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลแทนการออกคำสั่งทางปกครองหรือใช้เป็นเครื่องมือเสริมการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ความยืดหยุ่นและบรรลุวัตถุประสงค์ทางปกครองมากขึ้น ดังเช่น สัญญาที่ฝ่ายปกครองตกลงกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนยอมยกเว้นหน้าที่ตามกฎหมายบางประการให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนตกลงให้เงินจำนวนหนึ่งแก่ฝ่ายปกครองเป็นการตอบแทนเพื่อฝ่ายปกครองนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในระบบกฎหมายปกครองของเยอรมันยังขาดหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีพัฒนาการที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับฝรั่งเศส ทำให้ต้องนำหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสัญญามาปรับใช้กับสัญญาทางปกครองโดยนำมาบัญญัติไว้ใน มาตรา ๕๔ ถึงมาตรา ๖๒^{๒๕} ของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของเยอรมันไว้โดยเฉพาะ สำหรับหลักกฎหมายทั่วไปที่สำคัญซึ่งเยอรมันนำมาใช้เป็นพื้นฐานของหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คือ “หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้ให้คำอธิบายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ไว้ว่า “หลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่สนับสนุนความมั่นคงแห่งนิติฐานะของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยการเคารพหลักการ “สัญญาต้องเป็นสัญญา” คู่สัญญาฝ่ายเอกชนย่อมสามารถไว้วางใจได้ว่าฝ่ายปกครองจะปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจ”^{๒๖} นอกจากนี้ ยังมีการนำหลักกฎหมายทั่วไปทางแพ่งอื่นๆ มาใช้ด้วย ได้แก่ หลักการแสดงเจตนา หัก และนิติสัมพันธ์เรื่องหนี้ที่เกิดจากสัญญา เป็นต้น และด้วยเหตุที่บทบัญญัติสำคัญๆ เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา ทางปกครอง ค.ศ. ๑๙๗๖ หรือ VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบทบัญญัติเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น มาตรา ๖๒ ของกฎหมายดังกล่าวจึงบัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้กับสัญญาทางปกครองในฐานะเป็นบทเสริมกิจการของฝ่ายปกครอง (Privatrechtliche Hilfsgesetze der Verwaltung) รวมทั้งให้นำบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ของกฎหมายดังกล่าวมาใช้กับเรื่องสัญญาทางปกครองด้วยเท่าที่เหมาะสม เช่น ความสามารถของคู่กรณีตามมาตรา ๑๑ การไม่เป็นคู่สัญญาได้เสียตามมาตรา ๒๐ และ

^{๒๔} วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง, บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กันยายน ๒๕๔๙, หน้า ๓๓.

^{๒๕} โปรตุเกสใน กมลชัย รัตนสกววงศ์, “ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” อ้างแล้ว, หน้า ๑๖.

^{๒๖} วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง, อ้างแล้ว, หน้า ๓๙.

มาตรา ๒๑ และดุลพินิจตามมาตรา ๔๐ เป็นต้น^{๒๗} ส่วนหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองประการอื่นๆ ได้แก่ สัญญาทางปกครองที่มีผลบังคับได้จะต้องทำเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ หรือ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการบอกเลิกสัญญาทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อให้เกิดแห่งหนึ่งของสัญญาสิ้นไปหรือไม่มีพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการชำระหนี้ตามสัญญาแล้ว (Wegfall der Geschäftsgrundlage) ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอาจนำเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์มาอ้างหรือบอกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น

๓.๑.๑ ประเภทของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองของเยอรมัน

นิติสัมพันธ์ในสัญญาทางปกครองของเยอรมันอาจเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายปกครองด้วยกัน หรือระหว่างคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายปกครองกับฝ่ายเอกชนก็ได้ แต่ในกรณีที่ฝ่ายเอกชนเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาต้องทราบตั้งแต่ขณะเข้าทำสัญญาแล้วว่าทั้งสองฝ่ายผูกพันกันตามสัญญาทางปกครอง เพราะเป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ หรือในขณะที่ทำสัญญา คู่สัญญาอาจไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสัญญาทางแพ่งหรือทางปกครอง แต่ข้อความในสัญญาให้สิทธิพิเศษแก่ฝ่ายปกครองอย่างมาก หากจะปรับให้เป็นสัญญาทางแพ่ง สัญญานั้นอาจจะขัดต่อกฎหมายและเป็นโมฆะ เพราะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มีเสรีภาพในการทำสัญญาดังเช่นสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกัน ส่วนในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายปกครอง (Koordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag) หรือที่เรียกกันในองค์การปกครองท้องถิ่นว่าความตกลงทางมหาชน (oeffentlich-rechtliche Vereinbarung) เป็นสัญญาทางปกครองที่ฝ่ายปกครองทำความตกลงกันเพื่อประโยชน์มหาชนเพราะไม่อาจกระทำได้โดยการออกคำสั่งทางปกครอง เช่น สัญญาระหว่างเทศบาลสองแห่งเกี่ยวกับแนวเขตแม่น้ำลำธาร การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ของเทศบาล สัญญาระหว่างทางตัดผ่านของทางรถไฟและถนนหลวง เป็นต้น คู่สัญญา ในสัญญาเหล่านี้มีสถานะที่เท่าเทียมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจบังคับการแก้อีกฝ่ายหนึ่งได้หากมีการปฏิบัติผิดสัญญา ดังนั้น จึงต้องนำคดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง^{๒๘}

๓.๑.๒ ประเภทของสัญญาทางปกครองของเยอรมัน

^{๒๗} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” เอกสารประกอบการสัมมนาตุลาการศาลปกครองภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗, สำนักวิจัยและวิชาการ, สำนักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๗, หน้า ๖.

^{๒๘} โปรดอ่านรายละเอียดใน กมลชัย รัตนสากวรงค์, “ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” อ้างแล้ว, หน้า ๑๗-๑๘.

สำหรับการพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของสัญญาทางปกครองของเยอรมันนั้น Professor Ziekow ให้ความเห็นว่า ตามมาตรา ๕๔ ประโยคที่หนึ่ง VwVfG สามารถพิจารณาได้ว่า สัญญาทางปกครองครอบคลุมสามประเภท ได้แก่

๑) สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกันตามนัยของมาตรา ๕๔ ประโยคที่สอง แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยคำพิพากษาระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๐๐ ถึง ค.ศ. ๑๙๙๓ เฉพาะเรื่องสัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกันของ Maurer และ Bartscher พบว่ามีสัญญาทางปกครองระหว่างรัฐกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนอยู่ในสาขากฎหมายสำคัญ ๆ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง กฎหมายเทศบาล กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับงานให้บริการ กฎหมายการให้การสนับสนุนการศึกษา กฎหมายทางหลวง กฎหมายเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลือ และกฎหมายเกี่ยวกับสังคม^{๒๙}

๒) สัญญาทางปกครองที่กำหนดความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชนบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน

๓) สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกันในฐานะเป็นฝ่ายปกครองด้วยกัน^{๓๐}

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักวิชาการไทยที่มีงานเขียนเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของเยอรมันได้แบ่งสัญญาทางปกครองไว้แตกต่างกัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้กล่าวถึงประเภทของสัญญาทางปกครองของเยอรมันเพียงสองประเภท ได้แก่ สัญญาต่างตอบแทนและสัญญาระดับข้อพิพาททางปกครอง^{๓๑} ในขณะที่ ดร. มานิตย์ วงศ์เสรี และดร. เพ็ญศรี วงศ์เสรี^{๓๒} ได้แบ่งประเภทของสัญญาทางปกครองของเยอรมันออกเป็น ๔ ประเภท^{๓๓} ดังนี้

^{๒๙} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, "สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน," อ้างแล้ว, หน้า ๒๒.

^{๓๐} โปรดอ่านรายละเอียดใน เพ็ญศรี วงศ์เสรี, "สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน," เล่มเดียวกัน, หน้า ๑-๖๖.

^{๓๑} วรเจตน์ ภาคีรัตน์, หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕๒.

^{๓๒} มานิตย์ วงศ์เสรี, หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔ และเพ็ญศรี วงศ์เสรี, "สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน," อ้างแล้ว, หน้า ๒๖-๓๑.

^{๓๓} ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกววงศ์ ได้แบ่งประเภทของสัญญาทางปกครองของเยอรมันว่ามี ๔ ประเภท ได้แก่

(๑) สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเป็นสัญญาต่างตอบแทน

(๒) สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเป็นการประนีประนอมกันเพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน

(๓) สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเป็นการทำความตกลงระหว่างฝ่ายปกครองด้วยกันเองในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(๔) สัญญาทางปกครองที่เกิดจากการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลปกครอง

ประเภทแรก สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกัน (Koordinationsrechtlicher Vertrag) (ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย รัตนสภาวะวงศ์ เรียกสัญญาประเภทนี้ว่า สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเป็นการทำความตกลงระหว่างฝ่ายปกครองด้วยกันเองในการบริหารราชการแผ่นดินหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย) หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายมหาชน (Rechtssubjekt) มีฐานะเท่าเทียมกันและวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการกำหนดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน (กฎหมายปกครอง) จึงมีลักษณะเป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานทางปกครองด้วยกันเอง โดยอาจมีเพียงสองหน่วยงานหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ ได้แก่ สหพันธ์ มลรัฐ องค์การปกครองท้องถิ่น นิติบุคคลมหาชน เช่น สัญญาระหว่างมลรัฐกับเทศบาลในการทำความตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรเงินสนับสนุนโรงละครในเขตเทศบาล หรือสัญญาระหว่างเทศบาลกับองค์กรท้องถิ่นเรื่องการโอนอำนาจหน้าที่ในการกำจัดขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ ในสัญญาประเภทนี้อาจมีการกำหนดเนื้อหาให้คู่สัญญาต้องกระทำการแลกเปลี่ยนหรือต่างตอบแทน หรือมีเนื้อหาเป็นการประนีประนอมกันก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

ประเภทที่สอง สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน (Subordination srechtliche Verträge) หมายถึง สัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครองและมีความสัมพันธ์ในฐานะที่เหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายเอกชน โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายมหาชน ฝ่ายปกครองโดยเจ้าหน้าที่สามารถทำสัญญากับฝ่ายเอกชนโดยตรงแทนการออกคำสั่งทางปกครอง หรือคู่สัญญาทั้งสองอาจเป็นเอกชนด้วยกันก็ได้หากปรากฏว่าเอกชนฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากฝ่ายปกครองตามกฎหมายให้กระทำการทางปกครอง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายปกครองซึ่งมีฐานะเหนือกว่าฝ่ายเอกชนก็สามารถทำสัญญาในลักษณะที่คู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกันได้ โดยเนื้อหาของสัญญาจะมีลักษณะเป็นการต่างตอบแทน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนหรือประนีประนอมกันก็ได้

ประเภทที่สาม สัญญาต่างตอบแทน (Austauschvertrag) หมายถึง สัญญาทางปกครองที่มีเนื้อหาเป็นการวางกฎเกณฑ์ระหว่างคู่สัญญาให้มีหน้าที่ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ชำระหนี้ต่างตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้อย่างชัดเจนแล้วในสัญญา และเพื่อให้ฝ่ายปกครองสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะได้บรรลุผล นอกจากนี้ ประโยชน์ตอบแทนที่ฝ่ายปกครองจะได้รับต้องมีความเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้

(โปรดอ่านรายละเอียดในกมลชัย รัตนสภาวะวงศ์, “ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” อ้างแล้ว, หน้า ๒๐-๒๒.)

รับจากสัญญาทางปกครอง^{๓๔} ทั้งนี้ สัญญาประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำอำนาจรัฐไปใช้โดยมิชอบหรือเพื่อป้องกันมิให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ของรัฐไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็เพื่อคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ให้ถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้ที่ตนไม่ได้ผูกพันตามกฎหมาย การกระทำการแลกเปลี่ยนหรือต่างตอบแทนจึงต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครองของฝ่ายปกครอง โดยฝ่ายปกครองต้องไม่ทำสัญญาที่กำหนดข้อเรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกระทำการใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลทำให้ฝ่ายปกครองได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างมาก เช่น สัญญาให้ทุนการศึกษา การต่างตอบแทนของผู้รับทุนไม่ใช่หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา แต่เป็นการเข้าทำงานในหน่วยงานที่ให้ทุนและต้องอยู่ในหน่วยงานนั้นตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ประเภทที่สี่ สัญญาประนีประนอม (Vergleichsvertrag) มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนหรือความไม่แน่นอน หรือเพื่อหาข้อยุติปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในสัญญาทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เป็นสัญญาที่ใช้ในกรณีที่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติและหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยหรืออันตรายจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ การทำสัญญาประเภทนี้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นการประนีประนอมในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเท่านั้น ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล ศาลปกครองก็อาจไกล่เกลี่ยให้คู่ความประนีประนอมกันเพื่อยุติคดีปกครองนั้นได้ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ

๓.๒ ผลของสัญญาทางปกครอง

จากการศึกษางานเขียนเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครองของเยอรมันที่เขียนโดยนักวิชาการไทยหลายท่าน ปรากฏว่าไม่ได้มีการเขียนเกี่ยวกับผลของสัญญาทางปกครองและสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญาทางปกครองของเยอรมันไว้อย่างชัดเจน และเป็นระบบดังเช่นงานเขียนของนักวิชาการไทยที่เขียนเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส คงมีเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองของเยอรมันเท่านั้นที่นักวิชาการไทยดังกล่าวได้กล่าวถึงและให้ความสำคัญอย่างชัดเจน ดังนั้นในเอกสารการศึกษานี้จึงจำเป็นต้องจัดทำหัวข้อในส่วนที่เกี่ยวกับผลของสัญญาทางปกครองของเยอรมันในลักษณะที่แตกต่างไปจากเนื้อหาเกี่ยวกับผลของสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส ดังปรากฏในเนื้อหาที่จะได้นำเสนอในลำดับต่อไป

๓.๒.๑ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

^{๓๔} โปรดอ่านรายละเอียดใน กมลชัย รัตนสกววงศ์, “ความพยายามในการนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” อ้างแล้ว, หน้า ๒๐-๒๑ และเพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” อ้างแล้ว, หน้า ๒๘.

ตามหลักกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสได้ให้อำนาจฝ่ายปกครองแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนก่อนหากเป็นการแก้ไขสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการแก้ไขจนเกินสมควรแก่เหตุ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็มีสิทธิเลิกสัญญาได้ในขณะที่สัญญาทางปกครองของเยอรมันมิได้มีแนวความคิดดังเช่นของฝรั่งเศส เนื่องจากฝ่ายปกครองของเยอรมันในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ภายในขอบเขตของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง (Gesetzmäßigkeitsgrundsatz) โดยตามมาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ บัญญัติเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวโดยใช้ข้อความว่า “ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย” ประกอบกับมาตรา ๖๐ (๑) ประโยคที่หนึ่งแห่งกฎหมายดังกล่าว บัญญัติให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิขอให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาทางปกครองได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วย หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ตกลงยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถนำคดีไปฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาได้ โดยให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาอาจทำได้ทั้งในแง่ของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและควรต้องเป็น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเมื่อบ่อเกิดแห่งหนี้ตามสัญญาสิ้นไปหรือไม่กฎหมายรองรับข้อกำหนดให้ต้องชำระหนี้ตามสัญญาอีกต่อไป เช่น ภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาทางปกครองไปแล้ว หากปรากฏว่ามีการแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ทำให้มีผลกระทบต่อนิติสัญญาที่ได้จัดทำไปแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ภายใต้หลักการดังกล่าวข้างต้น

๒) สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย

สำหรับในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายปกครอง เพราะมีความจำเป็นต้องคุ้มครองและขจัดความเสียหายที่จะมีต่อประโยชน์สาธารณะ (ซึ่งจะกล่าวต่อไปหัวข้อ ๓.๒.๒ การสิ้นสุดสัญญา) คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยการนำหลักเกณฑ์เรื่องการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๙ (๕) ประโยคที่หนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ มาบังคับใช้โดยอนุโลม^{๓๕} ซึ่ง ดร. เพ็ญศรี วงศ์เสรี ได้อธิบายไว้ว่า “สิทธิเลิกสัญญาทางปกครองเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิตามกฎหมายสัญญา.....ก่อให้เกิดสิทธิ (ที่จะได้รับการ) ชดเชยค่าเสียหายเพราะเหตุว่าความไว้วางใจที่คู่สัญญาเชื่อมั่นในความมีอยู่ของสัญญาทางปกครองดังกล่าวได้รับความกระทบกระเทือน (หรือถูกฝ่าฝืน) กล่าวคือ การชดเชยค่าเสียหายเพื่อความไว้วางใจในกรณีของการ

^{๓๕} มานิตย์ วงศ์เสรี, หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑.

เลิกสัญญา ดังนั้น ตาม “หลักสุจริต” (Treu und Glaube) จึงจำเป็นต้องชดใช้
 หายเพื่อจัดผลกระทบกระเทือนดังกล่าว”^{๓๖}

ค่าเสีย

๓) การบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาโดยทันที

กฎหมายปกครองเยอรมันให้อำนาจฝ่ายปกครองในการบังคับการ
 ให้เป็นไปตามสัญญาทางปกครองได้ทันทีตามมาตรา ๖๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางป
 ครงฯ เฉพาะในกรณีที่เป็นสัญญาระหว่างฝ่ายปกครองกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชน หรือ
 อีกนัยหนึ่งก็คือ สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่ในกรณีที่เป็นสัญญา
 ทางปกครองซึ่งคู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกัน เพราะเป็นสัญญาที่ทำระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วย
 กัน (ในงานเขียนของ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกววงศ์ ใช้คำว่า “หน่วยงานของรัฐ”
 และ “ฝ่ายปกครอง” ปะปนกัน) ในฐานะที่เท่าเทียมกัน คู่สัญญาจะไม่สามารถใช้สิทธิบังคับการ
 ตามสัญญาได้เองหากแต่ต้องนำคดีไปฟ้องศาลปกครอง

การใช้สิทธิบังคับการตามสัญญาเช่นนี้จะใช้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
 ไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญา แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้แสดงเจตนา
 ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า จะยอมให้บังคับการได้ทันที การแสดงเจตนาดังกล่าวเป็นการกระทำทางกฎหมาย
 และเป็นการกระทำฝ่ายเดียวที่แสดงต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะทำให้สัญญากลายเป็นคำบังคับ
 ที่ใช้บังคับตามสัญญาได้เลย และหากการแสดงเจตนาดังกล่าวกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 แม้ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาทางปกครองก็เป็นการเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ หลักการบังคับการได้ทันที
 ดังกล่าวอาจใช้ในการกรณีที่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา โดยเรียกร้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
 ปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการไม่ชำระหนี้ตามสัญญา หรือ
 ชำระหนี้ล่าช้า หรือชำระหนี้บกพร่อง เป็นต้น^{๓๗}

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิบังคับการตามสัญญาทางปกครอง
 โดยทันทีของฝ่ายปกครองจะแตกต่างจากของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน กล่าวคือ หากเป็น
 ฝ่ายปกครองก็จะเข้าดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องในสัญญาโดยการออกคำสั่ง
 ทางปกครองได้ด้วยตนเอง^{๓๘} โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจะต้องเป็นนักกฎหมายวิชาชีพ หรือ
 Assessor หรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยตุลาการของเยอรมันเพื่อประกัน
 ความรู้ทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบังคับตามสัญญาทางปกครองและต้องได้รับอนุมัติ
 จากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการเฉพาะเรื่องดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
 ระดับสูงของสหพันธรัฐหรือของมลรัฐ แต่ในกรณีที่เป็นการบังคับการโดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชน
 ก็จะต้องนำคดีเข้าสู่ศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลออกกฎหมายบังคับคดี (die

^{๓๖} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” อ้างแล้ว, หน้า ๕๐.

^{๓๗} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๕๓-๕๔.

^{๓๘} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๕๔.

Vollstreckungsverfuegung) บังคับแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๑๗๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล (die Verwaltungsgerechtsordnung)^{๓๙}

สำหรับในแง่ของกระบวนการในการบังคับตามสิทธิเรียกร้องในสัญญาทางปกครองของฝ่ายปกครองเพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปฏิบัติตามสัญญานั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเรียกร้องให้ชำระหนี้เป็นเงิน การกระทำการ จำยอมให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำเป็นต้น ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องชำระหนี้เป็นเงิน ฝ่ายปกครองจะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คู่สัญญาฝ่ายเอกชนยังไม่ชำระหนี้ ฝ่ายปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสิทธิออกคำบังคับหรือดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนออกขายทอดตลาดต่อไป ส่วนในกรณีที่เป็นการบังคับตามสิทธิเรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนกระทำการ จำยอมให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำ หากมีการตกลงกันไว้ในสัญญาทางปกครองให้สามารถบังคับตามสิทธิได้ทันที เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ “วิธีบังคับทางปกครอง” วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

(ก) การจัดการแทน

(ข) ค่าปรับทางปกครอง

(ค) การบังคับทางปกครองโดยตรง^{๔๐}

เพียงแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการบังคับทางปกครองดังกล่าวจะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนทราบก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีบังคับทางปกครองโดยทันทีเพื่อขจัดความเสียหายที่อาจมีต่อส่วนรวม ก็ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว

สำหรับกระบวนการในการบังคับตามสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเพื่อให้ฝ่ายปกครองชำระหนี้เป็นเงินนั้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้กำหนดคำบังคับให้ฝ่ายปกครองชำระเงินตามสัญญาทางปกครอง โดยศาลปกครองจะกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองและขอให้ฝ่ายปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับทางปกครองให้ต่อไปอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ ศาลปกครองไม่จำเป็นต้องกำหนดคำบังคับตามคำร้องของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเสมอไป แต่อาจกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองเป็นอย่างอื่นก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ศาลปกครองจะกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง จะต้องสั่งการหรือเตือนให้ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อน^{๔๑}

๔) การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

^{๓๙} โปรดอ่านรายละเอียดใน กมลชัย รัตนสกววงศ์, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๓๕-๓๖.

^{๔๐} มานิตย์ วงศ์เสรี, หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘.

^{๔๑} โปรดอ่านรายละเอียดใน มานิตย์ วงศ์เสรี, หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองของประเทศเยอรมัน, เล่มเดียวกัน, หน้า ๓๘-๓๙.

สำหรับหลักในการใช้สิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ต่อศาลนั้น จะต้องพิจารณาลักษณะของข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางปกครองแยกเป็นสองส่วน ได้แก่

(ก) ส่วนแรก เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อสัญญา การตีความ การปฏิบัติตามสัญญา การปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาและการเลิกสัญญา

(ข) ส่วนที่สอง เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาทางปกครอง หรือเกิดจากการขอปรับปรุงแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญา

ในเรื่องการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกววงศ์ ได้ให้คำอธิบายว่า ตามระบบกฎหมายและการศาลของเยอรมัน ศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองเฉพาะในส่วนแรกเท่านั้น ส่วนการพิจารณาพิพากษาเรื่องค่าเสียหายต่างๆ ตามสัญญาทางปกครองเป็นอำนาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความทางปกครองฯ และมาตรา ๓๔ แห่งรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (GG)^{๔๒} ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงต้องฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาในส่วนแรกต่อศาลปกครองและฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนที่สองต่อศาลยุติธรรม จากการแบ่งเขตอำนาจศาลดังเช่นที่กล่าวมานี้จึงเป็นการสร้างภาระให้แก่คู่สัญญาที่จะต้องนำคดีพิพาทไปสู่ศาลทั้งสองระบบศาลและอาจทำให้คดีต้องล่าช้าได้ ลักษณะการแบ่งเขตอำนาจดังกล่าวนี้นับว่ามีความแตกต่างจากระบบกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส เพราะศาลปกครองฝรั่งเศสมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาทางปกครองทั้งสองส่วนดังกล่าวเพียงศาลเดียว

๓.๒.๒ การสิ้นสุดของสัญญา

ตามแนวความคิดเกี่ยวกับผลของสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสถือว่า คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยต้องจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตลอดเวลา เพราะหัวใจหลักของสัญญาทางปกครองมุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงไม่สามารถอ้างสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญากับฝ่ายปกครองได้ แม้ฝ่ายปกครองจะเป็นผู้กระทำผิดสัญญาก็ตาม เพราะตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสมิได้นำหลักสัญญาต่างตอบแทนซึ่งเป็นหลักทางแพ่งมาใช้ในทุกกรณี สิทธิที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนพึงมีพึงได้ก็คือ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือร้องขอให้ศาลสั่งให้เลิกสัญญาในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง ในขณะที่แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ในหลักเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของเยอรมันแต่ประการใด ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. กมลชัย รัตนสกววงศ์ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ฝ่ายปกครองของเยอรมันในฐานะที่เป็นรัฐคงจะไม่ปฏิบัติผิดสัญญา เพราะหากมีความจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา

^{๔๒} โปรดอ่านใน กมลชัย รัตนสกววงศ์, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๓๗.

ได้ กฎหมายปกครองของเยอรมันก็ให้สิทธิคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอปรับปรุงแก้ไขสัญญาหรือขอเลิกสัญญาได้”^{๔๓} ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะเป็นสัญญาทางปกครองประเภทที่จัดทำระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหรือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชน

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาทางปกครองของเยอรมันซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา ๖๐ (๑) แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ สะท้อนว่า การเลิกสัญญาเป็นเพียงทางเลือกลำดับรองและจะใช้เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไม่อาจกระทำได้หรือขาดความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ คู่สัญญาที่สามารถบอกเลิกสัญญาได้จะต้องเป็นผู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา (Rücktrittsberechtigt) และการบอกเลิกสัญญาสามารถกระทำได้ด้วยการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากตามมาตรา ๕๗ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ กำหนดให้ขั้นตอนการทำสัญญา ต้องทำเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นจะถือว่ายังไม่มีสัญญาทางปกครองเกิดขึ้น ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอื่นๆ ดังเช่น การเลิกสัญญาก็ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย^{๔๔}

ส่วนผลของการบอกเลิกสัญญา นั้น จะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อการแสดงเจตนาขึ้นไปถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว อันมีผลทำให้สัญญาระงับ (rückgängig) และสิทธิเรียกร้องให้คู่สัญญาชำระหนี้สิ้นสุดลง ส่วนการชำระหนี้ที่คู่สัญญาได้กระทำไปก่อนแล้ว ก็ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม^{๔๕}

สำหรับหลักในการเลิกสัญญาตามกฎหมายปกครองเยอรมันจะแบ่งออกเป็นสองกรณีตามมาตรา ๖๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ ดังนี้

(ก) การเลิกสัญญาในกรณีปกติ คู่สัญญาฝ่ายปกครองหรือฝ่ายเอกชนสามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาแบบนี้ได้หากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

(ข) การเลิกสัญญาแบบพิเศษ มีลักษณะเป็นสิทธิจำเป็น (Notrecht) ซึ่งกฎหมายให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครองให้เป็นผู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อันเป็นเพียงการแสดงเจตนาตามกฎหมายมหาชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์สาธารณะในกรณีจำเป็นหรือเพื่อขจัดผลเสียหายให้สิ้นไปตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาทางปกครองฯ^{๔๖}

จากลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายปกครองของเยอรมันให้ความสำคัญคุ้มครองประโยชน์ของเอกชนและประโยชน์สาธารณะอย่างเสมอภาคกัน ดังจะเห็นได้จากหลัก

^{๔๓} กมลชัย รัตนสากววงศ์, “สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส,” อ้างแล้ว, หน้า ๓๓.

^{๔๔} โปรดดูรายละเอียดใน เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” อ้างแล้ว, หน้า ๔๗-๔๘ และหน้า ๗-๙.

^{๔๕} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๔๘.

^{๔๖} เพ็ญศรี วงศ์เสรี, “สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๔๙-๕๐.

กฎหมายที่ให้สิทธิคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถเลิกสัญญาได้ เพียงแต่มีเงื่อนไขที่เคร่งครัดว่าจะต้องเป็นกรณีที่การแก้ไขสัญญาไม่อาจกระทำได้อหรือไม่สมเหตุผลเท่านั้นจึงสามารถกระทำได้ ในขณะที่หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสไม่ได้ให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายเอกชนในการแก้ไขสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาเท่าเทียมกับฝ่ายปกครอง เพราะคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไปเพื่อรักษาความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะแม้ว่าฝ่ายปกครองจะไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็ไม่สามารถใช้หลักต่างตอบแทนเพื่อปฏิเสธการปฏิบัติตามสัญญาได้

อย่างไรก็ตาม มีหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสและเยอรมันประการหนึ่งที่จะคล้ายคลึงกัน ก็คือ ฝ่ายปกครองของเยอรมันสามารถบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้หากจำเป็นต้องรักษาประโยชน์สาธารณะและขจัดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่จะเกิดต่อสังคม ในขณะที่ฝ่ายปกครองของฝรั่งเศสสามารถใช้เอกสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะมีได้กระทำผิดสัญญา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ประโยชน์สาธารณะถูกระทบกระเทือน โดยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองของเยอรมันและของฝรั่งเศสในส่วนของการใช้สิทธิบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจหลายประการด้วยกัน ดังนี้

ประการแรก โดยภาพรวมแล้ว หลักกฎหมายปกครองและสัญญาทางปกครองของทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันต่างให้ความสำคัญแก่การบริการสาธารณะ เพียงแต่ดูเหมือนว่าแนวคิดของฝรั่งเศสจะเน้นหลักว่าประโยชน์มหาชนต้องมาก่อนและมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากทฤษฎีบริการสาธารณะที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศส ในขณะที่สัญญาทางปกครองของเยอรมันจะพยายามให้น้ำหนักกับทั้งประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยควบคู่กัน คำกล่าวเช่นนี้ดูมิได้เกินไปจากความจริงเมื่อปรากฏว่าเยอรมันยังยึดมั่นในหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา โดยคู่สัญญาต่างเคารพในหลักการแสดงเจตนาและหลักสัญญาต่างตอบแทนมาโดยตลอด และสัญญาต่างตอบแทนยังเป็นสัญญาประเภทหนึ่งในสัญญาทางปกครองของเยอรมัน แต่ฝรั่งเศสกลับมิได้ใช้หลักสัญญาต่างตอบแทนในสัญญาทางปกครอง เพราะจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นลำดับแรกด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาในแง่กฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้แก้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองปรากฏว่าฝรั่งเศสมีหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองที่วางหลักเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไว้อย่างกว้างขวาง ในขณะที่แนวกฎหมายปกครองของเยอรมันมีบทบัญญัติในเรื่องสัญญาทางปกครองน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบทบัญญัติเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองและยังนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้กับสัญญาทางปกครองในฐานะเป็นบทเสริม ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสได้ปฏิเสธหลักทางแพ่งหลายเรื่องด้วยกัน เช่น

หลักต่างตอบแทน หลักการบอกเลิกสัญญา หลักการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยต้องได้รับความยินยอมของคู่สัญญาสองฝ่าย หลักการชำระหนี้เป็นพันวิสัย เป็นต้น

ประการที่สอง แนวคิดของฝรั่งเศสเห็นว่าภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการจัดให้มีการบริการสาธารณะและรักษาความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ โดยรัฐจะเข้ามามีอิทธิพลผลักดันให้การบริการสาธารณะดำเนินต่อไป ในขณะที่เดียวกันก็พยายามของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเอาไว้ด้วย ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากฝรั่งเศสมี “หลักดุลยภาพทางการเงิน” เมื่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชนประสบปัญหาด้านการเงินที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดทางธุรกิจเนื่องจากต้องแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะให้เป็นผลสำเร็จ รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงให้ความช่วยเหลือ กรณีนี้แสดงให้เห็นบทบาทของรัฐที่มุ่งรักษาความต่อเนื่องของการจัดทำบริการสาธารณะและเพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุผลได้อย่างเด่นชัด ในขณะที่เยอรมันจะให้ความสำคัญแก่การบริการสาธารณะควบคู่กับประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน จึงพยายามใช้อำนาจรัฐเข้าแทรกแซงน้อยและปล่อยให้กลไกทางกฎหมายทำหน้าที่โดยตัวของมันเองในการเข้าควบคุมและบังคับให้คู่สัญญาต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย โดยไม่มีความสุดโต่งในการนำเรื่องการบริการสาธารณะเข้ามาเป็นปัจจัยในการบริหารสัญญา ในขณะที่รัฐจะคอยควบคุมดูแลทั้งประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนให้ดำเนินไปด้วยกันอย่างเหมาะสม จนทำให้ดูเหมือนว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนของเยอรมันไม่ต้องแบกรับภาระมากดังเช่นกรณีของฝรั่งเศส

ประการที่สาม ในเรื่องการให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองเหนือกว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชน ตามแนวคิดของฝรั่งเศสก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างจากแนวคิดของเยอรมัน เนื่องจากตามกฎหมายปกครองของเยอรมัน ฝ่ายปกครองในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองสามารถมีอิทธิพลต่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้เท่าที่อยู่ภายในขอบเขตของหลักความชอบด้วยกฎหมายหรือเท่าที่ไม่ขัดต่อบทกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายปกครองของเยอรมันมีความเคร่งครัดและจำกัดกรอบอำนาจของฝ่ายปกครองอย่างมากเมื่อเทียบกับกฎหมายปกครองของฝรั่งเศส นอกจากนี้ การที่ฝรั่งเศสสร้างหลักเรื่องความสำคัญสูงสุดของประโยชน์สาธารณะยังทำให้ฝ่ายปกครองสามารถบริหารสัญญาไปในทิศทางที่ขัดแย้งกับข้อสัญญาได้ เช่น การแก้ไขข้อสัญญาได้ฝ่ายเดียวหรือการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ฯลฯ ในขณะที่หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของเยอรมัน ฝ่ายปกครองจะบอกเลิกสัญญาได้แต่เฉพาะในกรณีที่จะเกิดภัยอันตรายร้ายแรงต่อสังคมและการ เลิกสัญญาก็เพื่อจัดความเสียหายดังกล่าวเพียงประการเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการแก้ไขสัญญา โดยทั่วไปทั้งฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสัญญาได้ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเมื่อบ่อเกิดแห่งหนี้ตามสัญญาลิ้นไปหรือไม่มีความหมายรองรับข้อกำหนดให้ต้องชำระหนี้ตามสัญญาอีกต่อไป จากหลักการแก้

ไขข้อสัญญา และการบอกเลิกสัญญาของเยอรมันและของฝรั่งเศสที่แตกต่างกันดังกล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นได้ว่าเยอรมันมีหลักกฎหมายในทั้งสองเรื่องดังกล่าวที่เข้มงวดมากกว่าของฝรั่งเศส

ประการที่สี่ แนวคิดของเยอรมันเรื่องการเข้าเป็นคู่สัญญาทางปกครอง มีหลักว่าคู่สัญญาจะต้องทราบตั้งแต่ขณะเข้าทำสัญญาแล้วว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะผูกพันกันตามสัญญาทางปกครองซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และเนื้อหาของสัญญาจะมีการให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ฝ่ายปกครองที่ต่างจากทางแพ่ง โดยคู่สัญญาไม่อาจเลือกโดยเจาะจงลงไปว่าจะทำสัญญาเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง ในขณะที่แนวคิดของฝรั่งเศส ฝ่ายปกครองสามารถพิจารณาเลือกได้ว่าตนประสงค์จะทำสัญญาภายใต้ระบบกฎหมายเอกชนเช่นเดียวกับที่เอกชนทำสัญญาระหว่างกัน ที่เรียกว่า “สัญญาของฝ่ายปกครองที่เป็นไปตามกฎหมายเอกชน” หรือจะทำสัญญาภายใต้ระบบกฎหมายปกครองที่เรียกว่า “สัญญาทางปกครอง”^{๔๗}

ประการที่ห้า ตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของเยอรมันมีการแบ่งประเภทหลักๆ ของสัญญาทางปกครองออกเป็นสัญญาต่างตอบแทนและสัญญาประโยชน์ประนอม ในขณะที่ฝรั่งเศสจะใช้หลักต่างตอบแทนกับเฉพาะบางสัญญาเท่านั้น เช่น สัญญาการโยธาสาธารณะ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสจะมีข้อพิพาทกว่าของเยอรมันตรงที่มีการแบ่งลักษณะของสัญญาทางปกครองออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้แก่ สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดและสัญญาทางปกครองโดยสภาพ

ประการที่หก ทั้งกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสและของเยอรมันต่างมีหลักเรื่องการบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาโดยฝ่ายปกครอง ซึ่งในกฎหมายปกครองของเยอรมันเรียกว่า “การใช้สิทธิบังคับการตามสัญญาทางปกครองโดยทันที” ของฝ่ายปกครอง หลักดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนกระทำผิดสัญญา ฝ่ายปกครองสามารถใช้สิทธิบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาได้ในเบื้องต้นโดยการออกเป็นคำสั่งทางปกครอง เช่น การเรียกค่าปรับ การเรียกค่าเสียหาย ทำให้ไม่ต้องนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองโดยทันที

ประการที่เจ็ด การนำคดีเข้าสู่ศาล ด้วยคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อสัญญา การตีความ การปฏิบัติตามสัญญา การปรับปรุงแก้ไขสัญญา และการเลิกสัญญา และส่วนที่สอง เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาทางปกครอง หรือจากการปรับปรุงแก้ไขสัญญา หรือจากการเลิกสัญญา ซึ่งศาลปกครองฝรั่งเศสจะมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททั้งสองส่วนนี้

^{๔๗} โปรดอ่านรายละเอียดใน ชาญชัย แสงศักดิ์ “ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครองตามแนวคิดของฝรั่งเศส,” ในอมร จันทรสมบูรณ์, นิติกรรมทางแพ่ง-นิติกรรมทางปกครอง-สัญญาทางปกครอง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๒๙ และนนทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, อ่างแล้ว, หน้า ๒๙๘.

แต่ศาลปกครองเยอรมันจะมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเพียงข้อพิพาทในส่วนแรกเท่านั้น ส่วนข้อพิพาทในส่วนที่สองจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม.

๔. แนวคิดของไทยเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและผลทางกฎหมายของสัญญาทางปกครอง

แต่เดิมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของไทย ดังเช่นการว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของทางราชการตามสัญญาจ้างก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัญญาประเภทที่รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งที่จะเสนอผลการศึกษา จะต้องจัดทำตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งปัจจุบันคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (บางครั้งเรียกว่า “สัญญาพัสดุ”) เมื่อส่วนราชการมีคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างจะต้องนำไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม โดยในการพิจารณาคดี นอกจากศาลจะพิจารณาเนื้อหาของข้อสัญญาในสัญญาจ้างก่อสร้างที่จัดทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเป็นส่วนราชการฝ่ายหนึ่งและเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ยังมีการนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้แก่คดีควบคู่กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ จนทำให้เข้าใจไปได้ว่าสัญญาจ้างก่อสร้างก็เป็นสัญญาทางแพ่งด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ส่วนราชการต้องการจัดจ้างผู้รับจ้างเอกชนโดยมีการยกร่างสัญญาที่มีเนื้อหาแตกต่างไปจากแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ก็จะต้องส่งร่างสัญญานั้น ๆ ไปหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนดำเนินการจัดทำสัญญากับเอกชนต่อไป จากสภาพการณดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ กฎหมายไทยยังไม่มีหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเพื่อใช้บังคับในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างที่เป็นของตนเอง หรือแม้แต่สัญญาสัมปทานที่ดูจะมีพัฒนาการมายาวนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็อยู่ในสถานะเดียวกัน จนกระทั่งเมื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลปกครองได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว จึงเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในแง่ของเขตอำนาจศาลเหนือคดี โดยในส่วนของสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค กฎหมายกำหนดให้เป็นสัญญาทางปกครองประเภทหนึ่งตามนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประเภทนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้เริ่มปรากฏความชัดเจนว่าหลักเรื่องสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายมหาชนได้แยกตัวออกจากระบบกฎหมายเอกชนอย่างชัดเจนและคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังเช่น สัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือฝ่ายปกครองกับ

เอกชนซึ่งเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะและประโยชน์สาธารณะ จะไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอีกต่อไป เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสมาใช้ดังได้กล่าวมาแล้วว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของฝรั่งเศสจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อสัญญา การตีความสัญญา การปฏิบัติ ตามสัญญา การเลิกสัญญา ตลอดจนการเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ในระบบกฎหมายปกครองของไทยก็ใช้หลักเดียวกันนี้ กล่าวคือ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองทั้งหมด ทั้งในส่วนที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา เช่น ข้อสัญญา การตีความ การปฏิบัติตามสัญญา การเลิกสัญญา เป็นต้น และข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายหรือการสั่งให้ใช้เงิน ซึ่งแตกต่างจากหลักกฎหมายปกครองของเยอรมันที่กำหนดให้ประเด็นพิพาทเกี่ยวกับข้อสัญญา การตีความสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา และการ เลิกสัญญาอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายจะอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม แต่ในแง่ของข้อกฎหมายที่บังคับใช้แก้คดีนั้น นอกจากศาลปกครองเยอรมันจะใช้กฎหมายปกครองเยอรมันเป็นหลักแล้ว ยังใช้ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันมาเสริมอีกทางหนึ่งด้วย ลักษณะดังกล่าวจึงนับว่ามีความคล้ายคลึงกับการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของศาลปกครองไทยในช่วงที่ผ่านมาโดยตลอด ทั้งนี้ เนื่องจากระบบกฎหมายไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยสัญญา ทางปกครองเป็นของตนเอง ประกอบกับในอดีตเมื่อคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่จัดทำระหว่างส่วนราชการกับเอกชนถูกฟ้องไปยังศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมก็จะพิจารณาพิพากษาโดยนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้แก้คดี ต่อมาเมื่อคดีพิพาทประเภทนี้มาอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลปกครองก็ใช้ทั้งหลักกฎหมายปกครอง ข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อสัญญาในแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมทั้งยังมีการนำหลักกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก้คดีโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายมหาชนอีกด้วย^{๔๔} นอกจากนั้น ในส่วนของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ก็มีการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกัน ดังนั้น ในกรณีของไทย แม้จะมีความชัดเจนในเรื่องการแบ่งเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคให้เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง แต่ในแง่ผลทางกฎหมายของสัญญาทางปกครอง โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา

^{๔๔} โปรดอ่านในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒/๒๕๔๖ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้เอี่ยมจวน ต้นหยงมัส กับ กรมอนามัย ในสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชนนั้น ยังต้องพิจารณาไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕^{๔๙} และข้อกำหนดในสัญญาจ้างเป็นสำคัญ ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในบทที่ ๒

สำหรับหลักการอื่นๆ ที่มีการนำมาใช้บังคับกับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการไทย ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองที่มีลักษณะทำนองเดียวกับของต่างประเทศ ได้แก่

ก. การที่ส่วนราชการไทยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและเป็นคู่สัญญาในสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคมีอำนาจควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ ดังเช่น ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่กำหนดว่าในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการในสังกัดหรือข้าราชการในสังกัดอื่นตามที่ได้รับคามยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้นั้นแล้ว ในกรณีที่มีลักษณะของงานก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ ลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นได้ถึงการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองควบคุมการปฏิบัติงานของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของทางราชการ

ข. การที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปฏิบัติตามสัญญาได้เอง ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาโดยมิต้องนำคดีไปสู่ศาลปกครองในทันที เช่น ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ลงมือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนดสัญญา ฝ่ายปกครองอาจจะมีหนังสือเร่งรัดให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเข้าปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งเรียกค่าปรับหรือริบหลักประกันสัญญาได้ดังเช่นที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ^{๕๐} การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท และในวรรคห้า กำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ส่วนราชการริบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญา

^{๔๙} สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๕๐} เหตุผลที่นำข้อ ๑๓๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ มาใช้กับวิธีการเรียกค่าปรับในกรณีผู้รับจ้างเอกชนส่งมอบงานล่าช้าหรือพ้นกำหนดเวลาด้วย นอกเหนือจากการส่งมอบพัสดุ เนื่องจากข้อ ๑๓๔ เป็นข้อเดียวในระเบียบดังกล่าวที่กำหนดเรื่องขั้นตอนและวิธีการเรียกค่าปรับและการแจ้งสงวนสิทธิไว้ และในข้อ ๑๗ ค่าปรับ ตามสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบดังกล่าวก็ได้กำหนดเรื่องขั้นตอนและวิธีการเรียกค่าปรับไว้ หากแต่บัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าปรับไว้ว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท”

ได้ส่งมอบพัสดุฯ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่าไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น นอกจากเรียกให้ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นอีกด้วยก็ได้ และวรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้อยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้แจ้งสงวนสิทธิไว้ในเวลารับชำระหนี้ แต่หากการบังคับการในเบื้องต้นไม่เป็นผล จึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายและอื่นๆ ซึ่งในชั้นนี้ มักจะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยออกคำบังคับให้เนื่องจากสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีผลบังคับระหว่างคู่สัญญาอีกต่อไป โดยข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดว่า ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และวรรคสอง กำหนดว่า การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายเอกชนในสัญญาจ้างก่อสร้าง ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามข้อกฎหมายและข้อสัญญาต่อไปในบทที่ ๒

บทที่ ๒

หน้าที่และสิทธิของคู่สัญญาในสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ศึกษาจากหลักกฎหมาย คำวินิจฉัยของศาลฎีกา และคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด)

๑. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาจ้างทำของที่มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยมีผู้ว่าจ้าง คือ ฝ่ายปกครอง และผู้รับจ้าง คือ นิติบุคคลเอกชน ตกลงจัดทำสัญญาระหว่างกัน ด้วยใจสมัครและมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าตอบแทนหรือให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น ส่วนผู้รับจ้างมีหน้าที่ทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจนสำเร็จตามข้อตกลง และได้รับสินจ้างจากผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนก็จะ ต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้น ลักษณะดังที่กล่าวมานี้มีพื้นฐานมาจากความผูกพันในหนี้ ซึ่งหนี้ตามกฎหมายโรมันเป็นความผูกพันตามกฎหมายในสองลักษณะ คือ หน้าที่ (debitum) และความรับผิดชอบ (obligatio) โดยหน้าที่เป็นความผูกพันในการปฏิบัติภาระหนี้ที่ต้องกระทำตามมูลหนี้โดยปกติ เช่น สัญญาซื้อขาย ผู้ขายมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้ผู้ซื้อ ส่วนผู้ซื้อ มีหน้าที่ชำระราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย เป็นต้น หน้าที่เป็นความผูกพันที่มีต่อดังบุคคลของผู้ที่เป็นลูกหนี้ที่จะต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอันใดอันหนึ่งตามมาตรา ๑๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนความรับผิดชอบเป็นความผูกพันในลักษณะของการถูกบังคับให้ชำระหนี้และการชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามปกติในการชำระหนี้^{๔๑} ทั้งนี้ การที่ลูกหนี้จะปฏิบัติตามภาระหนี้ตามที่ตนมีหน้าที่ผูกพันหรือไม่เป็นเรื่องของความสมัครใจของลูกหนี้เอง แต่ถ้าลูกหนี้เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าผิดสัญญาผลที่ตามมา ก็คือ นอกจากจะทำให้ลูกหนี้ไม่ได้รับสิทธิตามสัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติตามภาระหนี้ตามหน้าที่ของตนแล้ว กลับจะต้องมีความรับผิดชอบแทน

กรณีการไม่ชำระหนี้ตามสัญญานี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ธีระวัฒน์ ได้อธิบายว่า มี “ผลสามประการ ประการแรก คือ การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาเจาะจงในกรณีที่สามารถบังคับได้ ประการที่สอง คือ การใช้สิทธิเลิกสัญญาในกรณีเป็นสัญญาต่างตอบแทน ประการสุดท้าย คือ การบังคับโดยการชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าหนี้อันเป็นความรับผิดชอบทางสัญญา... และความรับผิดชอบทางสัญญามีวัตถุประสงค์สองประการ คือ ประการแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ตามสัญญาที่ตกลงไว้ ประการที่สอง เพื่อการชดเชยค่าเสียหาย ความเสียหายตามสัญญาก็คือ การสูญเสียประโยชน์ที่เจ้าหนี้ควรได้รับตามสัญญาหากลูกหนี้สมัครใจชำระหนี้ นั่น เช่น การชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากการส่งมอบชำรุดบกพร่องไม่เป็นไปตาม

^{๔๑} ดาราพร ธีระวัฒน์, “หลักและขอบเขตความรับผิดชอบทางสัญญา,” อาจารย์บุชา หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๓๘, หน้า ๓๖๘.

สัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นต้น”^{๕๒} นอกจากการชดเชยความเสียหายแล้ว ยังมีเรื่องการใช้สิทธิเรียก เบี้ยปรับตามที่คู่สัญญาดตกลงกัน ซึ่งเป็นข้อสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดค่าเสียหาย ไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ลูกหนี้อาจไม่ชำระหนี้ในภายหลังหรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง ข้อสัญญาเรื่องเบี้ยปรับ จะมีผลบังคับได้เมื่อสัญญาไม่เป็นโมฆะหรือใช้ไม่ได้เช่นเดียวกับสัญญาอื่นๆ ตามมาตรา ๓๘๔^{๕๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับผลของการที่ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างนี้จะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป

๑.๑ หน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ในส่วนของสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างตาม สัญญาจ้างก่อสร้างนั้น จะต้องพิจารณาตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “อันว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจะ ทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” และผู้ว่าจ้างตกลงจะ ให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น” แต่ถ้างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างชำรุดบกพร่อง หรือส่งมอบล่าช้า ผู้ว่าจ้างย่อมยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ตามมาตรา ๕๘๘^{๕๔} แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ โดยเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาและผลสำเร็จของผลงานจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ สัมพันธ์กับการตัดสินใจว่าควรจ่ายสินจ้างหรือไม่ เพราะโดยทั่วไปผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จ่ายสินจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันโดยสินจ้างอาจจะเป็นเงินตราหรือทรัพย์สิน อย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ปรากฏดังตัวอย่างเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตามคำพิพากษากฎีกา ต่อไปนี้

- กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างยอมปฏิเสธไม่รับมอบ งานได้ โดยผู้รับจ้างจะอ้างว่ากรรมการตรวจงานของผู้ว่าจ้างไม่ทั่วถึงไม่ได้ แต่เมื่อสภาพของ ถนนแข็งแรงพอใช้ได้และผู้ว่าจ้างก็ยินยอมจะรับถนนไว้โดยการลดสินจ้างลง ประกอบกับผู้รับจ้าง ได้เปิดถนนให้ประชาชนใช้แล้วโดยผู้ว่าจ้างมิได้ทักท้วงแต่ประการใด ถือได้ว่าถนนที่ผู้รับจ้างก่อ สร้างตามสัญญาเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงต้องรับการก่อสร้างตามสัญญาไว้และ ใช้สินจ้างตามสมควร (คำพิพากษากฎีกาที่ ๑๒๙๗/๒๕๒๓)

- กรณีที่ผู้รับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลตามสัญญาจ้างให้ผู้ว่าจ้างแล้วแต่ไม่ได้ ปริมาณน้ำตามสัญญา ทำให้สัญญาต้องเลิกกันตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยอม กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้รับจ้างทำงานให้ตามที่ผู้ว่าจ้างจ้างแล้วแต่ไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่ตกลงกันในสัญญา

^{๕๒} ดารารพร ธีระวัฒน์, “หลักและขอบเขตความรับผิดชอบทางสัญญา,” อาจารย์บุชา หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, อ่างแล้ว, หน้า ๓๗๐-๓๗๑.

^{๕๓-๕๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๔ ถ้าการชำระหนี้ตามที่สัญญาไว้นั้นไม่สมบูรณ์ การที่ตกลงกันด้วยข้อเบี่ยงปรับ ในการไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ถึงกันแม้ถึงกรณีจะได้รู้ว่าข้อสัญญานั้นไม่สมบูรณ์

มาตรา ๕๘๘ ในกรณีที่ส่งมอบเงินช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการทำชำรุดบกพร่องก็ดี ท่านว่า ผู้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร

ผู้ว่าจ้างจำต้องใช้เงินเป็นค่าแห่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปให้แก่ผู้รับจ้าง แม้ในสัญญาจะระบุว่าผู้รับจ้างต้องคืนเงินที่รับไปจากผู้ว่าจ้างทั้งหมด แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องใช้ค่าแห่งงานให้ผู้รับจ้างไม่ ซึ่งค่าแห่งงานนี้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควร (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๒๒/๒๕๒๘)

ส่วนกรณีว่าผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเมื่อใดนั้น ต้องพิจารณาตามมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบงานที่ทำ ถ้าการทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วนๆ และได้ระบุจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วนๆ ไซ้รู้กันว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น” ดังนี้ แสดงว่าผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จ่ายสินจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานที่ทำหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว แสดงว่าผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแต่อย่างใด แม้แต่ในกรณีที่เป็นการส่งมอบงานเป็นงวดๆ ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินเมื่อรับมอบงานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวดเท่านั้น โดยไม่ต้องชำระล่วงหน้าเช่นกัน นอกจากนี้ ในแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก็ยังมีข้อสัญญาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่สอดคล้องกับมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังปรากฏความในข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)^{๔๕} ซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง และในข้อ ๔ ข.^{๔๖} ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ได้กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ โดยงวดสุดท้ายจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

^{๔๕-๔๖} แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ฯลฯ

ฯลฯ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา

ฯลฯ

ฯลฯ

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ฯลฯ

ฯลฯ

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน..... บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

อย่างไรก็ตาม โดยที่บทบัญญัติตามมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่ว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น คู่สัญญาอาจตกลงยกเว้นเป็นอย่างอื่นได้ ดังเช่น ในสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ที่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการชำระค่าจ้างพิเศษออกไปจากกรณีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะได้กำหนดให้หน่วยราชการผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนได้ แม้ผู้ว่าจ้างจะยังไม่ได้รับมอบงาน แต่ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยปรากฏตามความในข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า^{๕๗} ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น

๑.๒ หน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้างเพราะหวังได้สินจ้างเป็นผลตอบแทน ซึ่งตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า อันว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ไม่เพียงผู้รับจ้างต้องทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเท่านั้น แต่งานที่ทำนั้นจะต้องสำเร็จตรงตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างด้วย หากงานแล้วเสร็จแต่ไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ก็ไม่เข้าตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น หน้าที่ของผู้รับจ้างจึงอาจสรุปได้ ดังนี้

๑.๒.๑ ต้องทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและทำงานด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามมาตรา ๕๘๓^{๕๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

^{๕๗} แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินบาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มจำนวนตามจำนวนเงินค่าจ้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทันที

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการภายในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้ มีพักต้องรอคอยให้ถึงกำหนดเวลาส่งมอบของนั้นเลย

พาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและสัมภาระต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานให้เป็นผลสำเร็จตามมาตรา ๕๕๘^{๕๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑.๒.๒ ต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างตรวจงานได้ตามมาตรา ๕๕๒^{๖๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับจ้างเอง เพราะหากผู้ว่าจ้างได้ตรวจพบความบกพร่องไม่ตรงตามสัญญาหรือทำงานล่าช้าก็จะได้แจ้งหรือเตือนให้ผู้รับจ้างทำให้ถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเมื่อส่งมอบงาน

๑.๒.๓ ต้องรับผิดชอบในงานที่ชำรุดบกพร่องหรือฝ่าฝืนข้อสัญญาระหว่างการทำงาน ในเรื่องนี้กฎหมายตามมาตรา ๕๕๔^{๖๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างที่จะแจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขงานที่ได้ทำในระหว่างสัญญาได้หากตรวจพบว่างานนั้นทำไปโดยบกพร่อง เพราะหากปล่อยให้ผู้รับจ้างทำต่อไปก็จะทำให้ผลงานที่เสร็จมีความบกพร่องในท้ายที่สุด

๑.๒.๔ ต้องส่งมอบงานโดยไม่ชักช้า ซึ่งมาตรา ๕๕๖^{๖๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะถ้ากำหนดเวลาการส่งมอบงานเป็นสาระสำคัญของสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ ทั้งนี้ ในส่วนความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในกรณีนี้จะมีมากน้อยเพียงใด ต้องพิจารณาจากข้อสัญญาจ้างด้วย เช่น ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๗ ข.^{๖๓}

๕๙-๖๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๕๘ เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา

มาตรา ๕๕๒ ผู้รับจ้างจำต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานได้ตลอดเวลาที่ทำงานนั้น

มาตรา ๕๕๔ ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาดหมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือจะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซ้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดไว้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไป ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซมหรือทำต่อไปได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสียความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

มาตรา ๕๕๖ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญาเมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างลง หรือถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้

๖๓ แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

กำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานให้ลุล่วงไปได้ด้วย ทั้งนี้ การใช้สิทธิเลิกสัญญาจ้างไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญา หากแต่จะมีผลให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่พร้อมด้วยค่าเสียหายอื่นๆ และในข้อ ๑๗^{๖๔} ของแบบสัญญาจ้างดังกล่าวยังกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ เบี้ยปรับดังกล่าวจะเป็นการตกลงกันล่วงหน้าระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างว่า หากผู้รับจ้างผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างนั่นเอง

๑.๒.๕. ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานที่ทำภายหลังการส่งมอบ โดยทั่วไปผู้ว่าจ้างย่อมไม่ประสงค์ที่จะจ่ายสินจ้างให้แก่ผู้รับจ้างหากงานที่ส่งมอบปรากฏความชำรุดบกพร่องอย่างแน่นอน เนื่องจากเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ่ายสินจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลงานที่จัดทำแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างย่อมต้องหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นอย่างบริบูรณ์สมควรความมุ่งหมาย หากผลงานบกพร่องก็จะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงกำหนดเรื่องนี้ไว้ในมาตรา ๕๙๑^{๖๕} และมาตรา ๖๐๐^{๖๖} นอกจากนี้

^{๖๔} **แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕**

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

^{๖๕-๖๖} **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

มาตรา ๕๙๑ ถ้าความชำรุดบกพร่องหรือความชักช้าในการทำนั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้ก็ดี เพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างก็ดี ท่านว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่จะได้อำนาจไว้แล้วว่าสมภาระนั้นไม่เหมาะสมหรือว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมีได้บอกกล่าวตักเตือน

มาตรา ๖๐๐ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไว้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อการทำชำรุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการทำนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากโรงเรือนทำด้วยเครื่องมือ

แต่ข้อจำกัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น

ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๘^{๖๗} กำหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นเข้าทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างออกค่าใช้จ่าย

๒. สิทธิของผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

ตามหลักกฎหมายของไทย คู่สัญญาในสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งได้แก่ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต่างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันทั้งตามกฎหมายและข้อสัญญาจ้างดังได้กล่าวมาแล้ว หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาย่อมตกเป็นผู้ผิดสัญญา โดยเฉพาะในส่วนการจัดทำสัญญาจ้างที่ฝ่ายปกครองของไทยใช้อยู่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบดังกล่าว เป็นสำคัญ ส่วนในแง่ของการพิจารณาคดีในช่วงที่ศาลปกครองยังไม่เปิดทำการ ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ โดยพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ควบคู่กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และข้อสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อหน่วยงานทางปกครองมีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ และต้องการทราบว่าเป็นทางกฎหมายสมควรจะต้องถือปฏิบัติต่อกรณีดังกล่าวอย่างไร ก็จะมีการหารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วย ต่อมาหลังจากที่ศาลปกครองเปิดทำการแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ แม้โดยนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการจะเข้าลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันมีผลทำให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาข้างต้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่การวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวเท่าที่ผ่านมา ศาลปกครองได้นำหลักกฎหมาย

^{๖๗} แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด.....ปีเดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งข้อกำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งศาลยุติธรรมใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวมาแต่เดิม มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยข้อพิพาทร่วมกับหลักกฎหมายปกครองด้วย ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ว่าจ้างในกรณีที่เอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของรายงานงานการศึกษาฉบับนี้ จึงได้มีการหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งใช้หลักกฎหมายบางส่วนในทำนองเดียวกับที่ศาลปกครองใช้วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างประกอบการศึกษาไว้ในบทนี้ด้วย ส่วนตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

ทั้งนี้ ในการศึกษาคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างนั้น อาจสรุปสิทธิต่างๆ ของผู้ว่าจ้างได้ ดังนี้

๒.๑ สิทธิเรียกร้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง

แม้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมีหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายจะได้บัญญัติครอบคลุมรายละเอียดปลีกย่อยไว้ทั้งหมด หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างประสงค์จะตกลงกันให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนด ก็ย่อมกระทำได้ หากการนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน^{๖๔} ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงสามารถจัดทำข้อสัญญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมโดยสมัครใจของทั้งสองฝ่ายได้ อันเป็นเจตนารมณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ตลอดเวลา หรือในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อสัญญาบางข้อเพื่อให้มีความชัดเจน รัดกุม และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ส่วนราชการก็สามารถจัดทำร่างสัญญาใหม่ให้แตกต่างจากแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้ แต่จะต้องส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบก่อน ดังนั้น ส่วนราชการผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิเรียกร้องในเรื่องใดได้ เรื่องนั้นจึงต้องมีการกำหนดไว้ในข้อสัญญาและมีกฎหมายรองรับ ซึ่งโดยปกติสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ได้รับการบรรจุไว้ในสัญญาจ้างมีดังนี้

๒.๑.๑ กรณีที่ยังไม่มีการบอกเลิกสัญญาจ้างทันทีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า
อันเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างออกไป ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างมีการรับมอบงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้นไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ดังนี้

^{๖๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพนันวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

๑) สิทธิในการเรียกค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๓๔ วรรคท้าย ประกอบกับข้อ ๑๓๘^{๖๙} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบฯ ข้อ ๑๗^{๗๐} ที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเรียกร้องได้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญาจ้างหรือยังไม่ประสงค์บอกเลิกสัญญาจ้างทันที ผู้ว่าจ้างจะแจ้งการใช้สิทธิเรียกค่าปรับในตอนรับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจะต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ในช่วงที่มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามคำร้องขอของผู้รับจ้างเพื่อใช้สิทธิปรับในช่วงเวลาภายหลังจากที่ครบระยะเวลาตาม que ผู้ว่าจ้างขยายให้แล้ว แต่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

๒) สิทธิเรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในช่วงที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

๓) สิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกินกว่าจำนวนเงินในหลักประกันสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๔) สิทธิในการรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

การใช้สิทธิตามข้อ ๑) ถึงข้อ ๔) เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดสัญญา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากผู้ว่าจ้างรับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว หากงานดังกล่าวมีความบกพร่องหรืองานนั้นมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากผู้ว่าจ้างได้แจ้งผู้รับจ้างรายอื่นเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามข้อ ๘ ของแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ^{๗๑} โดยการใช้สิทธิในกรณีหลังนี้เป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่เข้าแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องนั้นๆ เอง แต่ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

๒.๑.๒ กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา อันเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างในทันทีที่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง แต่ได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยมีการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไว้ ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้อย่างแน่นอนแล้ว จึงบอกเลิก

^{๖๙} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๔

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรับแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

^{๗๐} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๖๔ หน้า ๔๑

^{๗๑} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๖๗ หน้า ๔๒

สัญญาในที่สุด กรณีหนึ่ง กับอีกกรณีหนึ่ง ได้แก่ กรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา และได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปตามคำร้องขอของผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จจนล่วงเลยกำหนดเวลาที่ขยายออกไปดังกล่าว ผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไว้ในช่วงที่ผู้รับจ้างทำงานล่วงเลยกำหนดเวลาที่ขยายให้ก่อนที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิดังนี้

- ๑) สิทธิเรียกค่าปรับ
 - ๒) สิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
 - ๓) สิทธิเรียกค่าเสียหายที่มีจำนวนเกินกว่าหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา
 - ๔) สิทธิเรียกค่าควมคุมงานเพิ่มในกรณีที่มีการจ้างผู้ควบคุมงาน
 - ๕) สิทธิเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยมีค่าจ้างส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
 - ๖) สิทธิในการเข้าครอบครองและใช้ประโยชน์จากงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน
 - ๗) สิทธิในการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างที่ยังอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
- การใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามข้อ ๑) ถึงข้อ ๗) จะมีได้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วและมีค่าเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเมื่อตกเป็นผู้ผิดสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙^{๗๒}
- แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาในทันทีที่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิเรียกร้องได้เฉพาะตามข้อ ๒) ถึงข้อ ๗) เท่านั้น โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าปรับตาม

^{๗๒} **แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕**

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑) เพราะการบอกเลิกสัญญาทันทีทำให้ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วจึงเรียกค่าปรับไม่ได้

๒.๒ สิทธิเรียกค่าปรับ

“ค่าปรับ” เมื่อมีการผิดสัญญา ก็คือ “เบี้ยปรับ” ตามกฎหมาย^{๗๓} ซึ่งเป็นคำสินไหมทดแทนความเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้า (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๘/๒๔๙๖) หรือค่าปรับรายวันตามสัญญาจ้างก็เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๑๖/๒๕๓๘) แม้มีข้อตกลงเกี่ยวกับเบี้ยปรับกันไว้ แต่ก็มีได้บังคับโดยเด็ดขาดว่าจำนวนเบี้ยปรับจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อศาลเห็นว่าเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวสูงเกินส่วน ศาลย่อมให้ลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๗๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๙๙/๒๕๓๖) ค่าปรับจึงเป็นเงินที่คู่สัญญาจ่ายเพื่อชดเชยให้แก่กันหากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมิชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าปรับ เงินประกันความเสียหาย ฯลฯ หากเงินเหล่านี้เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก็เป็นเบี้ยปรับทั้งสิ้น ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ธีระวัฒน์ ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า “เบี้ยปรับเป็นการกำหนดหรือประเมินความเสียหายที่จะเกิดจากการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของคู่สัญญาที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่า ถ้าไม่ปฏิบัติตามหนี้คือ ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง เจ้าหนี้จะเสียหายเท่าใด ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าการกำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้าเช่นนี้ ค่าเสียหายที่กำหนดนั้นอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดแก่เจ้าหนี้ กฎหมายจึงมีหลักให้เจ้าหนี้สามารถเรียกค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ถ้าเจ้าหนี้พิสูจน์ได้ว่ามีค่าเสียหายมากกว่าเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๓๘๑ วรรคสอง”^{๗๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือในกรณีตรงกันข้าม

^{๗๓} จิตติ เจริญฉ่ำ เห็นว่า ถ้อยคำในสัญญา “ค่าปรับ” และ “เบี้ยปรับ” นั้น จะเรียกว่าอะไรไม่สำคัญ ข้อสำคัญอยู่ที่ความมุ่งหมายอันแท้จริงของคู่สัญญาซึ่งปรากฏในสัญญานั้น ข้อสัญญาที่ว่าจะใช้ค่าเสียหายวันละ ๕ บาท นั้น ก็พอถือได้ว่าเป็นข้อสัญญาให้เสียเบี้ยปรับวันละ ๕ บาท (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๑/๒๔๙๒) (จิตติ เจริญฉ่ำ, “ข้อตกลงที่ให้รับเอาผลงานที่ทำไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๖ (เมษายน ๒๕๓๘), หน้า ๕๐-๕๑.)

^{๗๔-๗๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้

มาตรา ๓๘๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ถ้าลูกหนี้นำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้ว่าความจริงการไม่ปฏิบัติตามชำระหนี้ของตนก่อให้เกิดความเสียหายไม่มากเท่ากับเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ถ้าเป็นจริงศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงได้ตามมาตรา ๓๘๓^{๗๖} โดยส่วนใหญ่สัญญาที่คู่สัญญาจัดทำขึ้นโดยมีข้อตกลงให้มีเบี้ยปรับ^{๗๗} มักถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้เป็นสาระสำคัญ จึงมีการกำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จไว้เป็นการแน่นอนโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และใช้ต้นทุนสูง การกำหนดเบี้ยปรับก็เพื่อบังคับและติดตามให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างทางด่วน สัญญาจ้างก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน สัญญาจ้างก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา จะมีทั้งหลักกฎหมายและข้อสัญญาให้สิทธิผู้ว่าจ้างในการเรียกค่าปรับ แต่สิ่งสำคัญในการเรียกค่าปรับก็คือ จะต้องเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดเสียก่อน หากผู้รับจ้างยังไม่ผิดนัด ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าหนี้อย่อมไม่สามารถเรียกเอาค่าปรับได้ดังที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗๙^{๗๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๗^{๗๙} ค่าปรับ ทั้งนี้ การเรียกเบี้ยปรับอาจเรียกได้ทั้งในรูปของตัวเงินตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการเรียกเบี้ยปรับเป็นสิ่งของอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินตามมาตรา ๓๘๒^{๘๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ได้ ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ฟ้องผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่ทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำให้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าก่อสร้างไปแล้วบางส่วน

^{๗๖} ดารารพร ธีระวัฒน์, “หลักและขอบเขตความรับผิดทางสัญญา,” อาจารย์บุชา หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๓.

^{๗๗} ในประเด็นที่ว่าจะมีการเรียกค่าปรับได้ต้องเป็นกรณีที่มีการตกลงเรื่องค่าปรับไว้ล่วงหน้าหรือไม่ นั้น เสนีย์ ปราโมช อธิบายว่า แม้ในข้อสัญญาไม่มีการตกลงเรื่องค่าปรับไว้ล่วงหน้า ก็มีใ้ว่าคู่สัญญาจะไม่มีสิทธิเรียกร้องแต่ประการใด เนื่องจากตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซ้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้ ซึ่งหมายความว่า (ลูกหนี้) ไม่ยอมชำระหนี้เสียเลยหรือมีการชำระหนี้แต่ชำระหนี้ล่าช้าผิดเวลาหรือมีการชำระหนี้แต่ผิดความประสงค์แห่งหนี้ คือ ผิดสถานที่และวัตถุประสงค์ (โปรดอ่านใน เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๒, สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๐๕, หน้า ๖๗๐.)

^{๗๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๗๙ ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ก็ให้รับเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้อื่นจะพึงทำนั้นได้แก่ดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้รับเบี้ยปรับเมื่อนั้น

^{๗๙} โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖๔ หน้า ๔๑

^{๘๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๒ ถ้าสัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นให้เป็นเบี้ยปรับไม่ใช่ใช้เป็นจำนวนเงินไซ้ ทานให้นับตามบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ มาใช้บังคับ แต่ถ้าเจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็เป็นอันขาดไป

คงเหลือผลงานที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้รับเงินอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งตามสัญญามีข้อตกลงให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้วได้ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ มิได้ กรณีนี้ศาลวินิจฉัยว่าค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันไว้ นั้น ถือได้ว่าเป็นเบี้ยปรับเพื่อการที่จะชดใช้หรือบรรเทาความเสียหายอันอาจจะมีหรือเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า ถ้าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓^{๔๑} และข้อตกลงให้ผู้ว่าจ้างริบเอาผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้ว โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ มิได้ ก็เป็นข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นการที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นที่มีใช้จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ว่าจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๒ ถ้าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจ ลดลงให้เหลือเป็นจำนวนพอสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ ได้เช่นกัน แม้สิทธิรับผลงานที่ผู้รับจ้างทำไปแล้วเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างหลังจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แต่เมื่อถือว่าเป็นเบี้ยปรับเช่นเดียวกับค่าปรับ ศาลจึงนำมาเป็นข้อวินิจฉัย ลดค่าปรับได้หากเห็นว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับเบี้ยปรับสูงเกินส่วน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๖/๒๕๓๗) (สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับเป็นผลงานที่มีใช้ตัวเงินนี้จะได้มีการกล่าวถึงต่อไปในเรื่องการให้งานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างตามข้อสัญญาจ้างในหน้า ๘๗ ด้วย)

แม้ข้อตกลงให้ผู้ว่าจ้างริบเอาผลงานเป็นเบี้ยปรับเป็นสิ่งที่ทำได้ตามมาตรา ๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นให้เป็นเบี้ยปรับที่มีใช้เป็นจำนวนเงิน โดยมาตรา ๓๘๒ บัญญัติให้นำบทบัญญัติมาตรา ๓๗๙ ถึงมาตรา ๓๘๑ มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวด้วยก็ตาม แต่ก็มิให้ผู้ให้ข้อสังเกตว่า การบังคับเบี้ยปรับอย่างอื่นที่มีใช้เป็นจำนวนเงินยังมีข้อแตกต่างจากการบังคับเบี้ยปรับที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน เพราะเมื่อบังคับตามมาตรา ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว ยังมีเงื่อนไขสุดท้ายของมาตรา ๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า “ถ้าเจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็เป็นอันขาดไป” ซึ่งจากข้อความที่บัญญัติไว้ดังกล่าวทำให้เกิดข้อเรียกร้องเอาเบี้ยปรับที่มีใช้เป็นเงินที่แตกต่างไปจากเบี้ยปรับที่เป็นเงิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้วยว่าการริบเอาผลงานที่ทำได้แล้วจะถือว่าเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นที่จะเป็นเบี้ยปรับได้เพียงใด เนื่องจากเป็นที่เห็นได้ชัดว่าย่อมไม่มีการเรียกร้องให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นเลย เพราะผลงานที่มีอยู่นั้นเป็นกรณีที่มีการปฏิบัติกันไปตามสัญญา หากไม่มีการผิดสัญญา ผลงานนั้นก็เป็นสิ่งที่ชำระหนี้กันตามสัญญา ไม่ใช่ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นนอกจากสัญญา

^{๔๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

นอกจากกรณีดังกล่าวไว้ในมาตรา ๓๗๙ และ ๓๘๒ ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อบุคคลสัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนกระทำหรืองดเว้นกระทำการอันหนึ่งอันใดนั้นด้วย

ที่จะเป็นเบี้ยปรับได้ เพราะการเรียกเอาเบี้ยปรับนั้นต้องเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นไม่ใช่หนี้ตามสัญญา^{๔๒} ประกอบกับการริบเอาผลงานที่ทำไปแล้วเป็นเบี้ยปรับโดยไม่เรียกรื้อค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ต้องถือว่าสละสิทธิที่จะขอลดเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๘๓ ไว้ก่อนแล้ว การสละสิทธิที่จะขอลดเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๘๓ ไว้ก่อนจึงทำได้เพราะจะฝ่าฝืนสัญญาสละสิทธิมาขอลดไม่ได้^{๔๓} ซึ่งเป็นแนวความเห็นที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ศาลได้วินิจฉัยไว้ตามคำพิพากษาข้างต้นที่ควรต้องมีการศึกษาต่อไปโดยเฉพาะในกรณีที่มีนักกฎหมายบางท่านมีความเห็นว่า หากการริบเอาผลงานที่ทำไปแล้วไม่ใช่เป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่น การริบเอาผลงานที่ทำไปแล้ว ย่อมไม่ใช่เบี้ยปรับ เพราะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นตามสัญญาหรือเป็นผลงานที่มีอยู่แล้วตามสัญญา ไม่ใช่หนี้ที่ลูกหนี้จะต้องชำระเป็นอย่างอื่นในลักษณะของเบี้ยปรับแต่ประการใด และในกรณีเช่นนี้ย่อมไม่มีสิทธิขอลดการริบผลงานตามสัญญา^{๔๔} นี้ได้

ในเรื่องการใช้สิทธิเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้างนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุสำคัญมาจากสองกรณี ได้แก่

ก. กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ซึ่งหมายถึงกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เลยและได้มีข้อสัญญากำหนดเบี้ยปรับในกรณีนี้ไว้ กรณีนี้หากเรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้อีกไม่ได้ตามมาตรา ๓๘๐^{๔๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะหากกำหนดให้ลูกหนี้ต้องชำระหนี้อื่น รวมทั้งต้องเสียเบี้ยปรับด้วย จะทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบมาก และลูกหนี้จะได้รับความเสียหายมากขึ้น

ข. กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ซึ่งหมายถึงกรณีที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้แล้วแต่ไม่ถูกต้องตามสัญญา ในกรณีนี้ แม้ผู้ว่าจ้างรับมอบงานที่ส่งมอบไว้แล้ว โดยผลทางกฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาได้ และหากมีข้อกำหนดให้เจ้าหนี้เรียกเบี้ยปรับได้ เจ้าหนี้ก็ยังจะเรียกเอาเบี้ยปรับได้

^{๔๒} โปรดอ่านรายละเอียดใน จิตติ เจริญน้ำ “ข้อตกลงที่ให้ริบเอาผลงานที่ทำไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๖ (เมษายน ๒๕๓๘), หน้า ๕๐-๕๑.

^{๔๓} จิตติ เจริญน้ำ, “ข้อตกลงที่ให้ริบเอาผลงานที่ทำไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๕๒ (โดยอ้างอิง เสนีย์ ปราโมช, นิติกรรมและหนี้ (เล่ม ๑), หน้า ๔๒๑).

^{๔๔} จิตติ เจริญน้ำ, “ข้อตกลงที่ให้ริบเอาผลงานที่ทำไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ,” เล่มเดียวกัน, หน้า ๕๒.

^{๔๕} **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

มาตรา ๓๘๐ ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นแทนการชำระหนี้ก็ได้ แต่ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อลูกหนี้ว่าจะเรียกเอาเบี้ยปรับ ฉะนั้นแล้ว ก็เป็นอันขาดสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ต่อไป

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้

อีกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑^{๔๖} ซึ่งการกำหนดจำนวนเบี้ยปรับในลักษณะนี้จะมีจำนวนน้อยกว่าเบี้ยปรับเกี่ยวกับการไม่ชำระหนี้ในข้อ ก. จึงไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน แต่ข้อสำคัญก็คือ หากเจ้าหนี้ชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้เมื่อมีการแจ้งสงวนสิทธิไว้ในเวลาชำระหนี้ ไม่ใช่ภายหลังจากชำระหนี้แล้ว^{๔๗}

สำหรับช่วงเวลาใดหรือเมื่อใดที่เจ้าหนี้หรือผู้ว่าจ้างสามารถเรียกให้ลูกหนี้หรือผู้รับจ้างชำระค่าปรับได้ นั้น มีการอธิบายไว้สองกรณีด้วยกัน ดังนี้

๒.๒.๑ การเรียกเอาค่าปรับในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา (เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดสัญญา แต่ยังไม่มีการบอกเลิกสัญญา) ซึ่งเป็นกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเนื่องจากมีความล่าช้าในการทำงาน กรณีเช่นนี้ถือว่าผู้รับจ้างได้กระทำความผิดสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างได้ผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาออกไปโดยไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพราะผู้ว่าจ้างยังหวังในผลสำเร็จของงาน จึงให้ออกาสผู้รับจ้างทำงานที่จ้างนั้นต่อไป สัญญาจ้างจึงยังไม่เลิกกัน ดังนั้น หากในสัญญาจ้างมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าปรับได้เมื่อมีการผิดข้อสัญญาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างย่อมเรียกเอาค่าปรับนั้นได้ตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ดังนี้

- หากตกลงกันให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้เมื่อไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็มีใช้เป็นบทบังคับว่าจะต้องใช้สิทธิเลิกสัญญาทันทีจึงจะได้ค่าปรับไม่เมื่อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ใช้สิทธินั้น หากแต่ผ่อนผันให้คู่สัญญาอีกฝ่ายตามคำร้องขอด้วยความเห็นใจ หาได้ทำให้หมดสิทธิเรียกค่าปรับในที่สุดไม่ เช่นนี้ย่อมแสดงว่าสิทธิเรียกค่าปรับเนื่องจากการทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาอันเป็นการ

^{๔๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๑ ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่าไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น นอกจากเรียกให้ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นอีกด้วยก็ได้

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนในมูลชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง

ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลาชำระหนี้

^{๔๗} จิตติ เจริญนำ, “พฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับ,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๔ (เมษายน ๒๕๓๗), หน้า ๑๐๒-๑๐๓.

กระทำผิดสัญญากันนั้นยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๘/๒๕๕๖)^{๔๔}

นอกจากการใช้สิทธิปรับเมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้าโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานอันเป็นการปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาได้ด้วยตามมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ดังแผนภาพในหน้า ๑๑๕) ดังนั้น ในการใช้สิทธิเรียกค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาจ้างหรือเป็นการทำงานล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา เมื่อผู้รับจ้างยังคงทำงานตาม ที่ว่าจ้างต่อไป และได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จบริบูรณ์ในเวลาต่อมา ผู้ว่าจ้างก็ต้องใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างในวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานจากผู้รับจ้าง อันจะทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถปรับ ผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ (พร้อมค่าจ้างควบคุมงาน (ถ้ามี)) นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจนถึงวันที่มีการรับมอบงาน ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

- กรมอาชีวศึกษาทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ก่อสร้างอาคารประกอบโรงเรียนรวม ๑๑ รายการ แต่ในบางงวดงานผู้รับจ้างทำงานบางรายการไม่ทันกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างจึงต่ออายุสัญญาให้ แต่ผู้รับจ้างก็ยังทำงานแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรายการหนึ่งรายการใดใน ๑๑ รายการ หรือทั้ง ๑๑ รายการ จึงต้องถูกปรับเป็นรายวันนับแต่วันล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ส่วนกำหนดงวดงานที่แบ่งเป็นงวดตามสัญญาจ้างเป็นการตกลงแบ่งงวดการจ่ายเงิน มิใช่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาซึ่งไม่อาจนำมาคำนวณการปรับผู้รับจ้างตามข้อสัญญาได้ ดังนั้น หากผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันของแต่ละรายการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าวันที่ได้กำหนดไว้เพื่อการจ่ายเงินแต่ละงวดย่อมเป็นการไม่ถูกต้อง กรณีนี้ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิปรับรวมทุกรายการนับแต่วัน

^{๔๔} คัมภีร์ แก้วเจริญ อธิบายว่า สิทธิเลิกสัญญากับสิทธิเรียกเบี้ยปรับตามกฎหมายเป็นคนละเรื่องกัน และสิทธิทั้งสองประการนี้ก็เกิดขึ้นด้วยเหตุผลแตกต่างกัน เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้าล่วงเลยกำหนดส่งมอบงาน ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิเลิกสัญญาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๘ ประกอบมาตรา ๕๙๖ โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน แต่ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับหรือไม่ ต้องดูจากข้อความในสัญญาจ้างนั้นเองว่ากำหนดสิทธิเรียกเบี้ยปรับไว้อย่างไร สัญญาก่อสร้างในระดับมาตรฐานนานาชาติ อย่างเช่น เงื่อนไขสัญญาของ FIDIC (สมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษาสากล) เงื่อนไขสัญญาของ ICE (สถาบันวิศวกรโยธาของอังกฤษ) ฯลฯ ได้กำหนดบทปรับไว้ตามประเพณีการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้างต้น กล่าวคือ กำหนดเบี้ยปรับตามวัตถุประสงค์ของการจ้างก่อสร้างเพื่อเร่งรัดให้ได้ผลงานตามกำหนดเวลาของโครงการ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าก็ถูกปรับจนถึงวันส่งมอบงาน แต่ถ้าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา จะไม่มีหลักให้สิทธิปรับไว้เพราะเป็นคนละเรื่องกันและมีใช้ประเพณีของการจ้างก่อสร้างที่จะปรับผู้รับจ้างเพราะไม่ส่งมอบงาน (โปรดอ่านใน คัมภีร์ แก้วเจริญ วิเคราะห์ข้อหาหรือของกรมอัยการ “เบี้ยปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๙ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๓๑), หน้า ๘๓.

ที่ล่วงเลยกำหนดจนถึงวันที่งานทุกรายการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๑๐๕/๒๕๒๕)^{๔๙}

ในส่วนของการแจ้งสงวนสิทธิปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง นั้น ได้มีแนวปฏิบัติของส่วนราชการดังปรากฏตามความในข้อ ๑๗ ค่าปรับ^{๕๐} ของแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งกำหนดไว้ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง และในระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ ๑๓๔ ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย” คำว่า “ในขณะที่รับมอบพัสดุ” จึงหมายถึง “ในเวลาชำระหนี้” นั่นเอง ซึ่งศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า การบอกสงวนสิทธิ “ในเวลาชำระหนี้” นั้น หมายถึง ในขณะที่มีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิง มิใช่การชำระหนี้เพียงบางส่วน เพราะการที่เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้ไว้บางส่วนไม่ถือเป็นการชำระหนี้เต็มจำนวนที่เจ้าหนี้ต้องสงวนสิทธิปรับ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๘/๒๕๓๖)

จากหลักกฎหมายและระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ตลอดจนข้อสัญญาในสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การใช้สิทธิปรับที่เป็นโทษแก่ผู้ว่าจ้างก็คือ การใช้สิทธิปรับภายหลังการรับมอบงานและชำระค่าจ้างไปแล้ว เพราะผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถเรียกค่าปรับใดๆ ได้เลย หลักในการชำระหนี้ถือว่าการที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานไว้แล้ว ย่อมแสดงว่าผู้รับจ้างได้ชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้วและผู้ว่าจ้างได้รับชำระหนี้ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ทำให้หนี้ระงับเสร็จสิ้นไปในทันที มีผลให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้างได้อีก ในกรณีเช่นนี้ มีข้อสังเกตว่าหากผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยเมื่อได้ทราบว่าผู้รับจ้างชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือชำระหนี้ล่าช้า แต่ควรต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับในโอกาสแรกที่ทำได้ ทั้งนี้ ต้องมิใช่ภายหลังการรับมอบงานที่แล้วเสร็จล่าช้าไว้แล้ว ซึ่งมีผู้ให้คำอธิบายหลักการเกี่ยวกับการแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ว่า เมื่อเจ้าหนี้รู้ว่าลูกหนี้ผิดนัดและต้องการค่าปรับตามสัญญาในเวลาที่ยอมให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปซึ่งจะเป็นการสะดวกและทำให้ลูกหนี้รู้ว่าจะต้องชำระค่าปรับ หรือในเวลาต่อมาที่รับชำระหนี้ นั้น เจ้าหนี้ต้องบอกสงวนสิทธิไว้ว่าจะเรียกเอาเบี้ยปรับหรือค่าปรับตามสัญญานั้น ถ้าไม่ได้บอกสงวนสิทธิเรียกค่าปรับเอาไว้ ก็จะไม่สามารถเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคท้าย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๓/๒๕๑๔, ที่ ๑๐๔๔/๒๕๑๔, ที่ ๑๘๗๓/๒๕๑๔, ที่ ๒๑๐๐/๒๕๑๔, ที่ ๒๔๖/๒๕๒๒,

^{๔๙} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๕, หน้า ๑๕๔๖-๑๕๔๗.

^{๕๐} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๖๔ หน้า ๔๑

ที่ ๒๒๑๕/๒๕๒๖, ที่ ๒๙๔๗/๒๕๒๖ และที่ ๔๕๘/๒๕๓๕) ในเรื่องการแจ้งสงวนสิทธิปรับนี้ หากผู้ว่าจ้างไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไว้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับค่าปรับตามสัญญา แม้ว่าในข้อสัญญาจะกำหนดไว้ให้เรียกค่าปรับได้ก็ตาม^{๙๑}

ในเรื่องการใช้สิทธิเรียกค่าปรับและการแจ้งสงวนสิทธิปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าหรือปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

- กรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่สามารถก่อสร้างบ้านพักครูได้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเพราะไม่อาจใช้บ้านพักครูได้ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับมอบงานที่ผู้รับจ้างได้ทำตามสัญญาจ้างว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วให้เสนอเรื่องไปยังผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการดังกล่าวไม่มีอำนาจในการแจ้งสงวนสิทธิเรียกเบี้ยปรับแต่อย่างใด ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้างเท่านั้นที่มีอำนาจพิจารณารับมอบงานจากผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปขอรับเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงได้เรียกเบี้ยปรับที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา แต่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างไม่ยอมรับเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือจากการหักค่าปรับดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ว่าจ้างหาได้ยอมรับมอบงานโดยมิได้อิดเอื้อน ซึ่งจะทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๙๗ แต่อย่างใดไม่ และการที่ผู้ว่าจ้างแจ้งแก่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างว่าจะต้องมีการหักค่าปรับจากเงินค่าจ้าง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ว่าจ้างได้บอกสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาค่าปรับแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับจากผู้รับจ้างได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๕๖/๒๕๓๓)

- กรณีที่องค์การสะพานปลาวางจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ก่อสร้างเสากันกระแทกและรั้วลวดหนามที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยได้รับมอบงานไว้แล้วสองงวด ส่วนงวดที่สาม ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดไปสามวัน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจรับงานงวดสุดท้ายพบว่างานในส่วนสาระสำคัญมีข้อบกพร่องต้องแก้ไข จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข แต่ในระหว่างนั้นผู้ว่าจ้างได้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์จากงานงวดสุดท้ายนับแต่วันก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นต้นมา จึงเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้แล้วว่าผู้ว่าจ้างได้รับรองความถูกต้องและรับมอบงานจากผู้รับจ้างไว้แล้ว และเป็นการรับมอบงานส่วนที่แยกกันได้ออกจากส่วนอื่นไว้แล้ว แต่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาค่าปรับเพราะเหตุที่ไม่ชำระหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด จึงไม่สามารถใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างตามสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๒๑/๒๕๒๑)^{๙๒}

^{๙๑} จิตติ เจริญน้ำ, “การปรับตามสัญญาที่มีพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๑ (กันยายน ๒๕๓๘), หน้า ๔๙.

^{๙๒} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อยกหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๓๙๙-๔๐๑.

- กรณีที่เทศบาลเมืองพิจิตรทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ทำการปูพรีมิกค์ถนน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่หนึ่งเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงได้ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันนับแต่วันล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามงวดที่หนึ่ง กรณีนี้เป็นการปรับที่ไม่ถูกต้องเพราะวันแล้วเสร็จอันจะเป็นมูลให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ หมายถึง ถึง วันแล้วเสร็จโดยบริบูรณ์ตามสัญญาในงวดสุดท้าย ดังนั้น แม้ในสัญญาจ้างมีข้อกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาได้หากงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา แต่เมื่อผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา จึงมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้นับแต่วันที่เลยกำหนดวันแล้วเสร็จโดยบริบูรณ์ตามสัญญาในงวดสุดท้าย ส่วนวันแล้วเสร็จตามกำหนดงวดงานเป็นการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการจ่ายเงินตามงวดงาน ดังนั้น การที่ผู้ว่าจ้างปรับผู้รับจ้างเพราะส่งมอบงานงวดที่หนึ่งล่าช้า จึงเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างได้เมื่องานไม่แล้วเสร็จตามงวด (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๕๓/๒๕๒๓)^{๙๓}

- กรณีที่จังหวัดยโสธรว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตอำเภอ แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้วโดยมิได้บอกสงวนสิทธิการปรับไว้ในเวลารับชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิปรับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ การละเลยไม่บอกสงวนสิทธิปรับทำให้ทางราชการต้องเสียสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง จึงต้องมีผู้รับผิดชอบต่อทางราชการด้วย (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๖๐/๒๕๒๗)^{๙๔}

- กรณีกรมสรรพสามิตทำสัญญากับกลุ่มบริษัท ส. เพื่อผลิตและขายส่งสุราขาว-ผสม โดยต้องทำการก่อสร้างโรงงานสุราขึ้นใหม่จำนวน ๑๑ โรงงาน และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา โดยในสัญญาระบุว่าการก่อสร้างและส่งมอบไม่ทันภายในกำหนดจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างโรงงานสุราแล้วเสร็จและส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนด คณะกรรมการรับมอบงานก็รับมอบงานไว้โดยมิได้บอกสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๘๑ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๖๔/๒๕๓๒)^{๙๕}

นอกจากนี้ ยังมีหลักการใช้สิทธิเรียกค่าปรับอีกประการหนึ่ง คือ การใช้สิทธิเรียกค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ตามคำร้องขอของผู้รับจ้างเอง ผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุอันเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ก่อนการบอกเลิกสัญญาจ้าง

^{๙๓} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อยกหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๘๖๘-๘๖๙.

^{๙๔} สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อยกหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗, หน้า ๔๓๗-๔๓๘.

^{๙๕} สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อยกหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔, หน้า ๔๕๒.

จึงจะสามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ดังตัวอย่างคำพิพากษากฎีกา ดังนี้

- กรณีที่สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกำหนดว่า หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดอันเป็นการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ และถ้าเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้อีกด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาทั้งที่ผู้ว่าจ้างขยายเวลาให้แล้วถึงสองครั้ง ผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยก่อนหน้านั้นได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาจ้างเอาไว้แล้ว ดังนี้ ย่อมถือได้ว่าการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับดังกล่าวเป็นการที่ผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว เพราะผู้ว่าจ้างได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งมาแต่แรกแล้วว่า จะใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาจ้างได้ (คำพิพากษากฎีกาที่ ๓๓๕๒/๒๕๔๒)

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับนี้ มีผู้ให้คำอธิบายไว้ว่า หากคู่สัญญาจะตกลงกันไว้ในสัญญาว่า ในการเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา คู่สัญญาไม่ต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับกันก่อนก็ได้ การทำข้อตกลงล่วงหน้ากันไว้ในลักษณะนี้เป็นการทำสัญญาที่ยกเว้นหลักกฎหมายตามมาตรา ๓๘๑ วรรคท้าย ที่คู่สัญญาสามารถกระทำได้เพราะมิใช่ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบได้กับกรณีที่มีการวินิจฉัยว่า การบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือ การเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาและค่าเสียหายที่กำหนดจำนวนไว้ล่วงหน้าก็คือ เบี้ยปรับ นั่นเอง ซึ่งคู่สัญญาอาจตกลงกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง ข้อตกลงดังกล่าว จึงไม่เป็นโมฆะ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามนัยคำพิพากษากฎีกาที่ ๓๘๒๑/๒๕๒๔^{๙๖}

สำหรับการเรียกค่าปรับในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาจัดเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้พึงได้รับตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยเจ้าหนี้หรือผู้ว่าจ้างต้องพิสูจน์ความเสียหายให้ ศาลเห็นด้วย หากไม่พิสูจน์ความเสียหายเช่นนั้น ศาลก็จะใช้ดุลพินิจปรับลดลงตามส่วนได้หากเห็นว่าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ สำหรับแนวความคิดที่ว่าไม่จำเป็นต้องนำสืบความเสียหายนั้น คงใช้ได้เฉพาะค่าปรับที่ไม่สูงเกินส่วนหรือไม่สูงไปเท่านั้น แต่หากสูงเกินไป ลูกหนี้จะต้องพิสูจน์ความเสียหายที่กำหนดเป็นค่าปรับ นั้นไว้ให้ศาลเห็นด้วยว่ามีเหตุผลอย่างใดจึงไม่ควรกำหนดค่าปรับไว้สูงเช่นนั้น และในบางกรณีแม้จะกำหนดค่าเสียหายไว้พอสมควรแล้ว ก็ยังต้องนำสืบค่าเสียหายอันเป็นค่าปรับที่กำหนดไว้ในสัญญาให้เห็นอีกด้วยเช่นกันหากเจ้าหนี้ได้ค่าเสียหายอื่นๆ พอเพียงแล้ว เช่น ได้เงินค่าริบหลักประกันพอควรแล้ว ศาลก็อาจไม่ให้ค่าปรับตามสัญญา เพราะเป็นค่าเสียหายที่ไม่จำเป็นหรือเกินเลยมากไป^{๙๗}

^{๙๖} โปรดอ่านรายละเอียดใน จิตติ เจริญจำ, “การแจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๒ (ตุลาคม ๒๕๓๘), หน้า ๔๐-๔๑.

^{๙๗} โปรดอ่านใน จิตติ เจริญจำ, “การปรับตามสัญญาที่มีพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ,” วารสารอัยการ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๗-๔๘.

อนึ่ง ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ^{๙๘} ได้กล่าวถึงการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้โดยต้องมีที่มาจากเหตุ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ๒) เหตุสุดวิสัย และ ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการได้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง จึงจะสามารถยกเหตุหนึ่งเหตุใดขึ้นกล่าวอ้างเพื่อขอให้ส่วนราชการงดหรือลดค่าปรับได้ แต่ในกรณีที่เหตุผลที่คู่สัญญายกขึ้นกล่าวอ้างไม่เข้าลักษณะตามเหตุหนึ่งเหตุใดข้างต้น หากแต่เป็นพฤติการณ์ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการดำเนินงานของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถขอให้งดหรือลดค่าปรับได้

ในเรื่องนี้มีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่ากรณีใดที่ผู้ว่าจ้างต้องลดค่าปรับหรือไม่ ดังต่อไปนี้

- กรณีที่ผู้รับจ้างฟ้องกรมทางหลวงเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งรับค่าปรับตามสัญญาโดยอ้างว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงทางแยกลาดพร้าวแล้วเสร็จล่าช้าเนื่องจากมีอุปสรรคในการทำงาน เช่น ต้องย้ายเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ท่อประปา ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งมีสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างมากนั้น ศาลเห็นว่าผู้รับจ้างได้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งได้คิดคำนวณระยะเวลาแก้ไขอุปสรรคไว้ด้วยแล้วและคิดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา การที่ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้างจึงเป็นการยอมรับงานจ้างตามสภาพอุปสรรคที่มีอยู่ มิใช่ผู้ว่าจ้างต้องส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างโดยปราศจากอุปสรรค ทั้งตามสัญญาที่ผู้รับจ้างทำกับผู้ว่าจ้างก็ไม่มีข้อสัญญาข้อใดกำหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องกระทำเช่นนั้น เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดจึงต้องถูกปรับตามสัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๐๔/๒๕๓๖)^{๙๙}

- ตามสัญญาจ้างตกลงว่า หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ปรับเป็นรายวันนั้น เห็นว่า เบี้ยปรับเป็นเงินที่ผู้รับจ้างสัญญาว่า

^{๙๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้ผู้สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือส่วนราชการทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

^{๙๙} โปรดอ่านรายละเอียดใน จิตติ เจริญน้ำ, “พฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับ,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๔ (เมษายน ๒๕๓๗), หน้า ๙๙-๑๐๒.

จะให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญา แต่ถ้าหากเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงให้เป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้รับจ้างได้ลงทุนก่อสร้างงานนี้เป็นเงินจำนวนมาก เมื่อผู้ว่าจ้างทราบว่าการรับจ้างใช้เสาเข็มผิดขนาด จึงไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเลย ทั้งนี้ แม้ผู้ว่าจ้างจะอ้างว่าจำต้องระงับการจ่ายเพื่อเป็นประกันการที่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ แต่เมื่อผู้ว่าจ้างมิได้นำสืบให้เห็นว่าได้จ้างบุคคลอื่นทำการก่อสร้างใหม่แล้วหรือไม่ และต้องใช้เงินจำนวนเท่าใด ทั้งปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้รับเงินค่าประกันการก่อสร้างที่มีจำนวนพอสมควรไว้แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะปรับผู้รับจ้างสูงกว่านี้อีก (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐/๒๕๓๙)

- ตามสัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำมีการแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เพียงงวดเดียว หลังจากนั้นผู้รับจ้างไม่ดำเนินงานต่อไปจนผู้ว่าจ้างต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๕๐ วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างยังคงเพิกเฉย แม้ต่อมาผู้ว่าจ้างจะได้มีหนังสือเร่งรัดให้เข้าดำเนินการก่อสร้างรวม ๓ ฉบับพร้อมทั้งได้แจ้งด้วยว่าหากไม่เข้าทำงานจะบอกเลิกสัญญา แต่ผู้รับจ้างก็มีได้ดำเนินการก่อสร้างแต่ประการใด พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้รับจ้างจึงย่อมต้องอยู่ในความรู้เห็นของผู้ว่าจ้างโดยตลอดและเล็งเห็นได้ว่าผู้รับจ้างน่าจะต้องละทิ้งงานและเกิดความเสียหายขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ว่าจ้างอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น แต่ผู้ว่าจ้างกลับละเลยไม่ใช้สิทธิดังกล่าวจนครบกำหนดอายุสัญญาและยังปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปอีกโดยผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาหลังจากสัญญาครบกำหนดแล้วถึง ๖๔๘ วัน โดยไม่ปรากฏเหตุผลสำคัญอย่างอื่นให้เห็นถึงเหตุขัดข้องที่ต้องกระทำเช่นนั้น แม้ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิปรับผู้รับจ้างตามสัญญาและมีสิทธิเรียกค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการก่อสร้างต่อจาก ผู้รับจ้างตามสัญญาก็ตาม แต่ก็ถือว่าเงินค่าปรับและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการบรรเทาความเสียหายอันอาจจะมีหรือเกิดขึ้นจากกรณีที่มีการผิดสัญญาไว้ล่วงหน้าเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง เมื่อความเสียหายเกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงานของผู้ว่าจ้างรวมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง ศาลย่อมใช้ดุลพินิจลดจำนวนเบี้ยปรับลงได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๙๓/๒๕๔๒)

๒.๒.๒ การเรียกเอาค่าปรับในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา

การใช้สิทธิเรียกค่าปรับในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วนั้น อาจแบ่งออกได้เป็นสองกรณี ได้แก่

๑) กรณีการเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับ

การเรียกค่าปรับในกรณีนี้มีความเกี่ยวข้องกับกรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญาในแง่ที่ว่า แม้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาทันที หากแต่ได้ผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาออกไป ทำให้ผู้รับจ้างยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้แม้ว่าจะได้กระทำผิดสัญญาแล้วก็ตาม โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับเนื่องจากเหตุล่าช้าเช่นนั้นได้ ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่ผู้รับจ้างจะทำงานได้

แล้วเสร็จ ก็จะบอกเลิกสัญญาในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้มีปัญหาว่าผู้ว่าจ้างควรใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเมื่อใด เนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่สามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับในวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้เพราะไม่มีผลงานส่งมอบให้แก่กันซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่างจากการแจ้งสงวนสิทธิปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าที่ผู้ว่าจ้างยังสามารถแจ้งสงวนสิทธิปรับในวันที่มีการส่งมอบงานได้ ตามปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น หลักในการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับที่เป็นคุณแก่ผู้ว่าจ้าง คือ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับกับผู้รับจ้างไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อได้ทราบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเมื่อสัญญาจ้างครบกำหนดสัญญาแล้ว แม้ว่า ผู้รับจ้างจะยังทำงานตามสัญญาจ้างต่อไปก็ถือเป็นการทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หากในระหว่างนั้นผู้ว่าจ้างไม่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไว้ก่อน ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างต้องบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ ก็อาจจะลืมไปว่ายังไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ หากจะมาใช้สิทธิดังกล่าวในภายหลังจากที่ได้บอกเลิกสัญญาไปแล้วก็จะไม่สามารถเรียกค่าปรับได้ สำหรับกรณีที่ผู้ว่าจ้างแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างไว้ก่อนแล้วในช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าดังกล่าว การบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้างที่มีตามมาก็จะมีลักษณะเป็นการบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะสามารถเรียกค่าปรับได้นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้าง

ในกรณีที่เป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างของทางราชการโดยผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองนั้น ตามข้อ ๑๓๗^{๑๐๐} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก็ได้ให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ประกอบกับข้อ ๗ ก. และข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาในแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบดังกล่าว (ทั้งนี้ จะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาโดยละเอียดต่อไปในหน้า ๖๒)

ในเรื่องการใช้สิทธิเรียกค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ อาจกล่าวได้ว่าหลักสำคัญ ก็คือ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างได้ต่อเมื่อได้แจ้งหรือแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบว่า แม้ผู้ว่าจ้างจะผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่บอกเลิกสัญญาจ้างในทันทีที่มีเหตุผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา (เช่น ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญา ฯลฯ) เนื่องจากผู้ว่าจ้างยังประสงค์จะได้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ผู้ว่าจ้างมากกว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างก็ตาม แต่ผู้ว่าจ้างก็ต้องการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเพราะเหตุทำงานล่าช้าโดยเริ่มปรับนับแต่วันถัดจากวันที่สัญญาจ้างครบกำหนดเป็นต้นไป กรณีนี้

^{๑๐๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือทำงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ จะต้องเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการบอกเลิกสัญญา ในกรณีเช่นนี้ แม้ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาในภายหลังเพราะเห็นว่าไม่มีโอกาสที่ผู้รับจ้างจะทำงานได้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างก็สามารถเรียกเบี้ยปรับเป็นรายวันได้นับแต่วันที่มีการผิดสัญญาซึ่งเป็นวันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่มีการบอกเลิกสัญญา อันถือเป็นเบี้ยปรับตามสัญญา นอกจากนี้ ถ้าผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ด้วยหากผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่สูงกว่าเดิม

กรณีเกี่ยวกับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการเรียกค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ดังนี้

- เมื่อใกล้จะครบกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาแต่ละฉบับตามที่ไต่ขยายเวลาออกไป ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับไว้ หลังจากครบกำหนดเวลาตามที่ไต่ขยายออกไปแล้ว ผู้ว่าจ้างไปตรวจงานก่อสร้างปรากฏว่าผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่างานไม่คืบหน้าแต่ประการใด เพราะผู้รับจ้างทิ้งงานอันถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาอันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาซึ่งไม่ขัดกับสิทธิที่ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามข้อสัญญาด้วยเช่นกัน เพราะ ผู้ว่าจ้างได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วว่า จะใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาจ้างได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๗/๒๕๔๐ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๘๐/๒๕๔๑)

สำหรับในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาจ้างเนื่องจากทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างในที่สุดนั้น มีหลักในการเริ่มนับระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิปรับในระหว่างที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ดังคำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ดังต่อไปนี้

- สำนักงานพลังงานแห่งชาติทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตรวมสามสัญญา แต่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเพียงบางส่วนและต่อมาผู้รับจ้างยังขอเลิกสัญญาจ้างทั้งสามฉบับ ผู้ว่าจ้างได้ตกลงเลิกสัญญาและได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่สามรายเข้าทำการก่อสร้างงานที่ค้างจนแล้วเสร็จและได้ชำระค่าจ้างแล้ว กรณีถือเป็นการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด อันเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นรายวันตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่ละฉบับ นับแต่วันพ้นกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจนถึงวันครบกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ของผู้รับจ้างรายใหม่ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๒๖)^{๑๐๐}

^{๑๐๐} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๓-๑๗๔.

- มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจ้างบริษัท ก. จำกัด ก่อสร้างเรือนแถวที่พักคนงานโดยแบ่งเป็นสามงวด ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงสองงวด และการส่งมอบงานงวดที่สองล่วงเลยกำหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างได้ผ่อนผันให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานงวดที่สามต่อไป แต่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่เสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ง. ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทน ซึ่งตามสัญญาจะถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาก็ต่อเมื่อก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จเมื่อครบกำหนดก่อสร้าง วันผิดสัญญาจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันดังกล่าวเป็นต้นไป การคิดค่าปรับจึงต้องเริ่มจากวันถัดจากวันครบกำหนดก่อสร้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ส่วนวันแล้วเสร็จแต่ละงวดงานนั้น เป็นวันที่กำหนดไว้เพื่อกำหนดงานแบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง หากวันผิดสัญญาโดยตรงไม่ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๘๒/๒๕๒๒)^{๑๐๒}

๒) กรณีการเรียกค่าปรับภายหลังการบอกเลิกสัญญา

การใช้สิทธิเรียกค่าปรับภายหลังการบอกเลิกสัญญานี้เป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาและไม่มีโอกาสที่จะแล้วเสร็จ จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีที่ผู้รับจ้างกระทำความผิดสัญญาและใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามมา กรณีนี้จัดเป็นกรณีที่แตกต่างจากการบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไว้ในแง่ที่ว่า การบอกเลิกสัญญาโดยทันทีจะทำให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถเรียกค่าปรับได้อีกต่อไปเพราะทันทีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้างย่อมมีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างกลับคืนสู่ฐานะเดิมและไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอีกต่อไป แต่กระนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ผิดสัญญายังต้องมีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ว่าจ้างยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ ดังปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและสำนักงานอัยการสูงสุด ดังต่อไปนี้

- ตามข้อสัญญาจ้างกำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้และหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าจ้างยังไม่ส่งมอบงานและสิ่งของตามสัญญาแต่อย่างใด ทั้งไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบเป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญา กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยมิได้เรียกค่าปรับผู้รับจ้างเพราะเหตุผู้รับจ้างมิได้ทำงานหรือส่งมอบงานล่าช้ามาก่อน ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๘/๒๕๓๐)

- ผู้รับจ้างละทิ้งงานในงวดที่ ๑๐ อันเป็นการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างและได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่ค้างอยู่จนแล้วเสร็จ การที่ผู้รับจ้างละทิ้งงานทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างทำให้สัญญาจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างระงับลงแล้ว

^{๑๐๒} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ขอรื้อหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๖๑๔-๖๑๕.

คู่สัญญาจำต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม แม้สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างจะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าปรับแก่ผู้ว่าจ้างจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จก็ตาม ผู้ว่าจ้างหาสิทธิที่จะได้รับเงินค่าปรับนั้นอีกต่อไปไม่เนื่องจากสัญญาได้ระงับลงแล้ว ผู้ว่าจ้างคงมีสิทธิเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้เพียงค่าเสียหายตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๒)

- เมื่อข้อสัญญาระบุว่า ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันนับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างเพราะเหตุผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้างมาก่อนวันบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างในเวลาต่อมา ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามสัญญาจ้างได้ คงได้แต่สิทธิเรียกค่าเสียหายตามสัญญาจ้างเท่านั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๓๑/๒๕๓๙)

นอกจากนี้ยังมีคำวินิจฉัยในการตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างภายหลังการบอกเลิกสัญญาที่น่าสนใจ ดังนี้

- กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ต่อมาผู้รับจ้างได้โต้แย้งว่าข้อสัญญาบางส่วนไม่น่าจะถูกต้อง เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้หารือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ได้รับแจ้งยืนยันให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาต่อไป หากจะแก้ไขต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ผู้รับจ้างจึงได้บอกเลิกสัญญา จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นคู่สัญญาได้ยอมรับการบอกเลิกสัญญาของผู้รับจ้างโดยมิได้สงวนสิทธิอย่างใดไว้ จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายและค่าปรับจากผู้รับจ้างตามสัญญาได้ เพราะกรณีมิใช่เรื่อง que ผู้รับจ้างผิดสัญญา แต่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาตกลงเลิกสัญญากันด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย สัญญาเป็นอันเลิกกันแล้วตั้งแต่วันที่สนองรับการเลิกสัญญานั้น (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ พ.๗๘/๒๕๒๑)^{๑๐๓}

- กรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้แจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับ จากนั้นผู้ว่าจ้างได้หาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำการก่อสร้างแทน ตามปัญหาพิพาทนี้ ผู้ว่าจ้างประสงค์จะฟ้องเรียกค่าปรับตามข้อสัญญานับแต่วันครบกำหนดการขยายเวลาจ้างตามที่ได้อนุญาตจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาว่า การที่ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ต้องเป็นการบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องทำการปรับผู้รับจ้างเนื่องจากการทำงานจ้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาเสียก่อนหรืออย่างน้อยก็ต้องแสดงเจตนาโดยแจ้งให้ผู้รับจ้าง

^{๑๐๓} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๔๖๓-๔๖๔.

ทราบเสียก่อนว่าแม้ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาทั้งที่ผู้รับจ้างทำงานจนล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้วก็ตาม แต่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างตั้งแต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา ดังนั้น หากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาโดยมิได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงความประสงค์ในการเรียกค่าปรับไว้ก่อน หรือเพียงแต่แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไปพร้อมกับหนังสือบอกเลิกสัญญาย่อมไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับ ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๔/๒๕๓๑)^{๑๐๔}

- กรณีที่กรมการbinพาณิชยได้ทำสัญญาจ้างบริษัท อ. ซ่อมเปลี่ยน Control Line ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างสถานีเครื่องส่งวิทยุหอบังคับการบินและอุปกรณ์ที่ทำอากาศยานเชียงใหม่ แต่ผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างชำระหนี้และสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ ต่อมาภายหลังได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับ การที่ผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างย่อมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้และการบอกเลิกสัญญาที่จะมีผลให้เกิดสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับได้ต้องเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับตามที่กำหนดในข้อสัญญา ดังนั้น เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องแสดงเจตนาต่อผู้รับจ้างให้ชัดเจนว่าผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับดังกล่าวไว้ โดยที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแม้จะครบกำหนดสัญญาจ้างแล้วก็ตาม หากผู้ว่าจ้างมิได้แจ้งการปรับและแจ้งสงวนสิทธิการปรับตั้งแต่เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา การแจ้งสงวนสิทธิในภายหลังแล้วจึงบอกเลิกสัญญาหรือการแจ้งสงวนสิทธิพร้อมกับการบอกเลิกสัญญาย่อมถือเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยมิได้แจ้งการปรับหรือสงวนสิทธิการปรับไว้เมื่อครบกำหนดสัญญา และทำให้ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิปรับย้อนหลังไปจนถึงวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๓๑)^{๑๐๕}

๒.๓ สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง

๒.๓.๑ หลักการบอกเลิกสัญญา

สัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลหนี้ เมื่อสัญญาเกิดขึ้นย่อมผูกพันคู่สัญญาในอันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญานั้น^{๑๐๖} การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นวิธีการระงับหนี้ตามสัญญา เพราะเมื่อไม่มีสัญญาอยู่ หนี้ตามสัญญาย่อมระงับไปด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดสัญญาไม่ได้ทำให้สัญญาชำระหนี้ที่เหมือนดังกรณีลูกหนี้ปฏิบัติชำระหนี้ถูกต้องตาม

^{๑๐๔} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหาทนายความและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๙-๒๑๐.

^{๑๐๕} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหาทนายความและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), เล่มเดียวกัน, หน้า ๓๓๒-๓๓๓.

^{๑๐๖} ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา, แก้ไขเพิ่มเติม (พิมพ์ครั้งที่ ๓), สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๒๗, หน้า ๔๖๘.

สัญญาเพราะไม่มีหนี้ต้องชำระกันอีกต่อไป โดยในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างในฐานะเจ้าหนี้มีทางเลือกสองทาง คือ จะยังไม่บอกเลิกสัญญาทันที แต่ใช้สิทธิเรียกค่าปรับก่อนไว้ และต่อมาภายหลังจึงมีการรับมอบงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบล่าช้าไว้ กรณีหนึ่ง กับอีกกรณีหนึ่ง คือ การเลือกใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างทันทีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา เพราะมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาได้ ซึ่งจะมีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อมีการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างนี้มักจะเป็นผู้ว่าจ้างมากกว่าผู้รับจ้าง ซึ่งแสดงว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้มุ่งหวังในผลงานที่จะได้รับจากผู้รับจ้างอีกต่อไป และหากยังปล่อยให้ผู้รับจ้างทำงานต่อไป ความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือความบกพร่องต่างๆ ก็จะเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการมากยิ่งขึ้น การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ส่วนราชการเลือกใช้เพื่อระงับความเสียหายเช่นนั้นและว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานที่ค้างอยู่ต่อไปจนเสร็จบริบูรณ์ ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างจึงเป็นสิทธิของคู่สัญญา ไม่ใช่บทบังคับว่าผู้ว่าจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาเสมอไป แต่เมื่อผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาย่อมแสดงว่าผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะบังคับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามชำระหนี้ตามสัญญาอีกต่อไป และโดยผลทางกฎหมาย การบอกเลิกสัญญามีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดผู้ว่าจ้างไม่สามารถบังคับให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ได้อีกต่อไป ซึ่งจะได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาต่อไปดังนี้

เนื่องจากบทบัญญัติตามมาตรา ๓๘๖^{๑๐๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาย่อมทำได้ด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาสามารถทำได้สองกรณีคือ การบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาและโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๑) การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา เป็นการที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นพ้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้จะต้องมีข้อกำหนดในสัญญาไว้โดยตรงว่าให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงจะสามารถบังคับให้เป็นไปตามข้อสัญญาเช่นนั้นได้ หรือในบางกรณีก็อาจจะมีข้อสัญญากำหนดไว้ว่าให้ฝ่ายใดเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ดังเช่น ตามสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา^{๑๐๘} ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนด

^{๑๐๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๖ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนั้นย่อมทำได้ด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

การแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่

^{๑๐๘} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๖๓ หน้า ๔๐

เวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างและว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานต่อไปให้เป็นผลสำเร็จได้ จากข้อสัญญานี้ มีข้อสังเกตว่าการบอกเลิกสัญญาสามารถกระทำได้นี้เนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันและช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ก็มีทั้งในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงและในช่วงภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดลง

สำหรับในกรณีที่เป็นการเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานภายในเวลาอันควรหรือไม่ลงมือทำงานเลยนั้น หากผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นแล้วว่าระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องเข้าเริ่มทำงานตามสัญญานั้นได้ล่วงเลยไปแล้วและงานที่ว่าจ้างคงจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาอย่างแน่นอน ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ก่อนครบกำหนดก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้างเพราะเหตุผู้รับจ้างไม่เข้าเริ่มทำงานตามกำหนดสัญญาดังกล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๙๓^{๑๐๙} และตามสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุฯ ข้อ ๗ ข. อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ามีคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับผลของการบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานไว้เป็นสองแนวที่แตกต่างกัน ดังนี้

แนวคำวินิจฉัยแรกเป็นกรณีที่วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานเลย ผู้ว่าจ้างไม่สามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ ดังนี้

- เมื่อตามสัญญาจ้างระบุว่า ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันนับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา โดยไม่มีข้อสัญญาเกี่ยวกับกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ลงมือทำการก่อสร้างเลยว่ามีกำหนดเบี้ยปรับกันอย่างไร เมื่อเบี้ยปรับตามข้อสัญญาเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดไว้สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าจะใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ผู้รับจ้างได้ลงมือทำการก่อสร้างแล้ว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างยังมิได้ทำการก่อสร้างตามสัญญาเลยทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา การที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจึงเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเบี้ยปรับตามสัญญาจากผู้รับจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๙๐/๒๕๓๘)

^{๑๐๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๙๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้ มีพักต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้นเลย

- กรมสามัญศึกษาโดยจังหวัดปทุมธานีได้ทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แต่ผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่เข้าทำการก่อสร้าง กรมสามัญศึกษาจึงได้มอบอำนาจให้จังหวัดฯ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างและริบหลักประกันสัญญา กรณีนี้เมื่อปรากฏว่านับแต่วันทำสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำการก่อสร้างบ้านพักครูเลย จึงเป็นเรื่องผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ใช่เรื่องทำการก่อสร้างล่าช้า จึงไม่มีช่วงเวลาที่ให้นำมาคำนวณค่าปรับได้ ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิที่จะปรับตามสัญญา แต่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๘๕/๒๕๑๗ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๕๒/๒๕๒๕)^{๑๐๐}

แนวคำวินิจฉัยที่สองเป็นกรณีที่วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานเลย ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างไม่ลงมือดำเนินการก่อสร้างใดๆ เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ทันภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ก่อนหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันอันถือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนที่หลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว จนกระทั่งปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอันเป็นการบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญา จึงไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นรายวันเพราะผู้ว่าจ้างได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งมาตั้งแต่แรกแล้วว่า จะใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาจ้างได้แม้ผู้รับจ้างจะยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างใดๆ ตามสัญญาก็ตาม (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๘๐/๒๕๔๑)

- กรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วน ป. วางท่อติดตั้งประปาในโรงเรียน เมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงมีหนังสือเร่งรัดให้เข้าทำงานและได้สงวนสิทธิปรับไว้แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉย ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญา รวมทั้งว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนในวงเงินค่าจ้างที่ต่ำกว่าเดิม กรณีนี้ผู้ว่าจ้างยังไม่ประสงค์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ประสงค์ใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันตามเงื่อนไขในสัญญาก่อน ต่อมาเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับ ดังนั้น นอกจากผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิริบหลักประกันและเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จภายหลังการบอกเลิกสัญญาได้แล้ว ยังมีสิทธิเรียกเอาค่าปรับนับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๓๗)^{๑๐๑}

^{๑๐๐} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ขอรื้ออัยการฎีกาหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๗๗-๑๔๗๘.

^{๑๐๑} จิตติ เจริญจำ, “ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๘), หน้า ๗๗-๘๐.

- กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพช.) ทำสัญญาจ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด แต่ผู้รับจ้างไม่เริ่มลงมือทำงานตามกำหนดเวลาในสัญญาจนล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จ กรณีนี้ถือว่าผู้รับจ้างกระทำความผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ผู้รับจ้างซึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญาย่อมไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วย่อมมีสิทธิเรียกค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้างได้หากมีการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานตามสัญญาในราคาที่สูงกว่าเดิม ส่วนการเรียกค่าปรับรายวันสำหรับความล่าช้าตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญานั้น ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิเรียกได้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างหรือได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างก่อนที่จะบอกเลิกสัญญา (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๘๗/๒๕๓๒)^{๑๑๒}

ตามหลักในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากมีข้อสัญญากำหนดให้สิทธิผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างย่อมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้างก่อนและไม่ต้องบอกกล่าวให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนก็ได้ ตลอดจนไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลาตามสัญญาก่อนแต่อย่างใด ดังปรากฏในคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่า โดยหลักของการบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญาซึ่งให้สิทธิผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้นั้น ถือเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ส่งมอบงานก่อนและไม่ต้องบอกให้แก้ไขงานให้ถูกต้อง และไม่รอให้ครบกำหนดเวลาตามสัญญาก่อนแต่ประการใด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๐๘/๒๕๒๔) ในกรณีดังกล่าวมานี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จำปี โสทธิพันธุ์^{๑๑๓} ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า การบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวกำหนดเวลาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนนั้นจะต้องเป็นกรณีที่การชำระหนี้ตามเวลาเป็นสาระสำคัญโดยสภาพของการชำระหนี้ตนเองหรือโดยเจตนาตามมาตรา ๓๘๘^{๑๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ในทางปฏิบัติมักปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานให้แล้วเสร็จโดยมีลักษณะเป็นหนังสือเร่งรัดการทำงาน หรือบางครั้งผู้ว่าจ้างก็จะแจ้งด้วยว่าหากไม่เข้าทำงานต่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดก็จะบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือมิฉะนั้นก็ให้ถือเอาหนังสือแจ้งของผู้ว่าจ้างดังกล่าวเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาเป็นต้น จากกรณีดังกล่าวมานี้จึงมีข้อสังเกตว่า แม้ในสัญญาจะมีการกำหนดเวลาในการชำระหนี้

^{๑๑๒} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่ม ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๔๗๖-๔๗๗.

^{๑๑๓} โปรด่านรายละเอียดใน จำปี โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, สำนักพิมพ์วิญญูชน (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐), ๒๕๔๘, หน้า ๓๖๒-๓๖๓.

^{๑๑๔} **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

มาตรา ๓๘๘ ถ้าวัตถุประสงค์แห่งสัญญานั้นว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนาที่คู่สัญญาแสดงไว้จะเป็นผลสำเร็จได้ก็แต่ด้วยการชำระหนี้ ณ เวลาที่กำหนดก็ดี หรือภายในเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ก็ดี และกำหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ชำระหนี้ไซ้ ท่านว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ มีพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในมาตราก่อนนั้นเลย

ไว้ แต่ก็มิได้หมายความว่าผู้ว่าจ้างจะต้องถือเอาเวลาในการชำระหนี้เป็นสาระสำคัญที่ต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในทุกโอกาสที่ ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาในสัญญา เพราะมีหลายกรณีที่ผู้ว่าจ้างในฐานะเจ้าหนี้มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด แต่ได้เลือกที่จะผ่อนเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ทั้งที่เป็นการชำระหนี้ที่ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาหรือล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว อันมีผลเป็นการสละสิทธิการบอกเลิกสัญญาเมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ดังนั้น เจ้าหนี้จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๘ ไม่ได้ เพราะเท่ากับเจ้าหนี้มิได้ถือเอาเวลาเป็นสาระสำคัญอีกต่อไป และจะมีผลทางกฎหมาย ดังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาตั้งต่อไปนี้

- ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมีข้อสัญญาว่า ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป หากงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานที่ว่าจ้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีโอกาสที่จะทำงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญาได้ทันที และหากเกิดความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาได้ด้วย ดังนั้น เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ว่าจ้างไม่ได้บอกเลิกสัญญาแล้วใช้สิทธิเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา แต่กลับยอมต่ออายุสัญญาให้ผู้รับจ้างโดยยอมรับเอาผลงานของผู้รับจ้างและชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างภายหลังจากที่ครบกำหนดอายุสัญญาที่ผู้ว่าจ้างต่ออายุให้ผู้รับจ้างแล้ว แสดงว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้ถือเอาระยะเวลาตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้รับจ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๐๗/๒๕๔๐)

- ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างอาคารเรียนโดยมีกำหนดส่งมอบงานและชำระค่าจ้างรวม ๗ งวด ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างรับมอบงานและชำระค่าจ้างเพียงงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ครบถ้วน แต่ชำระค่าจ้างงานงวดที่ ๔ ไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกัน ผู้ว่าจ้างจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่ได้บอกเลิกสัญญา ต่อมาหลังจากครบกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างชำระค่าจ้างงวดที่ ๔ ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยอมรับค่าจ้างดังกล่าว จากนั้นก็ยังคงก่อสร้างและส่งมอบงานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานเอาไว้และชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างครบถ้วน ซึ่งเป็นการแสดงว่าทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยังคงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไป โดยมีได้ถือเอากำหนดเวลาส่งมอบงานและชำระค่าจ้างเป็นงวดเป็นสาระสำคัญอีกต่อไป ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาไม่สามารถก่อสร้างงานงวดที่ ๗ ได้แล้วเสร็จและละทิ้งงานในที่สุด ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่การที่เมื่อครบกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ผู้รับจ้างไม่ได้ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าจ้างเป็นงวดเป็นสาระสำคัญ ในขณะที่ผู้ว่าจ้างก็ไม่ถือเอากำหนดเวลาส่งมอบงานเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น วันส่งมอบงานล่าช้าจึงไม่มีอีกต่อไป

ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน แต่มีเพียงสิทธิเรียกค่าเสียหายเท่านั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๓๘/๒๕๔๕)

ในเรื่องการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญาที่ รองศาสตราจารย์ ดร. จำปี โสทธิพันธุ์ ยังได้ให้ข้อสังเกตไว้ด้วยว่า “สิ่งที่พึงระวัง คือ สิทธิของเจ้าหนี้ในการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดจากข้อสัญญาหรือข้อตกลงหมายกันแน่ หากในข้อสัญญาเขียนว่าเวลาเป็นสาระสำคัญ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้นิยมนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ กรณีนี้เวลาจะเป็นสาระสำคัญจริงหรือไม่ก็มีใช้ประเด็นการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๘ อันเป็นสิทธิ เลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย แต่กลับเป็นเรื่องสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเกิดจาก ข้อสัญญาและหากเจ้าหนี้มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญาแล้ว เจ้าหนี้จะมาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๘ อีกไม่ได้ เพราะการไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญาเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาย่อมแสดงอยู่ในตัวว่ากำหนดเวลาในการชำระหนี้มีใช้สาระสำคัญอีกต่อไป หากลูกหนี้ยังคงไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะบอกเลิกสัญญาได้ต้องย้อนกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๓๘๗^{๑๑๕} ก่อน”^{๑๑๖} อย่างไรก็ตาม การบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนตามมาตรา ๓๘๘ ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้ไม่ต้องแจ้งการบอกเลิกสัญญาต่อลูกหนี้ หากแต่หมายความว่าเจ้าหนี้ไม่ต้องกำหนดเวลาแล้วบอกกล่าวลูกหนี้ให้ชำระหนี้ก่อนเหมือนกรณีตามมาตรา ๓๘๗ เพราะบทบัญญัติในมาตรา ๓๘๘ ก่อให้เกิด “สิทธิ” ในการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น แต่ไม่ได้มีผลให้สัญญาเลิกกันโดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากเจ้าหนี้ต้องการเลิกสัญญาก็ต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาด้วย

สำหรับในเรื่องการบอกกล่าวให้คู่สัญญาชำระหนี้ก่อนบอกเลิกสัญญานั้น ในสัญญาจ้างบางสัญญาถึงกับมีการกำหนดเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าภายในระยะเวลาเท่าใดด้วย ดังปรากฏตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่า ในสัญญาจ้างซึ่งกำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จไว้ หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาจะถูกปรับวันละ ๕๐๐ บาท หรือผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๕ วัน การที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดและได้ขอยายระยะเวลาออกไปโดยยอมเสียค่าปรับวันละ ๗๐๐ บาทแทนอัตราเดิมนั้น หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ก็ไม่ทำให้สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะบอกเลิกสัญญาหมดไปและเป็นกรณีที่ ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๕ วันเพราะกำหนดเวลาที่ต้องบอกเลิกสัญญาล่วงหน้านั้นหมายถึงการบอกเลิกในระหว่างอายุสัญญา มิใช่การบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญามานานแล้ว (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๔/๒๕๐๓)

^{๑๑๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๗ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซ้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

^{๑๑๖} จำปี โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, อ่างแล้ว, หน้า ๓๖๒-๓๖๓.

ในสัญญาที่มีข้อสัญญากำหนดเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาไว้นี้ โดยปกติ คู่สัญญามักจะทำสัญญากำหนดสิทธิในการเลิกสัญญาทำนองเดียวกับบทบัญญัติมาตรา ๓๘๗ มาตรา ๓๘๘ และมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นหลักทั่วไป แต่ถึงแม้จะไม่มีข้อสัญญากำหนดเรื่องนี้ไว้ คู่สัญญาก็มีสิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ได้ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากจะมีการกำหนดไว้ในข้อสัญญาด้วยก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ประการใด นอกจากนี้ คู่สัญญายังอาจตกลงกันกำหนดสิทธิเลิกสัญญาในข้อสัญญาไว้แตกต่าง จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ได้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน^{๑๑๗} ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า สิทธิเลิกสัญญาต้องเป็นไปตามข้อสัญญา ถ้าคู่สัญญาตกลงกันไว้ในสัญญาว่าให้เจ้าหนี้มีสิทธิเลิกสัญญาได้ สิทธิเลิกสัญญาก็ต้องเป็น ไปตามข้อสัญญา โดยไม่อยู่ในบังคับสิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และยังได้ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาไว้สองประการ ดังนี้

ประการแรก สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา หมายความว่า คู่สัญญาได้ ตกลงกันกำหนดสิทธิในการเลิกสัญญาไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ก็ให้เจ้าหนี้ มีสิทธิแสดงเจตนาเลิกสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียว มิใช่คู่สัญญาแสดงเจตนาตกลงกันเลิกสัญญาหลัง จากทำสัญญาแล้ว อันเป็นการเลิกสัญญาโดยความตกลง

ประการที่สอง สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา มิใช่เงื่อนไขบังคับหลังหรือ เงื่อนไขเวลาสิ้นสุด เพราะนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลังหรือเงื่อนไขเวลาสิ้นสุดย่อมจะสิ้นผลหรือสิ้น สุดเมื่อเงื่อนไขสำเร็จหรือถึงกำหนดเวลา ส่วนสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญานั้น แม้จะกำหนดไว้ ในนิติกรรมเช่นเดียวกัน ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเลือก หากประสงค์จะเลิกสัญญาก็ต้องแสดง เจตนาเลิกสัญญา หากไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญา สัญญาก็ยังมีอยู่^{๑๑๘}

๒) การใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อกฎหมาย แม้ในกรณีที่ไม่มีข้อสัญญา ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ก็ตาม แต่ก็ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาได้ซึ่งเป็นการใช้ สิทธิเลิกสัญญาอันเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเอง โดยจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ตามมาตรา ๓๘๖ ถึงมาตรา ๓๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีตาม คำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องส่งมอบพื้นที่และกำหนดแนวเขตพื้นที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างว่า การที่ ผู้ว่าจ้างสั่งระงับการก่อสร้างเฉพาะการวางผังและตอกเสาเข็มรुकล้าเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดของผู้ว่าจ้างที่ไม่ตรวจแนวเขตที่ดินให้แน่นอนเสียก่อน ผู้ว่าจ้างจึงเป็นฝ่าย

^{๑๑๗} โปรดอ่านรายละเอียดในศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรมและสัญญา, อ้างแล้ว, หน้า ๔๗๗.

^{๑๑๘} ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา, เล่มเดียวกัน, หน้า ๔๗๗-๔๗๘.

ผิดสัญญาที่ไม่สามารถให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ แต่เมื่อในสัญญาจ้างเหมาไม่มีข้อสัญญาให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้เลย สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจึงย่อมมีอยู่เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น แม้สัญญาจ้างเหมาจะกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แน่นอน แต่เมื่อ มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าคู่สัญญาไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นข้อสำคัญอีกต่อไป กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๗ โดยผู้รับจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถลงมือก่อสร้างต่อไปโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควรให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ หากไม่สามารถแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๘/๒๕๒๕)

อย่างไรก็ตาม หลักในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยข้อสัญญาและการบอกเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมายนี้เน้นว่ามีความเกี่ยวพันกันและยังมีผลต่อความระงับแห่งสิทธิเลิกสัญญาด้วย ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. จำปี โสทธิพันธุ์ ได้ให้คำอธิบายไว้ดังนี้ “การที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาแล้ว แต่เจ้าหนี้มิได้ใช้สิทธิ แต่เมื่อลูกหนี้มาชำระหนี้ล่วงหน้าเจ้าหนี้ก็รับไว้ครั้งหนึ่ง ต่อมาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ อีก จึงมีประเด็นให้ต้องพิจารณาว่า เจ้าหนี้จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อสัญญาเดิมอยู่หรือไม่ในเมื่อครั้งแรกมิได้ใช้สิทธิ อาจมีลักษณะเป็นการตกลงยกเลิกสิทธิเลิกสัญญาที่มาจากข้อสัญญาได้โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาความระงับแห่งสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๓^{๑๑๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น หากการไม่ชำระหนี้ภายหลังมีลักษณะเดียวกับการชำระหนี้ครั้งแรก เจ้าหนี้ก็จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาอีกไม่ได้ หากต้องการบอกเลิกสัญญาต้องไปใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามบทบัญญัติของกฎหมาย”^{๑๒๐} กรณีที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องการรับชำระหนี้บางส่วน มิใช่ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ซึ่งเปรียบเทียบกับได้กับการที่ส่วนราชการว่าจ้างผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้างโดยมีการแบ่งงานออกเป็นงวดๆ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วสองงวด โดยการส่งงานงวดที่สองเป็นการส่งงานล่าช้ากว่ากำหนดสัญญาทางราชการได้ผ่อนผันให้ผู้รับจ้างทำงานงวดที่สามต่อไปจนกระทั่งล่วงเลยกำหนดสัญญาแล้ว ก็ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างทันที ต่อมาเมื่อมีเหตุให้ส่วนราชการผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงบอกเลิกสัญญาจ้าง กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าส่วนราชการผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิโดยข้อสัญญาบอกเลิกสัญญาจ้างในทันทีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา แต่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อกฎหมายในภายหลังก็เป็นกรณีที่ทำได้ เพียงแต่มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า กรณีเช่นนี้ควรเริ่มนับวันผิดสัญญาตั้งแต่วันใด กล่าวคือ ควรจะนับวันผิดสัญญาตั้งแต่เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญาส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา

^{๑๑๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายที่มีสิทธิเลิกสัญญานั้นแถลงให้ทราบภายในระยะเวลานั้นก็ได้ว่าจะเลิกสัญญาหรือไม่ ถ้ามิได้รับคำบอกกล่าวเลิกสัญญาภายในระยะเวลานั้น สิทธิเลิกสัญญาก็เป็นอันระงับสิ้นไป

^{๑๒๐} จำปี โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, อ่างแล้ว, หน้า ๓๖๕.

หรือควรจะนับแต่วันที่ครบกำหนดส่งมอบงานครบบริบูรณ์ในงวดสุดท้ายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ในเรื่องนี้สำนักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการเดิม) เคยมีความเห็นว่า วันแล้วเสร็จแต่ละงวดงาน กำหนดไว้เพื่อการแบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง หาใช้วันผิดสัญญาโดยตรงไม่ ส่วนวันผิดสัญญาให้ถือเป็น วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา (คำวินิจฉัยของสำนักงาน อัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๘๒/๒๕๒๒ และเลขรับที่ ห.๕๓/๒๕๒๓)^{๑๒๑}

นอกจากนี้ หากพิจารณาในแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๗ วรรคสอง^{๑๒๒} ซึ่งกำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘^{๑๒๓} ก็ได้ (ได้แก่ สิทธิในการว่าจ้างผู้อื่นทำงานต่อจน แล้วเสร็จ การริบหลักประกันสัญญา การเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และถ้า ผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย) จะเห็นได้ว่าการระบุว่า “ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา...” แสดงว่าเป็นกรณีที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้นแล้ว หรือมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองยังไม่ประสงค์จะ บอกเลิกสัญญา โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม สัญญาที่ยังไม่ถึงขนาดต้องบอกเลิกสัญญา และถ้าหากให้ผู้รับจ้างทำงานต่อไปให้แล้วเสร็จจะ

^{๑๒๑} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๖๑๔-๖๑๕ และหน้า ๘๖๘-๘๖๙.

^{๑๒๒-๑๒๓}

แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ฯลฯ

ฯลฯ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้น ชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่ จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบาง ส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลัก ประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้ว เสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่าการบอกเลิกสัญญาในทันที จึงได้ผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาจ้างออกไป หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ยินยอมขยายระยะเวลาหรือต่ออายุสัญญาให้ตามข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างเพราะหวังที่ผลสำเร็จของงานจึงไม่บอกเลิกสัญญาในทันที แต่กระนั้น การจะบอกเลิกสัญญาทันทีหรือการผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาออกไปนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต้องคำนึงถึงประโยชน์หรือทางได้เสียของส่วนราชการอย่างรอบคอบที่สุด ซึ่งข้อ ๑๓๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการที่ข้อ ๑๓๗ กำหนดไว้ในลักษณะดังกล่าวทำให้ส่วนราชการ ไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยง่าย หากแต่ต้องมีสาเหตุที่ถึงขนาดทำให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด อันแสดงว่าไม่ต้องการให้ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาตามอำเภอใจหรือโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบถึงความเสียหายที่จะเกิดมีแก่ทางราชการ ดังปรากฏในคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่วินิจฉัยไว้ในกรณีที่กองทัพเรือบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัท ท. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการและที่พักอาศัยของอู่ซ่อมเรือที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า เนื่องจากระยะเวลาทำงานได้ล่วงเลยมาประมาณร้อยละ ๕๕.๒ ของเวลาทำงานแล้ว แต่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ผลงานเพียงร้อยละ ๑๗ เท่านั้น และได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ กรณีนี้หากผู้ว่าจ้างแน่ใจในวิชาช่างที่จะพิสูจน์ได้ว่าช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ผู้รับจ้างไม่สามารถจะทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามข้อกำหนดในสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาย่อมทำได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจหรือพิสูจน์เช่นนั้นไม่ได้ ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการบอกเลิกสัญญา เพราะอาจถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๑๗๓/๒๕๒๒)^{๑๒๔} ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เห็นว่าเมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองจะไม่เลิกสัญญาทันที แต่จะให้โอกาสแก่ผู้รับจ้างโดยการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปหรือเรียกค่าปรับในระหว่างที่เกิดความล่าช้าจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ ต่อเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้แม้ว่าจะได้ขยายระยะเวลาให้แล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่นๆ ต่อไป โดยมีได้เป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ประการใด

สำหรับการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดอีกประการหนึ่ง คือ การเลิกสัญญาซึ่งกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้ว่าจ้างฝ่ายเดียวสามารถบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา ๖๐๕^{๑๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งโดยปกติหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบอก เลิกสัญญา

^{๑๒๔} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ขอรื้อหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๗๕๘-๗๕๙.

^{๑๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๕ ถ้าการที่จ้างยังไม่แล้วเสร็จอยู่ตรงใด ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น

โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทำนองที่ว่าผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาในสัญญา แต่ไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๒/๒๔๗๘) หากผู้รับจ้างยังไม่มี การผิดนัดหรือผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างก็ยังไม่สามารถใช้สิทธิขอเลิกสัญญาได้ เว้นแต่มีเหตุที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องการให้ผู้รับจ้างทำงานต่อไปแม้ผู้รับจ้างยังคงทำงานอยู่ มิได้ทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างอาจเลิกสัญญาโดยเสียค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๖๐๕ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๓/๒๔๘๘ และที่ ๔/๒๕๒๔) ดังนั้น มาตรา ๖๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปที่ว่า โดยปกติ การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจะกระทำโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวไม่ได้ นอกจากนี้ โดยนัยของมาตราดังกล่าว ยังเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมิได้ผิดสัญญา แต่ได้กำหนดให้มีการเยียวยาผลกระทบที่คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกบอกเลิกสัญญาจะได้รับ โดยการให้คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกบอกเลิกสัญญาต้องชำระค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกบอกเลิกสัญญา การให้โอกาสแก่คู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างในระหว่างสัญญาในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ผลงานที่ผู้รับจ้างกำลังทำอยู่อีกต่อไป เพราะในกรณีเช่นนี้หากให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อไปจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีและจะไม่เป็นผลดีต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรืออาจเป็นกรณีที่มีเหตุมาจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งทำให้งานก่อสร้างนั้นหมดความจำเป็นแล้ว ดังนั้น ในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๖๐๕ นี้ หากไม่มีข้อกำหนดในสัญญาเป็นอย่างอื่นแล้ว ผู้ว่าจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้กระทำผิดสัญญาแต่ประการใด ในเรื่องนี้มีตัวอย่างความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ไว้ในกรณีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (ผู้ว่าจ้าง) มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างยุติการก่อสร้างงานโยธา โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองกะวัดทองใหญ่ไว้ชั่วคราวเนื่องจากกรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาต่างกลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยผู้ว่าจ้างสามารถเรียกเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบคืนจากผู้รับจ้างได้ตามมาตรา ๓๙๑^{๑๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการเลิกจ้างและการต้องหยุดงานก่อสร้างกรณีนี้มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๓๖)^{๑๒๗}

^{๑๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่ไม่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่วันที่รับไว้

ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำและเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดเชยคืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

^{๑๒๗} โปรดอ่านรายละเอียดใน จิตติ เจริญจำ, “มีสิทธิเลิกสัญญาได้ แต่ต้องชดเชยค่าเสียหาย,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๖ (มิถุนายน ๒๕๓๗), หน้า ๒๐-๒๑.

๒.๓.๒ ผลของการเลิกสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว จะมีผลแบ่งออกได้เป็นสองกรณี คือ

๑) ผลที่กำหนดตามข้อตกลงในสัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาดอกเลิกกำหนดผลของการเลิกสัญญาเป็นประการใดไว้เป็นการล่วงหน้าโดยความยินยอมของคู่สัญญา ผลก็ควรเป็นไปตามข้อสัญญานั้นๆ ดังเช่น การกำหนดผลของการบอกเลิกสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา^{๑๒๘} ซึ่งกำหนดว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วสามารถใช้สิทธิได้ ดังนี้ (๑) เข้าทำงานที่ค้างเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ (๒) ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างนั้นและวัสดุต่างๆ (๓) รับผิดชอบการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน (๔) เรียกค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น (๕) เรียกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ (เช่น ค่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่) และ (๖) เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ดังคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้วินิจฉัยไว้ ดังนี้

- กรณีที่กรมเจ้าท่าบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาจ้างหุ่นส่วนจำกัด พ. ทำการขุดลอกร่องน้ำคลองกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ โดยสัญญาดังกล่าวถือเอากำหนดเวลาแล้วเสร็จเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญา เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา ๕๙๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และตามข้อสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้างมีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกหลักประกันและเรียกค่าเสียหาย รวมทั้งว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จตามสัญญา และเมื่อผู้ว่าจ้างได้แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่อาจจะถอนได้ตามมาตรา ๓๙๖ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๓๘)^{๑๒๙}

- กรณีกรมเจ้าท่าจ้างเหมาจ้างหุ่นส่วนจำกัด พ. ขุดลอกร่องน้ำแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง โดยตกลงถือเอาราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และให้ยึดถือระยะทางที่ขุดลอกตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญา มิใช่ปริมาณดินที่ขุดได้ ต่อมาผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานล่าช้ากว่ากำหนดและใช้อุปกรณ์เครื่องจักรไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดประกอบ การยื่นเสนอราคา แต่โดยที่ก่อนครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ สั่งให้ผู้รับจ้างระงับการขุดลอกร่องน้ำข้างสะพานด้านละ ๒๒๕ เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๕๐ เมตร ย่อมเป็นผลให้ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในงานส่วนดังกล่าวอีกต่อไป แต่ยังคงต้องรับผิดชอบในงานส่วนที่เหลือรวมเป็นระยะทาง ๓๕๐ เมตร เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังทำงานส่วนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ และได้จ้างช่วงบุคคลอื่นให้ทำงานแทนโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง กรณีจึงเป็นการกระทำผิดสัญญา ผู้ว่าจ้าง

^{๑๒๘} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๑๒๓ หน้า ๗๒

^{๑๒๙} โปรดอ่านรายละเอียดใน จรณ เจริญณา, “เลิกสัญญาเสียแล้ว จะให้ดำเนินการต่อไปไม่ได้,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๓ (พฤศจิกายน ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๔-๑๐๙.

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเอาค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ทราบคำสั่งนายช่างแขวงทางหลวงลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงที่ห้ามมิให้ขุดลอกร่องน้ำเป็นระยะทางครอบคลุมระยะทางขุดลอกตามสัญญาซึ่งทำให้การชำระหนี้ตามสัญญาเป็นพันธียตามมาตรา ๒๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าเสียหายนอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องได้ต่อเมื่อเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและพิสูจน์ได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๙๒/๒๕๓๘)^{๑๓๐}

นอกจากนี้ ยังมีแนวคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่วินิจฉัยเกี่ยวกับผลของการบอกเลิกสัญญาตามที่มีข้อสัญญากำหนดไว้ในอีกลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- กรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า แต่ผู้ว่าจ้างไม่ได้เรียกค่าปรับในระหว่างปฏิบัติงานล่าช้านับแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ต่อมาผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาจึงแจ้งสงวนสิทธิปรับไปพร้อมกันนั้น เมื่อตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้รับจ้างเฉพาะในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จภายในกำหนดเวลา โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับเป็นรายวันจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานเสร็จบริบูรณ์ แต่มิได้ตกลงให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไว้อย่างชัดเจน ผู้ว่าจ้างจึงย่อมไม่มีสิทธิปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันจนถึงวันบอกเลิกสัญญา (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๓๙)^{๑๓๑}

๒) ผลที่กำหนดโดยกฎหมาย โดยทั่วไปเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วจะไม่สามารถถอนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง^{๑๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการเลิกสัญญาดังกล่าวทำให้คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑^{๑๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. จำปี โสคติพันธุ์ ได้ให้คำอธิบายว่า “การบอกเลิกสัญญาส่งผลให้สัญญาจะรับย้อนหลังไปตั้งแต่วันทำสัญญา ฐานใดๆ ที่จะรองรับการชำระหนี้ที่ได้กระทำไปแล้วจึงไม่มีอยู่อีกต่อไป กฎหมายจึงกำหนดให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิมด้วยการคืนสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้รับไว้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมด (status quo ante) โดยต่างฝ่ายต่างคืนสิ่งที่ตนได้รับไปแล้วทั้งหมด (restitution in intergrum)”^{๑๓๔} หลักการดังกล่าวนี้เป็นไปตามหลักของสัญญาต่างตอบแทนซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องคืนสิ่งที่ได้รับไว้ให้ตอบแทนสิ่งที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้คืนกลับมา ถ้ามีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมส่งคืน คู่สัญญาอีกฝ่ายก็ปฏิเสธที่จะส่งคืนได้เช่นกัน ทั้งนี้สิ่งที่คู่สัญญาต่างต้องชำระคืนให้แก่กันเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม ได้แก่^{๑๓๕}

^{๑๓๐} โปรดอ่านรายละเอียดใน รชฎ เจริญจำ, “ทำงานไม่เสร็จตามสัญญา บอกเลิกได้,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๐ (มิถุนายน ๒๕๓๘), อ้างแล้ว, หน้า ๓๗-๔๒.

^{๑๓๑} โปรดอ่านรายละเอียดใน รชฎ เจริญจำ, “เลิกสัญญาที่ยอมจ่ายค่างานบางส่วน,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๘), หน้า ๕๑-๕๕.

^{๑๓๒} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๑๐๗ หน้า ๖๓

^{๑๓๓} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๑๒๖ หน้า ๗๔

^{๑๓๔} จำปี โสคติพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗/๒-๓๗/๓.

^{๑๓๕} ศักดิ์ สนองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, อ้างแล้ว, หน้า ๔๘๓-๔๘๔.

๒.๑) ทรัพย์สินที่ได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่กันไปตามสัญญา ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีการส่งมอบหรือโอนโดยการคืนทรัพย์สินนั้น ถ้าเป็นพันวิสัยที่จะคืนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ต้องชดเชยค่าเสียหาย

๒.๒) เงินที่ชำระแก่กันตามสัญญา ผู้รับต้องคืนเงินนั้นพร้อมด้วย ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินไว้

๒.๓) การงานที่ได้กระทำให้แก่กันตามสัญญาซึ่งโดยสภาพไม่อาจคืนเป็นตัวเงินได้ ต้องใช้เงินทดแทนตามควรค่าแห่งงานนั้น ถ้าในสัญญาได้กำหนดจำนวนเงินที่จะใช้ตอบแทนกันไว้ก็ให้เป็นไปตามนั้น คำว่า “การงานที่ได้กระทำให้แก่กัน” เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง โดยอาจเป็นวัตถุแห่งหนึ่งที่มีใช่เป็นการส่งมอบทรัพย์สิน แต่เป็นการกระทำ ก็ย่อมเป็นการงานที่ได้กระทำได้ เช่น ลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้าง ผู้รับจ้างทำการงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น ดังตัวอย่างคำวินิจฉัยต่อไปนี้

- ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนเสร็จแล้วให้ผู้ว่าจ้างเช่าอาคารนั้นได้ ผู้รับจ้างปลูกสร้างอาคารผิดแบบแปลน ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องคืนที่ดินและอาคารให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องชดเชยค่าก่อสร้างตามผลงานแก่ผู้รับจ้างที่ได้สร้างลงไปแล้ว จะให้ผู้รับจ้างรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปก็เท่ากับไม่ได้คืนสู่ฐานะเดิม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕/๒๕๒๑) ทั้งนี้ เพราะวัตถุแห่งหนึ่งในคดีนี้ก็คือ การที่ผู้รับจ้างต้องปลูกสร้างอาคารให้ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นการกระทำ มิใช่ส่งมอบทรัพย์สิน จึงต้องชดเชยเงินเป็นค่าการงาน มิใช่โดยการคืนทรัพย์สินโดยให้รื้อถอนออกไป ส่วนการงานที่ได้กระทำจะมีค่าที่สมควรเพียงใดนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่ง

- กรณีผู้รับจ้างรับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลตามสัญญาจ้างที่ทำไว้กับผู้ว่าจ้างแต่ไม่ได้ปริมาณน้ำตามที่กำหนดในสัญญา สัญญาจึงเลิกกันตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ได้น้ำไม่ครบปริมาณตามสัญญา อันหมายความว่ามิได้ให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์ได้อยู่ หากขุดเจาะได้น้ำตามสัญญา กรณีผิดสัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นและผู้ว่าจ้างก็ต้องใช้ค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนั้น กรณีนี้ผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้ค่าแห่งการงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำไปตามมาตรา ๓๙๑ ให้แก่ผู้รับจ้าง แม้จะมีข้อสัญญาระบุให้ผู้รับจ้างต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปจากผู้ว่าจ้าง ก็หาได้หมายความว่าผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องใช้ค่าแห่งการงานให้ผู้รับจ้างแต่ประการใด ซึ่งค่าแห่งการงานนี้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควร (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๒๒/๒๕๒๘)

๒.๔) การยอมให้ใช้ทรัพย์สินตามสัญญา โดยสภาพก็ไม่อาจคืนให้แก่กันได้ จึงต้องชดเชยเงินแทนตามสมควรแก่ค่าของการใช้ทรัพย์สินนั้น ถ้าในสัญญาได้กำหนดจำนวนเงินที่จะใช้ตอบแทนไว้ก็ให้เป็นไปตามนั้น (โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อ ๒.๕.๒ การเข้าใช้ประโยชน์ในงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในหน้า ๘๓)

ในเรื่องการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของคู่สัญญาภายหลังการบอกเลิกสัญญานี้ คู่สัญญาอาจตกลงยกเว้นไม่ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมไว้ก็ได้ เช่น กรณีที่คู่สัญญาตกลงไว้ว่า ถ้ามีการเลิกสัญญาให้ผู้ว่าจ้างรับภาระงานที่ทำไว้แล้วได้ทั้งหมดโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุผู้รับจ้างผิดสัญญา

ผู้ว่าจ้างสามารถรับงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้แล้วทั้งหมดได้โดยไม่ต้องชดใช้ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิม (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๐๕-๓๐๐๖/๒๕๑๗ และที่ ๒๐๒๖/๒๕๓๗) โดยที่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ นี้มีหลายกรณีด้วยกันดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๒.๑) ถึง ข้อ ๒.๔) อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สมองชาติ ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า “หากคู่สัญญาจะตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่จำเป็นต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ย่อมทำได้ทุกอย่าง มิใช่เฉพาะให้รับการทำงานโดยไม่ต้องชดใช้ค่าแห่งงานเท่านั้น”^{๑๓๖}

๒.๔ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย

การเลิกสัญญามีได้ทำให้ผู้ว่าจ้างในฐานะเจ้าหนี้หมดสิทธิเรียกค่าเสียหาย โดยมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติไว้ว่า การใช้สิทธิเลิกสัญญาหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ เพราะเมื่อสัญญาระงับเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาไปแล้ว คู่สัญญายังมีความรับผิดชอบร่วมกันอยู่ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาได้ระงับไปแล้ว คงเหลือแต่ความรับผิดชอบในความเสียหายเพราะผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ต้องให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยต่อไป ซึ่งในเรื่องของความเสียหายนี้ มีผู้ให้คำอธิบายว่าสามารถพิจารณาได้เป็นสองนัย^{๑๓๗} ได้แก่

ก. ค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ชำระหนี้อันเป็นค่าเสียหายก่อนการบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะมีจำนวนเท่าใดนั้น เป็นเรื่องที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญาต้องฟ้องและพิสูจน์ให้ศาลเห็นความเสียหายที่แท้จริง

ข. ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญา หมายความว่า การที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญาได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ต้องได้รับความเสียหายอย่างไร ก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาได้ ดังตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้

- แม้จะฟังได้ว่าผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้รับเหมารายใหม่ในราคาที่สูงขึ้นจากสัญญาเดิมที่ผู้ว่าจ้างได้จ้างผู้รับจ้างจริง แต่เงินจำนวนนี้ตามข้อสัญญากำหนดไว้ว่า “ค่าเสียหายในเบื้องต้นก็คือ เงินค่าจ้างของผู้รับจ้างรายใหม่ที่เกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างที่เหลือซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง” ดังนี้ เงินจำนวนดังกล่าวจึงถือว่าเป็นค่าเสียหายในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาเช่นกัน เกี่ยวกับค่าเสียหายนี้ ศาลได้กำหนดให้ผู้รับจ้างชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างซึ่งสูงกว่าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ้างผู้รับเหมารายใหม่ในราคาที่สูงขึ้นแล้ว ทั้งผู้ว่าจ้างนำสืบไม่ได้ว่าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอย่างไร ประกอบกับตามสัญญาจ้างมีข้อสัญญากำหนดไว้ว่า ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดใช้แต่ค่าปรับอย่างเดียวหรือค่าเสียหาย กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๓๙๐ วรรคสอง^{๑๓๘} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้

^{๑๓๖} ศักดิ์ สมองชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา, อ่างแล้ว, หน้า ๔๘๖.

^{๑๓๗} โปรดอ่านใน จำปี โสติพิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, อ่างแล้ว, หน้า ๓๗๖.

^{๑๓๘} โปรดดูในเชิงอรรถที่ ๘๕ หน้า ๔๙

จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้นท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้” เมื่อผู้ว่าจ้างไม่อาจพิสูจน์ความเสียหายยิ่งกว่าค่าปรับที่ศาลกำหนดให้ ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างอีกได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๗/๒๕๔๐)

- ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างเหมาก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างได้ และในสัญญายังกำหนดด้วยว่า ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการต่อไปจนงานจ้างเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ ดังนี้ ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญา แม้จะมีเบี้ยปรับที่ผู้รับจ้างสัญญาแก่ผู้ว่าจ้างว่าจะใช้ให้เมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ตาม แต่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าวต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้น ศาลจึงมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ไปตามความเสียหายที่แท้จริงได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๐๔/๒๕๓๘)

- ตามข้อสัญญามีสาระสำคัญว่า ถ้าผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย โดยผู้รับจ้างยอมจ่ายเงินค่าจ้าง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นใดตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีข้อสัญญาอื่นกำหนดว่า ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้เรียกค่าเสียหายอันพึงมีได้อีกด้วย เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าหลังจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างรายใหม่ได้ทำการก่อสร้างงานตามสัญญาต่อจากผู้รับจ้างจนงานเสร็จบริบูรณ์แล้วหรือไม่ แต่ตามข้อสัญญาจ้างเหมาตนเองแสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนว่า หากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างยอมมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำการก่อสร้างงานแทนผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายและผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการที่ต้องเสียค่าจ้างสูงขึ้นโดยมิพักต้องรอให้งานก่อสร้างที่กระทำภายหลังต้องเสร็จเสียก่อน เพราะเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้าง โดยเฉพาะเมื่อต่อมาผู้ว่าจ้างได้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ก่อสร้างงานส่วนที่เหลือในอัตราที่สูงกว่าราคางานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างค้างอยู่ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้รับจ้างรายใหม่ก่อสร้างไปแล้วเพียงใด แต่เมื่อคำนึงถึงความเป็นไปทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าจ้างต้องได้รับความเสียหายอันควรได้รับการชดเชยจากผู้รับจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๒๖/๒๕๓๗)

ตามหลักในการใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างภายหลังการบอกเลิกสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างเนื่องจากต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในราคาที่สูงขึ้นนั้น ผู้ว่าจ้างไม่สามารถใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายได้อย่างอิสระ แต่จะเรียกค่าเสียหายได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและผู้ว่าจ้างต้องพิสูจน์ในศาลเห็นดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น หากผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายไว้สูงมากกว่าความเสียหายที่แท้จริง หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่เหลือต่อจากผู้รับจ้างรายเดิมโดยไม่มีค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น ศาลก็จะไม่สั่งให้ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ดังคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ว่า หากปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้ไปจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือ

โดยเสียค่าใช้จ่ายพอกับที่จะจ่ายให้ผู้รับจ้างหากผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ว่าจ้างก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย คงเรียกได้เฉพาะค่าปรับ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๖๔/๒๕๒๓)^{๓๙}

- กรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ทำการปรับปรุงที่ดินก่อสร้างอาคารควบคุม บ้านพักพนักงาน รั้ว ถนน ท่อประปา รางเคเบิล ท่อร้อยสายเคเบิลและฐานราก Station Service Transformer ที่สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างตกลงยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือนค่าครองชีพ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักหรือค่าล่วงเวลาในระหว่างที่ผู้รับจ้างถูกปรับจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานได้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญาได้ ต่อมาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วบางส่วน แต่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าจ้างสำหรับงานส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วและไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามควรค่าแห่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้วบางส่วนก็เพื่อให้คู่สัญญาได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๓๙)^{๔๐}

ความแตกต่างระหว่างค่าปรับและค่าเสียหาย

เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงอาจเปรียบเทียบความแตกต่างของสิทธิทั้งสองประการดังกล่าวได้ ดังนี้

“เบี้ยปรับ” หรือ “ค่าปรับ” เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาให้กำหนดไว้ในข้อสัญญาได้ เจ้าหนี้จะสามารถเรียกค่าปรับได้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ยังไม่มีการบอกเลิกสัญญา หรือเรียกได้ว่าเป็น “ค่าปรับตามสัญญา” ในขณะที่ค่าเสียหายเป็นสิทธิที่เกิดโดยผลของกฎหมาย ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการบอกเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ชำระหนี้ ทั้งนี้ ค่าเสียหายประเภทนี้จะกำหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ก็ได้ โดยส่วนใหญ่หากมีการกำหนดไว้ในสัญญาก็มักจะเป็นค่าปรับ ดังนั้น เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาฝ่ายที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาสามารถได้รับทั้งค่าปรับและค่าเสียหาย (คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๒๙/๒๕๑๗ และที่ ๑๐๙๑/๒๕๖๒)

ด้วยค่าปรับและค่าเสียหายมีความแตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงสามารถใช้สิทธิเรียกทั้งค่าปรับและค่าเสียหายควบคู่กันได้ มิได้มีความซ้ำซ้อนกัน

^{๓๙} โปรดอ่านรายละเอียดใน จิตติ เจริญน้ำ, “การเลิกสัญญาที่มีสิทธิเข้าใช้งาน,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๕ (พฤษภาคม ๒๕๓๗), หน้า ๓๓-๓๕.

^{๔๐} โปรดอ่านรายละเอียดใน รชฎ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาที่ยอมจ่ายค่างานบางส่วน,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๙), หน้า ๕๑-๕๕.

แต่ประการใด ดังเช่น คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาไว้ว่า หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดอันเป็นการผิดสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันได้ตามสัญญา นอกจากนั้นแล้ว ถ้าหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายตามสัญญาจากผู้รับจ้างได้อีกด้วย ซึ่งสิทธิที่จะเรียกเอาค่าปรับเป็นรายวันและสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายดังกล่าว แม้จะเป็นสิทธิที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างข้อเดียวกันก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสิทธิที่แยกต่างหากจากกัน กล่าวคือ เป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเลือกใช้สิทธิดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงกรณีเดียวหรือเลือกใช้สิทธิดังกล่าวทุกกรณีก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๘๗/๒๕๔๐ ที่ ๓๑๘๐/๒๕๔๑ และที่ ๓๓๕๒/๒๕๔๒) และคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการเดิม) ในกรณีที่เทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี (ในขณะนั้น) ทำสัญญาจ้างบริษัท จ. ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย ๔ โรง แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เดือนตามกำหนดเวลาในสัญญาและยังคงทำงานตามสัญญาอยู่ต่อไป ทั้งที่ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวมากกว่า ๓ ปีแล้วในขณะที่มีการส่งเรื่องเข้าหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด แต่คู่สัญญาต่างยังมิได้บอกเลิกสัญญาต่อกัน โดยผู้ว่าจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างทั้งหมด สัญญาจ้างดังกล่าวจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ แต่ด้วยวัตถุประสงค์แห่งสัญญาก่อสร้างโดยสภาพและโดยเจตนาของคู่สัญญาแสดงไว้ชัดแจ้งว่า สัญญานี้จะเป็นผลสำเร็จได้ด้วยการชำระหนี้ของผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ เดือน แต่กำหนดเวลาดังกล่าวได้ล่วงพ้นมาถึง ๓ ปีเศษ ซึ่งตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิได้เบี้ยปรับเพียง ๙๐ วันเท่านั้น ผู้ว่าจ้างจึงชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตามมาตรา ๓๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการใช้สิทธิดังกล่าวหากระทบกระเทือนถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดไม่ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอาจเป็นปัญหาในภายหลังและเป็นข้ออ้างให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบประการได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด เลขรับที่ ห.๑๔๖/๒๕๑๗)^{๔๑}

อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ว่าจ้างในการเรียกค่าเสียหายมิได้มีแต่เฉพาะในกรณีที่คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาจ้างเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ผ่อนผันการบอกเลิกสัญญาออกไปเมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และต่อมาผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบล่าช้าไว้ ผู้ว่าจ้างยังสามารถเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าควบคุมงานได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้การเรียกค่าเสียหายเช่นนี้จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ดังเช่น ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๗ ค่าปรับ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระทั้งค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับแต่วันถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย

^{๔๑} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๗๐-๗๑.

ในการควบคุมงานด้วย ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการเดิม) ได้เคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ว่า เมื่อคู่สัญญาผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งชอบที่จะใช้สิทธิเรียกเบี้ยปรับและค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าเบี้ยปรับได้ แต่ถ้าคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเบี้ยปรับและค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ก็ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๖๑/๒๕๒๐)^{๑๔๒}

๒.๕ การใช้สิทธิเรียกร้องอื่น ๆ

๒.๕.๑ การริบหลักประกันสัญญา

ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดำเนินการ ๑๘ กำหนดว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียกค่าเสียหาย อันได้แก่ ๑) ริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ๒) เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มในการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานส่วนที่เหลือ ๓) เรียกค่าควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ในส่วนของหลักประกันสัญญานั้น ตามข้อ ๑๔๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดำเนินการ กำหนดไว้ว่า หลักประกันสัญญา^{๑๔๓} ควรใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๑) เงินสด ๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด และ ๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งมีผู้ให้คำอธิบายว่า หลักประกันตามสัญญาอาจเป็นเงินหรือหลักทรัพย์ที่วางไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญา เจ้าหนี้จะสามารถเรียกหรือหักเอาจากเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้เป็นประกันได้เพื่อเอาไปชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้น หากเป็นการวางเงินไว้เป็นประกัน เจ้าหนี้ก็สามารถหักเอาชำระหนี้ได้เลย ทั้งนี้ หนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาในที่นี้หมายถึงหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาโดยตรง หรือชำระหนี้ล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาในสัญญา หรือหนี้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ส่งมอบเกิดความชำรุดบกพร่องขึ้นตามที่กำหนดไว้ หรือหนี้ที่เกิดจากการรอนสิทธิก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญา เจ้าหนี้จึงสามารถเอาเงินประกันที่วางไว้นั้นมาชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการริบหลักประกันเพื่อใช้หนี้อย่างหนึ่ง หลักประกันดังกล่าวแล้วมาข้างต้นแตกต่างจากเบี้ยปรับและมิใช่เบี้ยปรับ เพราะเงินประกันที่วางไว้ก็เพื่อชำระ

^{๑๔๒} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๓๑๐.

^{๑๔๓} หลักประกันสัญญาแตกต่างจากมัดจำ แม้ว่าการวางมัดจำเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่มัดจำจะเป็นเงินหรือสิ่งของที่เป็นสังหาริมทรัพย์ที่ส่งมอบให้แก่กันได้ ทั้งนี้ หากสิ่งของที่คู่สัญญานำมาวางมัดจำไม่ได้มีค่าในลักษณะที่จะผูกมัดให้คู่สัญญาปฏิบัติตามแล้ว ของสิ่งนั้นไม่มีลักษณะเป็นมัดจำ เช่น หนังสือค้ำประกันที่ธนาคาร (bank guarantee) ทำให้ไว้เมื่อผู้รับเหมาทำสัญญาก่อสร้าง ไม่ใช่มัดจำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๒๒/๒๕๑๓ และที่ ๑๑๒/๒๕๓๖) (โปรดอ่านใน จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหนา จ้างทำของ รับขน, พิมพ์ครั้งที่ ๕ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม), ๒๕๔๓, หน้า ๑๑๘ และ ๑๒๑) ในขณะที่หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศจะใช้เป็นหลักประกันสัญญาได้

หนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาเท่านั้น แต่เบี้ยปรับเป็นกรณีที่ถูกหนี้ให้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้เป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ โดยอาจจะวางเงินเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้าก็ได้ เงินที่วางไว้จึงจัดเป็นเงินประกันการชำระหนี้เบี้ยปรับ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้อง เจ้าหนี้สามารถริบเอาเบี้ยปรับนั้นได้ ส่วนการใช้สิทธิริบหลักประกันที่ถูกหนี้วางไว้ตามสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อลูกหนี้ผิดนัดหรือผิดสัญญาแล้ว หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดหรือได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ก็ถือว่าไม่มีหนี้ที่อาจเรียกร้องได้เกิดขึ้น เจ้าหนี้จึงยังไม่สามารถริบหลักประกันได้^{๑๔๔}

กรณีการใช้สิทธิริบหลักประกันตามสัญญาจ้างนี้ มีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา และคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดในการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น

- เงินประกันความรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง ซึ่งมีข้อสัญญาระบุว่า ให้ใช้เงินนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติงานรับจ้างของผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันความรับผิดชอบของธนาคารมาวางเป็นประกันไว้แก่ผู้ว่าจ้างตั้งแต่วันทำสัญญาแล้วเงินตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวจึงไม่ใช่เงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างจะริบได้เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญา แต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายฐานผิดสัญญา ดังนั้น เงินจำนวนนี้ผู้รับจ้างจึงมีสิทธินำไปหักกับจำนวนเงินค่าเสียหายที่เป็นค่าปรับที่ศาลได้กำหนดให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ตามมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๗/๒๕๕๐ และที่ ๖๖/๒๕๕๒)

- เมื่อส่วนราชการได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานจ้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ แต่ปรากฏว่าราคาค่าจ้างสูงกว่าราคาที่ทำไว้ตามสัญญาเดิม ราคที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมเป็นค่าเสียหายที่ส่วนราชการพึงได้รับชดเชยคืนจากผู้รับจ้างรายเดิม ซึ่งธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันในสัญญาจ้างเดิมจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันทันที โดยส่วนราชการไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างเดิมชำระก่อน ส่วนค่าเสียหายนอกจากนั้น ส่วนราชการจะต้องเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างรายเดิม (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๑๕๖/๒๕๒๔)^{๑๔๕}

- กรณีที่กรมประชาสัมพันธ์ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยที่ซอยอารี แต่ต่อมามีเหตุจำเป็นต้องย้ายสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ จึงได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าเริ่มทำงานตามงวดงานแต่อย่างใด และยังปรากฏข้อเท็จจริงที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาได้ กรมประชาสัมพันธ์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาได้ และโดยที่ผู้รับจ้างได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้แม้แต่วางเดียว ผู้ว่าจ้างจึงย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างและธนาคารผู้ค้ำประกันจ่ายคืนเงินล่วงหน้า (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๓๔/๒๕๒๕)^{๑๔๖}

^{๑๔๔} โปรดอ่านใน จิตติ เจริญน้ำ, “เบี้ยปรับกับหลักประกันสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๕ (พฤษภาคม ๒๕๓๗), หน้า ๔๐-๔๑.

^{๑๔๕} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๔๔.

^{๑๔๖} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๔๖๑-๑๔๖๒.

- เมื่อคู่สัญญายินยอมเลิกสัญญากัน คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิรับหลักประกันสัญญาเพราะคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุที่จะอ้างได้ว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใด ผู้ว่าจ้างย่อมไม่มีสิทธิรับเงินประกันสัญญา แต่ถ้าอ้างได้ว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใด ผู้ว่าจ้างอาจเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้โดยเรียกเอาค่าเสียหายจากธนาคารผู้ค้ำประกัน แต่ผู้ว่าจ้างจะรับเงินประกันสัญญามีได้เพราะเงินประกันสัญญา มิใช่มัดจำตามกฎหมายและสัญญาก็มิได้ระบุให้รับแต่อย่างใด (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด เลขรับที่ พ.๔๔/๒๕๒๐)^{๑๔๗}

๒.๕.๒ การเข้าใช้ประโยชน์ในงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเพราะผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ทำให้อาจมีทั้งงานที่ก่อสร้างไปแล้วบางส่วนและงานที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จค้างอยู่และผู้ว่าจ้างยังประสงค์ในผลสำเร็จของงานนั้น ซึ่งในกรณีเช่นนี้ มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จากงานที่แล้วเสร็จบางส่วน ส่วนงานที่ยังค้างอยู่ ผู้ว่าจ้างอาจเข้าทำการก่อสร้างเองหรือว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จก็ได้ แต่เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้จัดหาไว้แล้วในพื้นที่ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ แต่กระนั้น การที่ผู้ว่าจ้างจะรับเอางานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนไว้ใช้ประโยชน์หรือไม่ ก็ต้องพิจารณาด้วยว่างานดังกล่าวนั้นเป็นงานที่เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยไม่บังคับว่าผู้ว่าจ้างต้องรับเอางานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนไว้ในทุกกรณี โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

๑) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาพของงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน

๑.๑) กรณีงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วบางส่วนเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างย่อมได้กรรมสิทธิ์ในงานดังกล่าวด้วยการชำระค่าแห่งการทำงานให้แก่ผู้รับจ้าง

จากหลักที่ว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น กฎหมายมีเจตนาให้ผลภายหลังการเลิกสัญญา คือ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ฐานะเดิมเหมือนไม่เคยมีการทำสัญญาต่อกันประดุจว่าไม่เคยมีนิติกรรมเกิดขึ้นในระหว่างคู่กรณี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒/๒๕๑๘) แต่ในทางปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าหลักการให้คู่สัญญาตามสัญญาจ้างก่อสร้างกลับคืนสู่ฐานะเดิมยังมีข้อจำกัดเพราะไม่สามารถให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ทั้ง

^{๑๔๗} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ขอรื้อหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๔.

หมดเสมือนไม่เคยมีสัญญาต่อกันมาก่อนจริง เนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นการว่าจ้างให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารลงบนที่ดิน หากจะให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมก็ต้องรื้อถอนออกไปเพื่อส่งคืนที่ดินเปล่าตามสภาพก่อนลงมือก่อสร้าง ซึ่งการกระทำเช่นนี้ย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับหรือหากเป็นงานก่อสร้างที่มีความชำรุดบกพร่องเล็กน้อยก็สามารถซ่อมแซมแก้ไขเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะคืนให้แก่กันได้ ประกอบกับการงานที่ได้ทำหรือก่อสร้างไว้แล้วก่อนเลิกสัญญาจัดเป็นวัตถุที่ติดอยู่กับที่ดิน การรื้อถอนจึงกระทำมิได้ ผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้ค่าแห่งการงานให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อตอบแทนผลงานที่ได้ทำไปแล้วตามสมควร โดยอาจประเมินค่าแห่งการงานนั้นในกรณีที่ไม่สามารถตีมูลค่าได้ชัดเจนแน่นอน ทั้งนี้ การใช้สิทธิตามหลักการในข้อนี้ยังต้องพิจารณาด้วยว่างานก่อสร้างที่จะยึดหรือรับไว้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างหรือไม่เพียงใด

กรณีเช่นนี้ได้เคยมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ว่า ส่วนการงานที่ผู้รับจ้างได้ทำให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องชดใช้เงินตามสมควรแก่ค่าแห่งการงานนั้นๆ การที่จะให้หรือสัณหาออกไปย่อมเสียหายแก่ผู้รับจ้างอย่างมาก การก่อสร้างที่ทำไปแล้วเชื่อว่าจะใช้ไม่ได้เสียเลย ผู้ว่าจ้างยังแก้ไขประโยชน์ได้ จึงให้ผู้ว่าจ้างรับเอาสิ่งปลูกสร้างและใช้ค่าการงานเป็นเงินให้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๕/๒๕๑๒, ที่ ๖๔๙/๒๕๑๓, ที่ ๙๘๒/๒๕๑๓, ที่ ๒๗๖๙/๒๕๑๙, ที่ ๒๘๗/๒๕๒๔, ที่ ๒๘๒๑/๒๕๒๒ และที่ ๕๗๒/๒๕๒๕)^{๑๔๘} ดังนั้น การคืนสิ่งก่อสร้างที่ได้ทำไปแล้วโดยในทางกฎหมายจึงไม่ใช่การรื้อถอนเอาไปแต่ต้องใช้เงิน เพราะการรื้อถอนเอาไปก็เท่ากับไม่ได้คืนสู่ฐานะเดิมด้วย เมื่อรื้อถอนก็จะเสียหายหมดจึงทำให้คืนดังเดิมไม่ได้ในเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ว่า เมื่อผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว กรณีต้องนำบทบัญญัติตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาปรับใช้แก้คดีด้วยการให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม บรรดาการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดใช้คืนด้วยการให้เงินตามควรค่าแห่งการงานนั้นๆ แต่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างลงในที่ดินของผู้ว่าจ้างแล้ว การที่จะให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ก็ด้วยการที่ผู้รับจ้างต้องคืนที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าก่อสร้างอันเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำลงแล้วเท่านั้น จะให้คืนฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมโดยให้ผู้รับจ้างต้องรื้อสิ่งก่อสร้างออกไปโดยผู้ว่าจ้างมิได้ชดใช้ค่าก่อสร้างอันเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างทำลงไปแล้วให้ผู้รับจ้างไม่ได้เพราะเท่ากับผู้รับจ้างไม่ได้คืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมเนื่องจากต้องเสียหายแต่ฝ่ายเดียว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๕/๒๕๒๑) งานที่ก่อสร้างไปแล้ว เวลาคืนสู่ฐานะเดิมกฎหมายจึงบังคับให้ชดใช้ค่าการงานคืนเท่านั้น ซึ่งจะต้องคิดคำนวณเป็นเงินว่าจะต้องใช้คืนกันเท่าใดตามควรแก่ค่าแห่งการงานนั้นๆ เพราะงานที่ทำไปแล้วนั้นมิได้ผิดสัญญาและเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างโดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้น หากมีผู้อื่นมารับจ้างก่อสร้างต่อไป ผู้รับจ้างรายใหม่

^{๑๔๘} โปรดอ่านใน รชฎ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาที่ยอมจ่ายค่างานบางส่วน,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๙), หน้า ๕๗.

ก็จะใช้ผลงานที่ทำไว้แล้วนั้นต่อไปได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๒๑/๒๕๒๒) ไม่ใช่กรณีที่
ไม่ทำงานเลยจนถึงกับทำให้มีสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าจ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๑๕-๒๒๑๖/๒๕๒๒)
นอกจากนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างต้องใช้ค่าแห่งการงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้วตามมาตรา ๓๙๑ ก็สามารถ
หักกลบลบกันได้กับเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างไปก่อนแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔/๒๕๒๔)
เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับ
คืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น การให้ผู้
สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ผู้รับจ้างต้องคืนเงินค่าจ้างเต็มที่ที่ได้รับไปแล้วแก่ผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้ว่า
จ้างก็ต้องคืนสิ่งของต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งให้ผู้ว่าจ้างแก่ผู้รับจ้างด้วย แต่ปรากฏว่าสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่จะต้องคืนให้แก่ผู้รับจ้างนั้น ผู้ว่าจ้างได้นำไปใช้แล้วเป็นเวลาถึง ๑๘ เดือน
ทั้งผู้รับจ้างก็ได้ลงทุนลงแรงขุดเจาะน้ำบาดาลจนให้ผู้ว่าจ้างมีน้ำใช้บริโภคได้ เมื่อเป็นดังนี้
การคืนเงินของผู้รับจ้างให้แก่ผู้ว่าจ้างจึงต้องหักจำนวนเงินค่าเสื่อมราคาสิ่งของเพื่อชดเชยให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมกับค่าการงานในการติดตั้งให้ผู้รับจ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๑๘/๒๕๑๑)

๑.๒) กรณีงานที่ก่อสร้างเสร็จแล้วบางส่วนไม่เป็นประโยชน์แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องรับผลงานเอาไว้และไม่ต้องชำระค่าแห่งการงาน

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดตามสัญญา ถ้างานที่ทำแล้วเสร็จบางส่วนนั้นเป็นงานที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างอยู่บ้าง ย่อมเป็นการสมควรที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าแห่งการงานให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ถ้านั้นไม่เป็นประโยชน์หรืออาจก่อความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างได้ในภายหลัง ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องชำระค่าแห่งการงานที่ได้ทำไปนั้น ดังเช่น ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโดยไม่ได้มาตรฐานตามแบบรูปหรือรายการ หรือใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาต่าง ๆ ในเรื่องนี้ที่วินิจฉัยว่า ถ้าการงานที่ทำไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างเลยและผู้ว่าจ้างเองก็มีได้รับมอบงานที่ทำแล้วนั้นไว้ ผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยคืนในส่วนนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๘/๒๕๒๔) เพราะไม่มีอะไรจะต้องคืนนั่นเอง การใช้เงินค่าก่อสร้างเป็นเพียงให้ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๒/๒๕๒๕) เมื่องานก่อสร้างนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยก็เท่ากับไม่มีการงานที่จะต้องคืนต่อกัน เช่น ฐานรากที่ก่อสร้างบางกว่าแบบแปลนจะแก้ไขให้ถูกต้องไม่ได้นอกจากรื้อทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่ จึงไม่มีประโยชน์ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดกำไรและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่จะคืนให้ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๖๙/๒๕๒๑)^{๑๔๔}

๒) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการให้กรรมสิทธิ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนตกเป็นของผู้ว่าจ้าง

ในส่วนของการให้งานที่ผู้รับจ้างทำไปแล้วบางส่วนและเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง นั้น สามารถแบ่งได้เป็นสองกรณี ได้แก่ การให้

^{๑๔๔} จิตติ เจริญน้ำ, “การเลิกสัญญาที่มีสิทธิเข้าใช้งาน,” วารสารอัยการ, อ่างแล้ว, หน้า ๓๕.

กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และการให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของ ผู้ว่าจ้างตามข้อสัญญาที่จัดทำระหว่างคู่สัญญาอันถือเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินเพื่อเป็นเบี้ยปรับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑) กรณีกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างตามหลักกฎหมาย

กรณีนี้งานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างเพราะผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าจ้างตามงวดงานแล้วอันเป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาตามหลักสัญญาต่างตอบแทน ดังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

- กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานงวดที่หนึ่งเสร็จและรับเงินไปแล้ว แต่ทำงานงวดที่สองไปเพียงบางส่วนและทำงานงวดที่สามเสร็จแล้ว ผู้ว่าจ้างถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาจึงบอกเลิกสัญญาและไม่ยอมชำระเงินค่างวดสองงวดที่ค้าง กรณีนี้เมื่อมีการเลิกสัญญาต่อกันแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลให้ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างหมดพันธะในอันที่ต้องพึงปฏิบัติต่อกัน ส่วนที่เป็นการทำงานที่ผู้รับจ้างได้กระทำและยอมให้ผู้ว่าจ้างได้ใช้ทรัพย์สินนั้น แม้ตามสัญญาจะไม่มีข้อกำหนดให้ชดใช้ค่าตอบแทนในเรื่องนี้ไว้ก็ตาม แต่ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้คืนด้วยการใช้เป็นเงินตราตามควรค่าของผลงานที่ทำตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๑๔/๒๕๒๓)^{๔๐}

- กรณีที่กองทัพเรือโดยเจ้ากรมอู่ทหารเรือได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ทำการก่อสร้างหลักเทียบเรือจำนวน ๒ คู่ (๔ หลัก) พร้อมสะพานทางเดิน ระบบไฟฟ้า ประปาและเสาธงราชนาวีจำนวน ๑ เสา รวม ๑๐ งวดงาน โดยผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีรวม ๒ ครั้ง แต่ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จได้เพียง ๗ งวด ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและขอให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับและริบหลักประกันของ พร้อมเรียกค่าเสียหายตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างได้ยื่นข้อเสนอขอมอบทรัพย์สินที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนตามสัญญาในงวดที่ ๑๐ ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อหักกลบลบหนี้กับความเสียหายของทางราชการเนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ หากทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าความเสียหายที่ทางราชการได้รับ ขอให้ผู้ว่าจ้างยุติการเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญา พร้อมคืนหนังสือค้ำประกัน ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า เมื่อกองทัพเรือใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว หลักเทียบเรือที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบแล้วถึงงวดที่ ๗ และงานก่อสร้างในงวดที่ ๑๐ ซึ่งแล้วเสร็จบางส่วนได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพเรือแล้วตามข้อสัญญา กองทัพเรือมีสิทธิเข้าใช้หลักเทียบเรือดังกล่าวได้ รวมทั้งริบหลักประกัน เรียกค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้รับจ้างตามสัญญาข้ออื่นๆ ได้ด้วย ผู้รับจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากกองทัพเรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพเรือดังกล่าว แต่การเข้าใช้ประโยชน์จากหลักเทียบเรืออาจเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้แก่กอง

^{๔๐} รพฐ เจริญจำ, “เลิกสัญญาที่ยอมจ่ายค่างานบางส่วน,” วารสารอัยการ, อ้างแล้ว, หน้า ๕๗.

ทัพเรือให้น้อยลงจากที่กำหนดไว้ในสัญญาก็ได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๘/๒๕๓๖)^{๑๕๑} ซึ่งกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานเป็นงวดๆ รวม ๗ งวด และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานในแต่ละงวดพร้อมทั้งชำระค่าจ้างตามงวดงานในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว อันมีผลทำให้งานก่อสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีค่างานค้างจ่าย ยกเว้นผลงานที่ได้ทำไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จในงวดอื่นๆ ที่เหลือ ดังนั้น กองทัพเรือในฐานะผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิในงานก่อสร้างและเข้าใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือได้ด้วยเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นให้เป็นเบี้ยปรับที่มีใช้เงิน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้าง หากแต่ยังต้องถูกริบหลักประกัน ชำระค่าปรับ และค่าเสียหายอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

- กรณีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ว่าจ้างบริษัท ป. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ แต่ผู้รับจ้างทำงานส่วนที่ ๑ ซึ่งมี ๓๓ งวดงานไม่แล้วเสร็จและถูกเรียกค่าปรับ ต่อมาผู้รับจ้างได้จ้างช่วงผู้รับจ้างอื่นมาติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและติดตั้งลิฟท์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ถือได้ว่าผู้รับจ้างกระทำความผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับที่ผู้รับจ้างต้องชำระ ริมสัมภาระ อุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดและสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายตามข้อสัญญาได้ ส่วนทรัพย์สินที่ได้ส่งมอบตามงวดงานและได้รับค่าจ้างไปแล้วนั้น ถือว่าผู้ว่าจ้างได้รับมอบงวดงานโดยถูกต้อง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตกเป็นของผู้ว่าจ้าง (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๑๖๖/๒๕๒๓)^{๑๕๒}

๒.๒) กรณีที่กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างตามข้อสัญญา (ในลักษณะเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นที่มีใช้ตัวเงินให้เป็นเบี้ยปรับ)

ในบางกรณีงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้แต่ไม่แล้วเสร็จนี้ ก็อาจตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างได้เลยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าแห่งการงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่คู่สัญญาได้ตกลงไว้แตกต่างไปจากกฎหมายกำหนดว่าเมื่อมีการบอกเลิกสัญญากันแล้วให้สิ่งก่อสร้างหรือการงานที่ทำไปแล้วตกแก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าแห่งการงานหรือค่าเสียหายอย่างไรก็ได้เลย ก็ย่อมทำได้เพราะเป็นข้อตกลงในสัญญาที่บังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา ซึ่งจะมีผลให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือการงานที่ทำไปแล้วตกเป็นของผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าใช้และครอบครองได้เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้ว การตกลงระหว่างคู่สัญญาให้ข้อสัญญามีความแตกต่างไปจากหลักที่กฎหมายกำหนดเช่นนี้สามารถทำได้โดยไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมาย เพราะเป็นการแสดงเจตนาด้วยใจสมัครและด้วยความยินยอมของคู่สัญญาและไม่ขัดทกกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งในเรื่องนี้ได้เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา

^{๑๕๑} โปรดอ่านใน จิตติ เจริญจำ, “การเลิกสัญญาที่มีสิทธิเข้าใช้งาน,” วารสารอัยการ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑-๓๓.

^{๑๕๒} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ, เล่มที่ ๒, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๑๙-๑๐๒๓.

ที่วินิจฉัยว่า ในกรณีที่มีข้อความในสัญญาไว้ชัดเจนว่าให้งานก่อสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างและไม่ต้องชดใช้ราคาเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลักษณะของการกำหนดเบี้ยปรับก็ต้องให้เป็นไปตามข้อสัญญานั้น ดังคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อไปนี้

- ตามสัญญาจ้างระบุว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำการจ้าง โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ นั่นคือ ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการให้ถือเอาบรรดาผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นก่อนผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอันเป็นการให้ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้ อย่างอื่นซึ่งมิใช่จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ย่อมมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับนี้ได้ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ว่าจ้างกับผลงานและพฤติการณ์ของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติตามสัญญา เห็นได้ว่าเบี้ยปรับดังกล่าวเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ผู้ว่าจ้างยอมรับผลงานของผู้รับจ้างเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ เกี่ยวกับค่าผลงานที่ทำไปแล้วอีก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๖/๒๕๓๗ ที่ ๒๗๙๔/๒๕๓๗ และที่ ๒๙๘๓/๒๕๔๑)

- เมื่อสัญญาจ้างมีข้อความว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นหรือก่อสร้างไว้เพื่องานจ้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือไม่ก็ตาม ยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างงานงวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ ยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา และได้คืนงานส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จแก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเรียกเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๘ และที่ ๙ ซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๗/๒๕๓๘)

- การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างถึงน้ำโดยใช้เสาเข็มผิดขนาดจากที่ขออนุญาต และถึงน้ำที่สร้างขึ้นก็ไม่แข็งแรงตามแบบ ผู้รับจ้างจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งแม้ว่าตามปกติผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับชดใช้คืนค่าผลงานที่ผู้รับจ้างทำไปแล้วอันได้แก่ การก่อสร้างถึงน้ำโดยใช้เสาเข็มผิดขนาดจากผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่ข้อสัญญาระบุว่าเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ข้อตกลงนี้มีลักษณะเป็นการที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งมิใช่จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหากเป็นจำนวนพอสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผลงานนี้โดยไม่ต้องใช้ราคาแก่โจทก์ เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ว่าจ้างกับผลงานและพฤติการณ์ของผู้รับจ้างแล้ว หากเบี้ยปรับนี้เป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้ค่าผลงานที่ได้ทำไปแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๐/๒๕๓๙)

- ตามสัญญาจ้างกำหนดว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จทุกรายการในงวดที่สาม จึงจะมีสิทธิรับค่าจ้าง แต่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิม แม้ตามปกติผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับชดเชยคืนค่าผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างแล้วบางส่วนตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่ตามสัญญาระบุว่าเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ข้อตกลงนี้มีลักษณะเป็นการที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๒๑/๒๕๔๐)

- ในสัญญาจ้างที่มีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาได้และรับผลงานโดยไม่ต้องใช้ราคานี้เป็นการที่ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะชำระหนี้เป็นอย่างอื่นให้เป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ว่าจ้างรับผลงานของผู้รับจ้างแล้วจึงถือได้ว่าผู้รับจ้างชำระค่าปรับแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๘-๔๕๙/๒๕๒๔) ในกรณีเช่นนี้จึงถือว่าเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว แม้คู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะเดิมก็จริง แต่ผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิได้ค่าแห่งการงานที่ได้ทำไปแล้วบางส่วน ในขณะที่ผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญา จึงสามารถเรียกร้องได้แต่ค่าเสียหายเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๒)^{๑๕๓}

- ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างได้ละทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญา แต่ปรากฏว่าในสัญญามีข้อกำหนดว่า เมื่อ ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างทำและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำงานนั้นโดยเฉพาะเพื่องานที่จ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ข้อตกลงนี้มีลักษณะเป็นการที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นที่มิใช่จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก่ผู้ว่าจ้างและหากเป็นจำนวนพอสมควรผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผลงานนี้ได้โดยไม่ต้องชำระราคาให้แก่ผู้รับจ้าง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๙๔/๒๕๓๗)^{๑๕๔}

- กรณีที่องค์การสุราทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์กักน้ำเสียโรงงานสุรากับผู้รับจ้างจำนวนสามราย แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งในสัญญาจ้างมีข้อตกลงว่าเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่า

^{๑๕๓} จิตติ เจริญน้ำ, “การเลิกสัญญาที่มีสิทธิเข้าใช้งาน,” วารสารอัยการ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖-๓๗.

^{๑๕๔} รชฏ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาแล้ว ยังยึดเครื่องมือไว้ได้,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๔ (สิงหาคม ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๔.

ตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย ดังนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ระบบกำจัดน้ำเสียทั้งระบบที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างตามข้อสัญญาและผู้ว่าจ้างมีสิทธิใช้สอยระบบกำจัดน้ำเสียนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๑๓๓๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๓๐)^{๑๕๕}

- กรณีที่กรมทรัพยากรธรณีทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ๔๐ บ่อ และสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบสถานีวัดระดับน้ำจำนวน ๔๐ แห่ง โดยแบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด ก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้ขยายอายุสัญญาออกไปตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้และเรียกค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงมีหนังสือเร่งรัดการทำงานและแจ้งเรียกค่าปรับในส่วนงานที่ล่าช้าจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเพียงสองงวด โดยที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ตรวจรับงานและได้ขุดเจาะบ่อเสร็จ ๓ บ่อ แต่ไม่มีฐานซีเมนต์และรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบ ผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและแจ้งเรียกค่าปรับ ธิบหลักประกันสัญญา และสงวนสิทธิเรียกค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้าทำงานแทน รวมทั้งให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ตลอดจนได้สงวนสิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ตามสัญญา สำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยว่า ในส่วนของงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้วและได้ทำการส่งมอบโดยที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ตรวจรับงานและไม่ได้ออกใบตรวจรับงานให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิเบิกเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างได้^{๑๕๖} ต่อมาเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่ผู้รับจ้างผูกพันกับผู้ว่าจ้างได้ แต่ภายหลังการบอกเลิก สัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการให้ผู้รับจ้างได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานไปแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องชดเชยเงินตามควรแก่ค่า

^{๑๕๕} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๖๕-๖๖.

^{๑๕๖} สำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการชำระเงินตามงวดงานว่า ในกรณีที่มีข้อสัญญากำหนดว่า เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบนั้น และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละงวดแล้วผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะออกใบตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน ข้อสัญญาดังกล่าวนี้นี้แสดงว่าผู้รับจ้างจะมีสิทธิเบิกเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งจากผู้ว่าจ้างได้ภายหลังจากที่ได้มีการออกใบตรวจรับงานสำหรับงานงวดนั้น และต่อไปหากปรากฏว่าผู้ว่าจ้างไม่ยอมชำระค่าจ้างตามที่ผู้รับจ้างมีสิทธิ ก็จะมีค่าจ้างค้างชำระในแต่ละงวดเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเห็นว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดใดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็จะไม่ออกใบตรวจรับงานให้ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างก็จะยังไม่มีสิทธิเบิกเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างได้ เมื่อผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิเบิกเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างแล้ว กรณีย่อมจะไม่มีเรื่องค่าจ้างที่ค้างชำระตามสัญญาแต่ละงวดเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อหาใดๆ (โปรดอ่านใน ราชฎ เจริญจำ, “งานที่ได้ทำไปแล้วเมื่อเลิกสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๙.)

แห่งการนั้นๆ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสอง แต่ในข้อสัญญากำหนดว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา บรรดางานต่างๆ ที่ผู้รับจ้างทำขึ้น ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดย ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่ากำหนดจนผู้ว่าจ้างต้องบอกเลิกสัญญา บรรดางานต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้ทำนอกเหนือจากงวดที่หนึ่ง อาทิ งานที่ผู้รับจ้างส่งมอบในงวดที่ ๒ โดยผู้ว่าจ้างมิได้ตรวจรับงานและงานป้อนน้ำบาดาล ๓ บ่อที่ยังไม่มีฐานซีเมนต์และรั้ว ผู้ว่าจ้างสามารถรับไว้ได้โดยไม่ต้องชำระราคา (ทั้งนี้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า กรณีเลิกสัญญาเพราะผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างรับการทำงานที่ทำโดยไม่ต้องชดใช้ค่าแห่งการทำงานตามข้อตกลงได้ ไม่ถือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและยังวินิจฉัยในคดีอื่นไว้ว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็น กรณีที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นที่มีใช้จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๓๙๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากเป็นจำนวนพอสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผลงานที่ผู้รับจ้างทำขึ้นโดยไม่ต้องชำระราคาแก่ผู้รับจ้าง) เมื่องานที่ผู้รับจ้างได้ ทำไปแล้วนอกเหนือจากงานงวดที่ ๑ โดยผู้ว่าจ้างมิได้ตรวจรับงาน ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ว่าจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ผู้รับจ้างยอมไม่มีสิทธิเรียกร้องในเงินค่างานดังกล่าวและ ไม่อาจนำเงินค่างานดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าปรับและค่าเสียหายได้ นอกจากนี้ เงินค่างานส่วนที่นอกเหนือจากงวดที่ ๑ ดังกล่าวมิใช่จำนวนค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว ส่วนเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมดนั้น หมายถึง เงินค่าจ้าง^{๑๕๗}

ในกรณีที่กรรมสิทธิ์ในเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามข้อกำหนดในสัญญา นั้น มีข้อพิจารณาว่า คำว่า “เครื่องมือก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง” หรือคำว่า “เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง” นี้มีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ กรณีดังกล่าวสำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยมีคำวินิจฉัยในการตอบข้อหารือว่า “ยึด “สิ่งของต่างๆ” ที่นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้าง” คำว่า “สิ่งของ” หมายรวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือของผู้รับจ้างที่ใช้ในการก่อสร้างด้วย เพราะตามเจตนารมณ์ของสัญญาจ้างพิพาท “สิ่งของ” หมายถึง เครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ทำงานที่จ้างตามมาตรา ๕๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสัมภาระสำหรับทำการงานที่จ้างตามมาตรา ๕๘๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ห.๒๐๓/๒๕๒๕) ดังนั้น จึงพอจะสันนิษฐานได้ว่าไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำใดถ้อยคำหนึ่งในบรรดาถ้อยคำดังกล่าว ก็มุ่งที่จะให้หมายถึงสิ่งของประเภทที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างนั่นเอง โดยอาจจะเป็นสิ่งของขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรไปจนถึงสิ่งของใช้งานอื่นๆ เช่น นั่งร้าน เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ฯลฯ

^{๑๕๗} โปรดอ่านใน รชฏ เจริญฉ่ำ, “งานที่ได้ทำไปแล้วเมื่อเลิกสัญญา,” วารสารอัยการ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๕-๑๑๑.

อนึ่ง ในการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีที่เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างตามข้อสัญญาหรือไม่ มีเงื่อนไขว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นของผู้รับจ้างเอง มิใช่ของบุคคลอื่น และต้องนำมาไว้ในสถานที่ก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างโดยเฉพาะ หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงไม่เข้าลักษณะดังกล่าว เครื่องมือเครื่องใช้นั้นก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ดังปรากฏตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ดังนี้

- กรณีที่ในสัญญาจ้างก่อสร้างระบุว่า ถ้าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา รับผิดชอบประกันและยึดสิ่งของต่างๆ ที่นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงาน โดยเฉพาะเพื่องานที่จ้างนั้น สิ่งของดังกล่าวต้องเป็นของผู้รับจ้างซึ่งหมายรวมถึงเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างตามมาตรา ๕๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากสิ่งของดังกล่าวมิใช่กรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างก็ไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างเพราะสัญญาจ้างมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่ผูกพันบุคคลภายนอก ผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจหรือสิทธิใดๆ ที่จะอ้างเอาสิ่งของของบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตน จึงต้องคืนแก่เจ้าของที่แท้จริง แต่เมื่อปรากฏว่ากรณีนี้สิ่งของต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง ภายหลังจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว สิ่งของดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างตามสัญญาทันทีและไม่ต้องคืนให้แก่ผู้รับจ้าง แม้ผู้รับจ้างได้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วนแล้ว ผู้ว่าจ้างก็ไม่จำเป็นต้องคืนสิ่งของดังกล่าว เพราะเป็นคนละเรื่องกันแบ่งแยกออกจากกันได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ พ.๒๐๓/๒๕๒๕)^{๑๕๘}

- กรณีกองทัพเรือว่าจ้างบริษัท ม. ก่อสร้างเสาอากาศ พร้อมติดตั้งระบบกำจัดฟ้าผ่าและระบบป้องกันไฟเกินที่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ โดยในนางนวดที่ ๒ กำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกซึ่งเป็นของบริษัท LEA แต่ผู้รับจ้างกลับติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัท MGC แทน และผู้รับจ้างยังต้องการแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อขอเปลี่ยนอุปกรณ์ชนิดดังกล่าวจากที่กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท LEA ไปเป็นของบริษัท MGC แต่ผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติเพราะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกของบริษัท MGC จึงเป็นการผิดสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และการบอกเลิกจ้างนี้มีผลให้สัญญาถูกเลิกจ้างทั้งหมด บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ตามข้อกำหนดในสัญญาไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วและมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเต็มตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ ตามข้อสัญญาที่คู่สัญญาได้จัดทำไว้ แต่สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งเป็นสิ่ง

^{๑๕๘} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๘๑.

ของที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง เพราะถือไม่ได้ว่าเป็นสิ่งของ ที่นำมาไว้เพื่อใช้ทำงานจ้าง (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๗๗/๒๕๓๒)^{๑๕๙}

อนึ่ง การที่สัญญาจ้างมีข้อตกลงว่าบรรดาสິงของต่างๆ ที่ผู้รับจ้าง นำมาไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อยค่าตอบแทน และค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ มีลักษณะเป็นการกำหนดเบี่ยงปรับได้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ จึงต้องนำท บัญญัติเกี่ยวกับเบี่ยงปรับมาใช้บังคับด้วย กล่าวคือ หากเบี่ยงปรับสูงเกินส่วน ศาลสามารถปรับลด ลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ ทั้งสามารถคำนวณโดยหักค่าปรับหรือเบี่ยงปรับจำนวนอื่นที่ได้รับไปบ้าง แล้วได้ด้วย^{๑๖๐} โดยปรากฏตามตัวอย่างความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ในกรณีกรมไปรษณีย์ โทรเลขทำสัญญาว่าจ้างทำห้ห้ส่วน อ. ทำงานถมดินและก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็นงวดๆ ต่อมาการสื่อสาร แห่งประเทศ ไทยได้รับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่และหนี้ตามสัญญาจ้างดังกล่าวมาเป็นของ การสื่อสารแห่งประเทศไทยโดยผลของพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เรียบร้อยตามรูปแบบ และรายการตามสัญญา ยังคงเหลืองานค้างอีก ๖ งวด นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยังใช้สัมภาระสิ่งของ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการในสัญญา ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทำการแก้ไขแล้ว แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉย ผู้ว่าจ้างจึงได้บอกเลิกสัญญา วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ บอกเลิกสัญญาเป็นวันเดียวกับผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการอีก สองงวด กรณีนี้เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว โดยที่ข้อสัญญาจ้างกำหนดให้สิ่งปลูกสร้างและ สัมภาระอุปกรณ์ในการก่อสร้างของผู้รับจ้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยไม่ต้องใช้ราคาแก่ ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างฯ อันเข้าลักษณะเป็นเบี่ยงปรับตามมาตรา ๓๗๗ และ ๓๘๒ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๘-๔๕๙/๒๕๒๔ ศาลจะลด เบี่ยงปรับที่สูงเกินส่วนลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหาก ศาลลดเบี่ยงปรับลงจะมีผลกระทบถึงค่าผลงานที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิริบไปแล้วเท่ากับจำนวนที่ศาลลด (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๙๐/๒๕๒๖)^{๑๖๑}

^{๑๕๙} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือ ปัญหาทนายความและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๕๓๗-๕๓๘.

^{๑๖๐} รศก. เจริญ, “เลิกสัญญาแล้ว ยังยึดเครื่องมือไว้ได้,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๔ (สิงหาคม ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๔.

^{๑๖๑} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือ ปัญหาทนายความและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๔-๑๑๗.

๓) กรณีมีข้อสัญญากำหนดให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยกรรมสิทธิ์ไม่ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง

ตามข้อ ๑๘ ของแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่เห็นว่าต้องสงวนไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา โดยสิทธิของผู้ว่าจ้างดังกล่าวมานี้เป็นสิทธิตามข้อสัญญาที่เกิดจากการแสดงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่จะปฏิบัติต่อกันเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาว่าในการเข้าใช้อุปกรณ์เครื่องมือหรือวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างนำมาไว้ในสถานที่ก่อสร้างเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องใช้ราคาให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่และเมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่ ดังได้กล่าวแล้วว่าสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเข้าใช้เครื่องมือก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ของผู้รับจ้างเป็นสิทธิที่เกิดภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างและเป็นสิทธิตามข้อสัญญา ดังนั้น หากข้อสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการระบุไว้เช่นใดก็ต้องให้เป็นไปตามนั้น ดังเช่น ในกรณีที่ข้อสัญญาระบุว่าให้สิ่งปลูกสร้างและสัมภาระอุปกรณ์ในการก่อสร้างของผู้รับจ้างตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยไม่ต้องใช้ราคาแก่ผู้รับจ้าง เป็นต้น แต่กระนั้น เครื่องมือก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เมื่อพิจารณาโดยสภาพแล้วมีทั้งที่เป็นของที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปและเป็นของที่ใช้แล้วไม่สิ้นเปลืองหมดไป โดยในกรณีหลังนี้เป็นสิ่งของของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่เข้าใช้ประโยชน์เสร็จแล้วยังพอที่จะส่งคืนให้ผู้รับจ้างได้ แต่ในกรณีแรก เป็นสิ่งของของผู้รับจ้างรายเดิมที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่นำมาใช้แล้วจะหมดสิ้นไป จึงไม่เหลืออะไรให้ส่งคืนแก่ผู้รับจ้างได้ ดังนั้น จึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาว่าผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ควรต้องชดเชยราคาให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิมหรือไม่ เนื่องจากผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่มีเพียงสิทธิที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ ผู้รับจ้างนำมาไว้ในสถานที่ก่อสร้างภายหลังการบอกเลิกสัญญาเท่านั้น แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งของเหล่านั้นแต่ประการใด ซึ่งเท่ากับว่าผู้ว่าจ้างเพียงแต่ยืมหนวสิ่งของดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือเพื่อให้ผู้รับจ้างรายใหม่ที่เข้าทำงานแทนได้ใช้ประโยชน์ในการทำงานที่ค้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งการยืมหนวดังกล่าวนี้มีใช้เรื่องสิทธิยืมหนวดตามมาตรา ๒๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาตามสมควรในระหว่างที่ใช้ทรัพย์สินหรือเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้น เรื่องนี้เคยมีคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยไว้ในกรณี กองทัพเรือ โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ส. ทำการก่อสร้างอาคารพักของข้าราชการชั้นประทวน ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการกองทัพอเรือผู้รับจ้างส่งมอบงานได้ ๑๗ งวด และรับเงินค่าจ้างตามสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว คงค้างงานงวดที่ ๑๘ ถึง ๒๐ ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา ต่อมาผู้รับจ้างได้มี

หนังสือร้องขอขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องมือและวัสดุก่อสร้างตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ สำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจ้างให้สิทธิแก่ทางราชการที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องสงวนไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ดังนั้น หากทางราชการประสงค์จะปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าวต่อไป ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ก็ตาม และการปฏิบัติงานต่อไปนั้นมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและวัสดุดังกล่าวแล้ว ทางราชการย่อมสามารถออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างขนย้ายเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่ผู้ว่าจ้างต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นตามสมควรเช่นที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะเช่นนี้ เว้นแต่วัสดุต่างๆ ที่ได้ใช้ในการก่อสร้างไปแล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปในการก่อสร้างและตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ทางราชการในที่สุด ทางราชการก็ต้องชำระค่าวัสดุดังกล่าวชดใช้คืนให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาท้องตลาดในขณะที่น่าไปใช้ด้วย ส่วนทางราชการจะต้องรับผิดชอบเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวชำรุดเสียหายหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ว่าทางราชการ ได้ดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นตามสมควรหรือไม่ สำหรับงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว แม้ไม่เสร็จตามสัญญา ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาหรือค่าของงานนั้น (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ๙๕/๒๕๓๙)^{๑๖๒}

ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยข้อหาดังกล่าวข้างต้น แม้โดยข้อสัญญาจะให้สิทธิผู้ว่าจ้างใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่ก็มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๓.๑) หากผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะทำงานต่อหรือยังหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่ค้างต่อไปไม่ได้ภายในเวลาอันควร ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป

๓.๒) แม้โดยข้อสัญญาจะให้สิทธิผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างได้ก็ตาม แต่ก็มิได้ให้กรรมสิทธิ์ในวัสดุต่างๆ เหล่านั้นตกเป็นของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ การที่ผู้ว่าจ้างสงวนและครอบครองเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้าง แม้จะมีลักษณะเป็นการยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ แต่ไม่เป็นเรื่องสิทธิยึดหน่วงโดยตรงตามมาตรา ๒๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะการยึดดังกล่าวไม่เข้ากรณีที่ผู้ว่าจ้างยึดหน่วงทรัพย์สินของผู้อื่นไว้เพื่อเรียกให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ อันจะถือว่าเข้ากรณีเป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งยึดครองนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างก็ต้องมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงที่จะต้องจัดการดูแลและรักษาทรัพย์สินที่จะใช้หรือยึดหน่วงไว้นั้นตามสมควรเช่นจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะเช่นนั้นตามมาตรา ๒๔๖ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะถือว่า

^{๑๖๒} โปรต่านใน รชฎ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาแล้ว ยังยึดเครื่องมือไว้ได้,” วารสารอัยการ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๘-๑๑๒.

กรณีนี้ไม่มีบทกฎหมายที่จะนำมาปรับได้โดยตรง ทั้งไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะยกมาปรับได้ด้วย แต่เป็นกรณีที่ใกล้เคียงกับเรื่องสิทธิยึดเหนี่ยว คือ เป็นการครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ เช่นเดียวกันและเป็นการครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ครองจึงต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ครองไว้นั้นเหมือนกัน

๓.๓) เนื่องจากทรัพย์สินของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดไว้มีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างชั่วคราวและวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งการดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งสามประเภทนี้อาจมีการใช้ความระมัดระวังต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิยึดไว้เพื่อใช้ทำงานต่อจนเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องคืนแก่ผู้รับจ้าง ฉะนั้น ในระหว่างที่ใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ ผู้ว่าจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องจัดการดูแลและรักษาตามสมควรเช่นที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะเช่นนั้นตามมาตรา ๒๔๖ ดังกล่าว ส่วนสิ่งก่อสร้างชั่วคราวนั้น โดยสภาพจะต้องมีการรื้อถอนและคืนให้แก่ผู้รับจ้างไปเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจึงต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างชั่วคราวนี้เช่นเดียวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ส่วนวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นของใช้สิ้นเปลืองหมดไปและเมื่อได้ใช้ก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างแล้วย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ว่าจ้างในที่สุด ผู้ว่าจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนนี้ให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าวัสดุต่างๆ ชดใช้คืนให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาท้องตลาดของวัสดุขณะที่น่าไปใช้ด้วยตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม เว้นแต่วัสดุต่างๆ ในขณะที่ยังมีได้ใช้หรือ ในที่สุดมิได้ใช้ในการก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องคืนแก่ผู้รับจ้างเมื่อเสร็จงานนั้น ผู้ว่าจ้างยังคงมีหน้าที่ดูแลรักษาเช่นเดียวกับเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างได้ดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของผู้รับจ้างในระดับความระมัดระวังดังกล่าวมาแล้ว แม้จะเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ว่าจ้างย่อมไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ได้ดูแลรักษาโดยใช้ความระมัดระวังในระดับดังกล่าว ผู้ว่าจ้างย่อมต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น^{๑๖๓}

จากข้อพิจารณาและแนวคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดดังกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ข้อสัญญาจะมีการกำหนดสิทธิในลักษณะที่เป็นการปกป้องประโยชน์ของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นส่วนราชการในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยเฉพาะการให้สิทธิผู้ว่าจ้างสามารถยึดเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างของผู้รับจ้างไว้ใช้งานภายหลังการบอกเลิกสัญญาได้ แต่ในทางกฎหมาย แม้ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาอันเป็นเหตุของการบอกเลิกสัญญา กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นของผู้รับจ้างก็ยังคงได้รับการคุ้มครองตามปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปทุกประการ

^{๑๖๓} โปรดอ่านใน รชฎ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาแล้ว ยังยึดเครื่องมือไว้ได้,” วารสารอัยการ, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๐-๑๑๑.

๒.๖ สิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องของงาน

โดยทั่วไปความเสียหายและความชำรุดบกพร่องในการทำงานที่ผู้รับจ้างทำนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างทำการก่อสร้าง ภายหลังการส่งมอบงานงวดสุดท้าย และในช่วงระยะประกันผลงาน ซึ่งตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๑^{๖๔} และข้อ ๘^{๖๕} ได้กำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นขณะที่ผู้รับจ้างทำงานหรือเกิดความชำรุดบกพร่อง ภายหลังการส่งมอบงาน โดยในข้อ ๑๑ ระบุว่า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น ซึ่งข้อ ๘ เรื่องความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ได้กำหนดไว้ว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗^{๖๖} หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จากข้อสัญญาทั้งสองข้อดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้รับจ้างมีความรับผิดชอบในการทำงานที่แบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก ความเสียหายที่เกิดแก่งานในขณะที่อยู่ในระหว่างอายุสัญญากรณีหนึ่ง ดังเช่น ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเดินเรือมาชนท่าเทียบเรือหรือเสาหลักในระหว่างที่

^{๖๔} แบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุนอกเหนือจากความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

^{๖๕} โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖๗ หน้า ๔๒

^{๖๖} กำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องโดยปกติจะมีระยะเวลา ๑ ปี แต่ในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างควรจะรับผิดชอบมากกว่า ๑ ปีตามลักษณะงานหรือด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเหมาะสม

ผู้รับจ้างกำลังทำงานตามสัญญา เช่นนี้ผู้รับจ้างก็ต้องซ่อมแซมหรือจัดทำขึ้นใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เป็นต้น ส่วนช่วงที่สอง เป็นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานที่ทำแล้วเสร็จบริบูรณ์และได้มีการส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างแล้ว ซึ่งสาเหตุของความชำรุดบกพร่องดังกล่าวอาจจะเนื่องจากผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง ทำงานไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่คู่สัญญาดตกลงกำหนดกันไว้ เช่น ๕ ปี หรือ ๑ ปี เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตว่าจุดแบ่งแยกความรับผิดทั้งสองประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ความรับผิดในความเสียหายระหว่างการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ส่วนความรับผิดในความชำรุดบกพร่องจะเริ่มต้นภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว โดยในกรณีหลังนี้ หากงานที่ผู้ว่าจ้างรับมอบปรากฏความชำรุดบกพร่องใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานเป็นต้นไปจนครบระยะเวลาที่คู่สัญญาดตกลงกัน ทั้งนี้ ความรับผิดในทั้งสองกรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับเข้าดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ถ้าผู้รับจ้างนิ่งเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆ ผู้ว่าจ้างจะเข้าทำการแก้ไขงานนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นเข้ามาทำการแก้ไขโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้

ตัวอย่างความเห็นของสำนักอัยการสูงสุดเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกให้ผู้รับจ้างรับผิดในความชำรุดบกพร่องมีดังนี้

- จังหวัดอุดรธานีทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ทำการก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอ พร้อมบ้านพักข้าราชการ ในระหว่างการก่อสร้าง ภายหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ได้เกิดเหตุพายุหมุนเป็นเหตุให้อาคารที่กำลังก่อสร้างเสียหายผู้รับจ้างได้ขอให้ทางราชการชดเชยค่าเสียหาย กรณีนี้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นและจัดหามาให้ใหม่หรือแก้ไขให้คืนดีตามสัญญา (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๖๓/๒๕๒๔)^{๑๖๗}

- สำนักงานรังวัดพัฒนาชนบทว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์ฝึกอบรม รพช. ต่อมาอาคารดังกล่าวมีความชำรุดเสียหาย ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ยินยอมเข้าซ่อมแซม กรณีนี้ความชำรุดเสียหายของงานที่จ้างเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของผู้รับจ้างที่ทำงานไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดขึ้นภายในกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างได้รับทราบความชำรุดบกพร่องแล้วไม่จัดการซ่อมแซม ถึงแม้ผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งให้เข้าซ่อมแซมถึงสองครั้งก็ตาม ทั้งไม่แจ้งเหตุขัดข้องใดๆ ถือได้ว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ห.๑๗/๒๕๒๔)^{๑๖๘}

^{๑๖๗} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑๘.

^{๑๖๘} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), เล่มเดียวกัน, หน้า ๑๓๘๕-๑๓๘๖.

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำสัญญาจ้างและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในการก่อสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยในสัญญาได้แบ่งการส่งมอบและรับมอบงานเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรก ผู้รับจ้างได้ส่งมอบเตียงจำนวน ๑๐๐ เตียง ส่วนที่สองเป็นงานติดตั้งระบบต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญา พร้อมทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้ดีตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในสัญญาจ้างได้กำหนดเบี้ยปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานส่วน ๑๐๐ เตียงแรกและส่วนที่เหลือไว้ต่างกัน เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแต่ละส่วนจากผู้รับจ้างแล้ว หน้าที่รับประกันความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างจึงต้องเริ่มนับแต่นั้น เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงาน ๑๐๐ เตียงแรกจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ที่จะซ่อมแซมแก้ไขให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามสัญญาการใช้งานสำหรับในส่วน ๑๐๐ เตียงแรก ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผู้ว่าจ้างรับมอบงานไว้แล้ว ผู้รับจ้างจึงจะมีหน้าที่รับประกันความบกพร่องของงานทั้งระบบ แต่โดยที่ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างยังไม่อาจเข้าไปใช้ประโยชน์ในงานที่นอกเหนือจากงานในส่วน ๑๐๐ เตียงแรก ดังนั้นการที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในงานส่วนดังกล่าวย่อมอาจเกิดปัญหาได้ เพราะเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ทั้งที่ยังไม่มีสิทธิเช่นนั้น หากเกิดความเสียหายขึ้นก่อนเวลาตรวจรับมอบงานย่อมไม่อาจบังคับให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขให้คืนดีได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่สัญญามีได้ตกลงกันไว้ในเรื่องนี้ กรณีเช่นนี้ หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในงวดงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สามารถที่จะตกลงกับผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างในเรื่องความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง ทั้งกำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบให้ชัดเจนก่อน (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๒๖)^{๖๙}

- สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบททำสัญญาจ้างเหมาจ้างหุ่นส่วนจำกัด น. ทำการสำรวจออกแบบและก่อสร้างทางลูกรัง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานรวม ๑๓ กวดให้แก่ผู้ว่าจ้าง ต่อมาได้มีการทำสัญญาให้ก่อสร้างเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจเพื่อรับมอบงานตลอดทั้งสาย พบว่าผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา โดยเฉพาะงานผิวจราจรลูกรังในงานงวดที่ ๑๓ ที่ได้ส่งมอบไว้แล้ว จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขซ่อมแซม แต่ผู้รับจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบ กรณีนี้เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างทำงานเสร็จและส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับไว้ ๑๓ กวด เมื่อตรวจรับงานแล้วก็ได้เปิดถนนสายดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใช้ตลอดมา พฤติการณ์เป็นการรับมอบงานทั้งหมดตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๓ โดยปริยายแล้ว ผู้ว่าจ้างจะอ้างว่าเป็นเพียงการตรวจรับหรือจ่ายเงินค่าจ้างตามงวดงานในสัญญาไม่ได้ การทำงานตามสัญญาเดิมควรยุติลงแล้ว แม้ผู้รับจ้างจะยอมผูกพันตนตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเข้าทำงานในส่วนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปก็หาทำให้งานตามสัญญาเดิมที่ได้ตรวจรับและเปิดใช้งานไปแล้วกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมอีกไม่ เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ และเปิดใช้เป็น

^{๖๙} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๒-๒๐๔.

ทางสัญญาจนถึง ๒ ปีแล้ว ผู้ว่าจ้างจะอ้างว่างานในงวดที่ ๑๓ ไม่ถูกต้องเพื่อให้ ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเสียก่อนจึงจะตรวจรับงานตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมหาได้ไม่ ผู้รับจ้างมีหน้าที่เฉพาะความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๓๔/๒๕๒๘)^{๑๗๐}

- กรมสามัญศึกษาทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ทำการก่อสร้างโรงฝึกงาน โดยมีธนาคาร ท. เป็นผู้ค้ำประกัน ในสัญญามีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องคืนหลักประกันให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา และในกรณีที่มีความชำรุดเสียหายแก่งานจ้างภายใน ๑ ปี นับแต่วันรับมอบงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย กรณีนี้เห็นว่าสัญญากำหนดเงื่อนไขสิ้นสุดความรับผิดชอบของหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพียงภายในกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างยังมีความผูกพันรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้างเท่านั้น เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวแล้ว หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ให้ผู้ว่าจ้างย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่ความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานเมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันรับมอบงานแล้ว เป็นความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างและพ้นกำหนดเงื่อนไขสิ้นสุดความรับผิดชอบของหนังสือสัญญาค้ำประกันซึ่งเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๔๑/๒๕๒๘)^{๑๗๑}

- กองทัพอากาศทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารตึกแถวครอบครัวยุทธนาทหารชั้นประทวน ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ทางราชการแล้ว ต่อมาผู้ว่าจ้างได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างและได้ทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องไว้แล้ว ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างและธนาคารผู้ค้ำประกันให้ปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินจำนวนดังกล่าวหลายครั้ง แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉยและธนาคารผู้ค้ำประกันปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค้ำประกัน เนื่องจากการค้ำประกันของผู้รับจ้างได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบงานแล้ว กรณีนี้การจะฟ้องผู้รับจ้างหรือผู้ค้ำประกันสัญญาให้รับผิดชอบชำระหนี้ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งชำรุดบกพร่องและเงินประกันสัญญาในเรื่องนี้นั้น หากมีการตรวจพบความชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาหลายครั้งและรายการความชำรุดบกพร่องที่ตรวจพบแต่ละครั้งแตกต่างกัน ผู้ว่าจ้างก็อาจพิจารณาแยกนับอายุความตามแต่ละวันที่ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น ส่วนในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมขยายวันแล้วเสร็จของงานตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม หากไม่ปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ธนาคาร ท. ผู้ค้ำประกันทราบโดยไม่ชักช้าตามเงื่อนไขในสัญญาค้ำประกันแล้ว ผู้ค้ำประกันย่อมยกเป็นเหตุบอกปิดความรับผิดชอบได้ตามมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่ากองทัพอากาศพบรายการบกพร่องซึ่งโดยส่วนใหญ่

^{๑๗๐} สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๕๐๗-๕๐๘.

^{๑๗๑} สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), เล่มเดียวกัน, หน้า ๖๒๓-๖๒๔.

เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญา อันเป็นความชำรุดบกพร่องที่ผู้ว่าจ้างพึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบงานตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างก็ได้รับมอบงานไว้ทั้งหมดตามสัญญา โดยมีได้แจ้งความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไข ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามมาตรา ๕๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๘๓/๒๕๒๙)^{๑๗๒}

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าจ้างบริษัท ย. ทำงานระบบปรับอากาศและห้องเย็น ฯลฯ ของอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้ว ต่อมาปรากฏความชำรุดบกพร่องของระบบปรับอากาศ ผู้ว่าจ้างจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขหลายครั้ง แต่ไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาได้ หลังจากนั้นผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างให้คืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างโดยอ้างว่าได้ทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างรับไว้ถูกต้องแล้วและอายุการรับประกันผลงานตามสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว กรณีนี้เห็นว่าการชำรุดบกพร่องของระบบปรับอากาศเกิดขึ้นในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน หากความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขให้เรียบร้อย โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างมิได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าแก้ไขซ่อมแซมหรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างให้ผู้อื่นแก้ไขซ่อมแซมได้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ให้ผู้ว่าจ้างนั้น สัญญากำหนดให้คืนให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หากผู้รับจ้างยังไม่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาไม่ต้องคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ว่าจ้างจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ระบบปรับอากาศชำรุดบกพร่อง จึงอยู่นอกเหนือข้อกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อเงินค่าเครื่องปรับอากาศ และแม้ว่ามาตรา ๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะบัญญัติห้ามมิให้ฟ้องร้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏก็ตาม เมื่อปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นและผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแล้ว แต่ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ จึงถือได้ว่าผู้รับจ้างยอมรับสภาพตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างแล้ว ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างลงมือแก้ไขซ่อมแซมจนกระทั่งถึงวันที่ผู้รับจ้างปฏิเสธไม่แก้ไขซ่อมแซมต่อไป ดังนั้น อายุความจะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ยอมแก้ไขซ่อมแซมเป็นต้นไปตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทั้งปวงที่ได้รับเนื่องจากความชำรุดบกพร่องของระบบปรับอากาศดังกล่าว (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๔๐/๒๕๒๙)^{๑๗๓}

^{๑๗๒} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหาทนายความและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๘๒๗-๘๒๘.

^{๑๗๓} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหาทนายความและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), เล่มเดียวกัน, หน้า ๙๐๐-๙๐๓.

- กรมชลประทานทำสัญญาจ้างเหมาจ้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารประกอบในเขตโครงการชลประทานขนาดกลาง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๕ ครั้ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๙ ต่อมาผู้ว่าจ้างสั่งให้หยุดงานส่วนที่เหลือไว้ก่อนเพราะมีฝนตกหนักน้ำท่วมพื้นที่โครงการทำให้คันคลอง คอนกรีตตาดคลอง ถนนลูกรังบนคันคลอง ตลอดจนอาคารในบริเวณคลองส่งน้ำชำรุดเสียหายหลายแห่งและงานที่ชำรุดเสียหายนั้นเป็นงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไปแล้วทั้ง ๕ ครั้ง ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขงาน แต่ผู้รับจ้างอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ยอมเข้าซ่อมแซมงาน กรณีนี้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหาย ที่เกิดในระหว่างอายุสัญญายังไม่สิ้นสุด ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยทั้งสัญญา งานส่วนที่เสียหายเป็นงานที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบเพื่อการจ่ายเงินเท่านั้น การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาได้ต้องเป็นงานที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ ดังนั้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ตามเงื่อนไขพิเศษแนบท้ายสัญญาจ้างและตามมาตรา ๖๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ความเสียหายจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างก็ยังคงรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นและจัดหาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดีภายในพันธกรณีที่มีอยู่ในสัญญาที่ยังไม่ถึงที่สุดตามเงื่อนไขสัญญา จึงถือว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานให้ถูกต้องครบถ้วนและยังต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ๑๔๘/๒๕๓๑)^{๑๗๔}

- สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจ้างเหมาบริษัท ท. ก่อสร้างฝายน้ำล้น และได้ตรวจรับงานแล้ว ต่อมาอีกประมาณ ๔ เดือนเศษ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจพบความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าแก้ไข แต่ผู้รับจ้างอ้างว่าความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นพ้นกำหนดระยะเวลา ๑ ปีที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแล้ว เพราะผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานแล้ว กรณีนี้ในสัญญาจ้างระบุว่า การตรวจรับงานก่อสร้างในงวดสุดท้ายให้ถือว่าเป็นการตรวจรับงานจ้างเหมาตามสัญญา เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบเข้าแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด กรณีดังกล่าววันที่ถือว่ามีกรับมอบงานงวดสุดท้าย คือ วันที่ระบุไว้ในใบตรวจรับงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องของงานภายใน ๑ ปี นับแต่วันดังกล่าว ผู้รับจ้างจึงต้อง

^{๑๗๔} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๓๘๔-๓๘๕.

รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างข้างต้น (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ ๙/๒๕๓๔)^{๑๗๕}

สำหรับในเรื่องระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายหลังการส่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น แม้จะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๖๐๐^{๑๗๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่คู่สัญญาสามารถตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ เพราะเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาของคู่สัญญาด้วยความยินยอมร่วมกัน ดังปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อไปนี้

- ในร่างสัญญาที่มีข้อสัญญาเรื่องความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องนั้น การที่จะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่ทำไว้เป็นระยะเวลาเท่าใดนั้น กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่สัญญาตกลงกันได้ เว้นแต่ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นไว้ในสัญญาแล้ว จึงให้ใช้ตามมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นหน่วยราชการจึงมีสิทธิที่จะกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องในงานจ้างก่อสร้างกับพื้นดินเป็นเวลา ๑ ปีได้ตามนัยแห่งมาตราดังกล่าว (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๒๖)^{๑๗๗}

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทำสัญญาจ้างจ้างหุ้นส่วนจำกัด จ. และบริษัท ป. ให้ทำการก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ ท่อประปา และท่อน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม ต่อมาได้มีการทำข้อตกลงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบรายการ ๔ ครั้ง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ ๒ ปี ถนนที่ก่อสร้างชำรุดบกพร่อง ผู้ว่าจ้างจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข แต่ผู้รับจ้างปฏิเสธโดยอ้างว่าผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ได้ส่งมอบงาน เห็นว่า ตามข้อสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อการชำรุดบกพร่องภายใน ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง จึงเป็นการกำหนดเวลารับผิดชอบเพื่อการชำรุดบกพร่องไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา จะนำกำหนดเวลาตามมาตรา ๖๐๐ วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับมิได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความชำรุดบกพร่องได้เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนด ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ได้รับมอบงาน ผู้ว่าจ้างจึงไม่สามารถดำเนินคดีบังคับให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องได้ เว้นแต่จะปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้นไว้ ผู้ว่าจ้างจึงจะดำเนินคดีได้สัญญาจ้างเหมาในกรณีนี้แตกต่าง

^{๑๗๕} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๖๙๘-๖๙๙.

^{๑๗๖} **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

มาตรา ๖๐๐ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไว้ว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อการชำรุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้

แต่ข้อจำกัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น

^{๑๗๗} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๘๘-๘๙.

ต่างจากตัวอย่างสัญญาจ้างแบบทำระยะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องในงานจ้างภายในระยะเวลาที่บัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ส่วนสัญญาในกรณีนี้ไม่ได้มีข้อกำหนดดังกล่าว (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๒๖)^{๑๗๘}

- ตามสัญญาจ้างกำหนดไว้ชัดเจนว่า “ถ้างานที่จ้างเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลา ๑ ปี ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย” ซึ่งหมายความว่า สัญญาดังกล่าวแม้จะเลยกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างไปแล้ว หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในกำหนด ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงานที่จ้าง ผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องอันเกิดกับงานที่จ้างนั้นต่อผู้ว่าจ้างตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๐ วรรคแรก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดกับงานที่จ้าง ซึ่งเป็นอาคารที่ปลูกสร้างกับพื้นดินได้เกิดขึ้นภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแก่ผู้ว่าจ้างซึ่งแม้จะเลยกำหนดเวลา ๑ ปีไปแล้ว ผู้รับจ้างก็ยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๐ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๕๗/๒๕๓๓)

- ตามสัญญาจ้างเหมาซื้อสัญญาว่า เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้นซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะเป็นโดยทำให้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของที่ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น หรือถ้าผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างให้ผู้อื่นทำงานจ้างนั้นแทนผู้รับจ้างได้ ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนั้น จึงมีผลบังคับว่าตามข้อสัญญาในสัญญาจ้างเหมา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานที่จ้างภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน ถ้าเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างและตามข้อสัญญาในสัญญาจ้างเหมา ซึ่งหมายความว่า นอกจากงานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจาก ๑ ปีแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน ๕ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๐ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจพบความชำรุดบกพร่องภายใน ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน ความเสียหายตามฟ้อง

^{๑๗๘} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๘-๑๒๙.

ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่พ้นระยะเวลาความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมา ผู้รับจ้างจึงต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๔๘/๒๕๓๘)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ค้างตามโครงการที่สาม ส่วนที่เป็นงานโยธาสถาปัตยกรรม เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างได้คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งค้ำประกันความรับผิดชอบของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างไปแล้ว ต่อมาผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมรอยร้าวจากหลังคาของอาคารโรงพยาบาลรวม ๑๗ รายการ แต่ผู้รับจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าความเสียหายบางรายการไม่เกี่ยวกับงานจ้างตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าความเสียหายเกิดจากความชำรุดบกพร่องของงานที่ทำ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างเป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงาน กรณีนี้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า ตามสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันรับมอบงาน อันถือได้ว่าคู่สัญญาได้ตกลงกันกำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อความชำรุดบกพร่องไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา แม้งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจัดเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดินก็ตาม ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องถึง ๕ ปีตามมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น อย่างไรก็ตาม ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบความชำรุดบกพร่องทั้ง ๑๗ รายการ ในครั้งแรกจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานได้เกินกำหนดเวลาหนึ่งปีแล้ว ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ แม้จะมีกรณีที่ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้างฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานที่ทำเป็นเวลา ๑๐ ปีก็ตาม แต่การฟ้องร้องผู้รับจ้างให้รับผิดชอบในกรณีนี้ มาตรา ๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่การชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างได้พบความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบได้ เว้นแต่จะมีหลักฐานว่าผู้รับจ้างได้รับสภาพหนี้หรือสภาพความรับผิดชอบไว้ต่อผู้ว่าจ้างแล้วตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างจึงจะฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๓๐)^{๑๗๙}

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ต่อมาภายหลังผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ผู้ว่าจ้างได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของอาคาร จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขในทันที แต่ผู้รับจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าเกินกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานแล้ว กรณีนี้เห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดแก่อาคารภายในห้าปีนับแต่วันรับมอบงานจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมแล้วกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิจ้างผู้อื่นเข้าทำการซ่อมแซมโดยผู้รับจ้างเป็น

^{๑๗๙} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๒-๑๕๔.

ผู้ออกค่าใช้จ่าย การฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ้างบุคคลอื่นเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องแทนผู้รับจ้างนี้ ถือเป็นการฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดแก่งานซึ่งมีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องตามมาตรา ๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องถือตามวันที่เกิดความชำรุดบกพร่องหรือผู้ว่าจ้างตรวจพบความชำรุดบกพร่องนั้น หากมีการตรวจสอบพบความชำรุดบกพร่องหลายครั้งภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาและรายการความชำรุดบกพร่องที่ตรวจพบแต่ละครั้งแตกต่างกันก็ต้องพิจารณาแยกนับอายุความตามแต่ละวันที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏขึ้น ส่วนการฟ้องธนาคารผู้ค้ำประกันให้รับผิดชอบก็ต้องฟ้องภายในอายุความเช่นเดียวกับที่จะฟ้องผู้รับจ้าง หากฟ้องผู้ค้ำประกันเมื่อขาดอายุความที่จะฟ้องผู้รับจ้างแล้ว ผู้ค้ำประกันจะยกเหตุขาดอายุความนี้ขึ้นต่อสู้เพื่อให้ไม่ต้องรับผิดชอบได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๓/๒๕๓๑)^{๑๘๐}

- กรณีกรมทางหลวงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ก่อสร้างทางหลวงจังหวัดเมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยตามเงื่อนไขในสัญญาและตามรายละเอียดต่อท้ายสัญญาจึงส่งมอบงานซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานโดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาเป็นเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันส่งมอบ ต่อมาปรากฏว่าได้เกิดการเลื่อนไถลของดินลงมากลอบผิวทางทำให้คันทางและผิวทางชำรุด ผู้ว่าจ้างจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นและได้ทำหนังสือแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันให้ทราบในชั้นหนึ่งก่อน แต่ผู้รับจ้างเพียงแต่ขนย้ายดินที่เลื่อนไถลลงมาโดยไม่ได้อุดซ่อมผิวทางที่ชำรุด ผู้ว่าจ้างจึงจ้างผู้อื่นเข้าทำการแทนกรณีดังกล่าวหากผู้ว่าจ้างให้ผู้อื่นทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมแทนผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างก็จะสามารถใช้สิทธิเรียกค่าจ้างและค่าสิ่งของที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิงจากผู้รับจ้างได้ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขเองก็จะมีค่าจ้างที่จะเรียกร้องจากผู้รับจ้างตามสัญญา แม้กรณีนี้ผู้ว่าจ้างมิได้เข้าแก้ไขความเสียหายเอง แต่ย่อมถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาทำให้ ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายได้ตามมาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ พ.๗๑/๒๕๒๔)^{๑๘๑}

๒.๗ สิทธิที่จะเสนอชื่อผู้รับจ้างที่กระทำผิดสัญญาให้เป็นผู้ทำงาน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญากับทางราชการ นอกจากจะมีข้อสัญญาแล้วยังมีบทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ บังคับให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการกระทำผิดสัญญา เริ่มตั้งแต่มาตรการสำหรับความรับผิดชอบในระดับเล็กน้อยที่ไม่ถึงขั้นต้องบอกเลิกสัญญา เช่น การเรียกค่าปรับในกรณีทำงานล่าช้าล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญา การริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

^{๑๘๐} สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๔), อ้างแล้ว, หน้า ๒๐๗-๒๐๘.

^{๑๘๑} กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๒), อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๓๒-๑๒๓๓.

การเรียกค่าตอบแทนงาน และค่าเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าในการทำงาน ส่วนมาตรการสำหรับความรับผิดในระดับที่สูงขึ้นมากก็คือ การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ซึ่งจะมีผลให้สัญญาจ้างระหว่างคู่สัญญาลิ้นสุดลง ส่วนสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ระหว่างคู่สัญญา หากยังไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องไว้ก็เป็นอันระงับไป แต่ผลที่จะตามมาภายหลังการบอกเลิกสัญญาก็คือ ความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชดเชยในค่าเสียหายต่าง ๆ (โดยเฉพาะในจำนวนที่เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา) ค่าปรับในกรณีที่มีการเรียกค่าปรับและได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับไว้ตั้งแต่ก่อนบอกเลิกสัญญา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ (เช่น กรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างรายใหม่ซึ่งเข้าทำงานแทนผู้รับจ้างรายเดิมที่ถูกบอกเลิกสัญญา) เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างต้องใช้สิทธิทางศาลบังคับให้ผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาชดเชยค่าเสียหายต่าง ๆ สำหรับมาตรการสำหรับความรับผิดในระดับที่รุนแรงขั้นสูงสุดที่ผู้รับจ้างจะได้รับ คือ การที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเสนอเพื่อให้มีการสั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานโดยการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานจะมีขึ้นภายหลังจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ดังนั้น ผู้รับจ้างที่ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างนอกจากจะต้องถูกเรียกค่าเสียหาย รับผิดชอบสัญญาและอื่น ๆ แล้ว ยังอาจต้องถูกลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานอีกด้วย อันถือเป็นมาตรการลงโทษที่รุนแรงมาก ซึ่งข้อ ๑๔๕^{๑๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน และให้กระทรวงเจ้าสังกัดรีบส่งชื่อผู้ทิ้งงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ (เดิม ก่อนวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบ

^{๑๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

ห้ามส่วนราชการก่อนนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

การห้ามส่วนราชการก่อนนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๔๕ ณ วรรคสอง และวรรคสามด้วย

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกำหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมาผู้รักษาการตามระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่กระทำก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน หรือไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบก็ได้

(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับผู้รักษาการตามระเบียบฯ ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง) เพื่อพิจารณา หากเห็นด้วยให้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นๆ ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและห้ามส่วนราชการก่อกวนสัมพันธ์กับผู้ทำงานที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบฯ จะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทำงาน จากข้อกำหนดตามข้อ ๑๔๕ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการสั่งให้เป็นผู้ทำงานจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาสองชั้น คือ ชั้นเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้เสนอชื่อผู้รับจ้างรายต่างๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อปลัดกระทรวงพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงาน และในชั้นต่อมาผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ จะทำหน้าที่พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง หากเห็นด้วยกับที่กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอชื่อผู้รับจ้างที่ควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ก็จะทำให้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบและแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานได้ทราบด้วย จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการสั่งให้เป็นผู้ทำงานจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและต้องผ่านการพิจารณาในหลายระดับ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากการลงโทษเป็นผู้ทำงานมีระดับความรุนแรงมากดังได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง ในเรื่องนี้มีแนวการวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ ได้หารือเรื่องการสั่งให้เป็นผู้ทำงานไว้ ดังนี้

- กรมประมงว่าจ้างบริษัท ป. ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ผู้รับจ้างมิได้ลงมือก่อสร้างและไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องได้รับความเสียหาย เห็นว่า หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่เริ่มลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาตามสัญญาและมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาด้วยแล้ว ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้พ้นกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก่อน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างย่อมใช้สิทธิต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ ส่วนการพิจารณาว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานหรือไม่ เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่จะพิจารณาตามข้อกำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ สำนักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการเดิม) ไม่อาจพิจารณาในอันที่จะเป็นการก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๒๖)^{๑๘๓}

- องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ก่อสร้างสนามกีฬาโดยแบ่งงานเป็น ๑๒ งวด หลังจากผู้รับจ้างก่อสร้างและรับเงินไปแล้ว ๙ งวด ก็ได้ขโมยเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างหนีออกจากพื้นที่ก่อสร้างไปโดยไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและไม่เข้าก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างรีบเข้าทำงานแล้วก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการเดิม) เห็นว่า กรณีนี้จะถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ละทิ้งงานหรือไม่ นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ แต่หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ

^{๑๘๓} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๘-๑๑๙.

ทำงานได้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ (คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๑๖๑/๒๕๒๘)^{๑๘๔}

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงหลักปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการสั่งให้เป็นผู้ทำงานเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาจริง ๆ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีฉบับต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ออกมาเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดและเพื่อเป็นการชักจูงความเข้าใจของหน่วยราชการ ดังเช่น ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรากฏ ตามหนังสือที่ น.ว. ๓๔/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ยืนยันการให้คว่ำบาตรผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างที่ละทิ้งงาน มิให้หน่วยราชการรับเข้าทำการประมูลก่อสร้างของทางราชการต่อไป โดยให้สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีรวบรวมจัดทำสารบบบริษัทก่อสร้างดังกล่าวแล้วพิมพ์แจกไปตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ไม่ให้รับเข้าประมูล แต่ต่อมาได้มีการผ่อนคลายความเข้มงวดลงโดยให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้างได้มีโอกาสถูกลบชื่อออกจากบัญชีผู้รับเหมาที่ละทิ้งงานหลังจากที่ได้ถูกลงโทษในการกระทำความผิดมาบ้างแล้ว ในช่วงเวลานั้น สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีและกรมโยธาเทศบาลจะร่วมกันพิจารณาการลบชื่อโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการลบชื่อออกจากบัญชีผู้รับเหมาที่ละทิ้งงานมีสาระสำคัญโดยสังเขป คือ ต้องถูกลงโทษตัดสิทธิไม่ให้เข้าประมูลรับเหมาก่อสร้างของทางราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เหตุที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้ทิ้งงานต้องมิได้เกิดจากการกระทำไปด้วยเจตนาทุจริตหรือเป็นการเอาเปรียบทางราชการ เป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคงและมีประวัติดีมาก่อนและได้รู้สำนึกในความผิดที่ได้กระทำไป เป็นต้น

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานขายหรือผู้ทิ้งงานจ้างของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งเนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ค่อนข้างหลากหลายสำหรับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และเมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยเฉพาะ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจนั้น หากไม่มีระเบียบกำหนดเรื่องการลงโทษผู้ทิ้งงานไว้ หรือไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการซื้อและการจ้าง การลงโทษผู้ทิ้งงานก็ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔) จึงได้เห็นชอบให้การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานขายหรือผู้ทิ้งงานจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ห้ามซื้อหรือจ้าง ผู้ทำงานตามระเบียบแต่ละระเบียบดังกล่าวมีผลครอบคลุมไปถึงการซื้อหรือการจ้างของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ทั้งหมดด้วย ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามหนังสือที่ สร. ๐๒๐๓/ว ๗๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔^{๑๘๕} ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทำงาน

^{๑๘๔} สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อหาหรือปัญหา กฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (เล่มที่ ๓), อ้างแล้ว, หน้า ๖๕๒-๖๕๓.

^{๑๘๕} โปรดดูใน www.gprocurement.go.th

โดยในกรณีที่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญากับทางราชการเป็นผู้ทำงานเพื่อความเป็นธรรมจะต้องมีหนังสือแจ้งผู้จะถูกลงโทษทราบและเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงเหตุผลโต้แย้งได้ด้วย ต่อมาเมื่อมีการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาลงโทษผู้ทำงานแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้นคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยอาศัยอำนาจตามความ ในข้อ ๑๒ (๕) และ (๑๕) แห่งระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทำงาน โดยให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการจัดหาตามระเบียบดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษผู้ทำงานและผลการลงโทษผู้ทำงานตามระเบียบที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ และในกรณีที่จะเสนอเรื่องการลงโทษผู้ทำงานให้ส่วนราชการระดับกรมหรือระดับจังหวัดมีหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษให้ผู้ประกอบการทราบและขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ โดยแจ้งไปด้วยว่าถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาจะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรและจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อส่วนราชการได้รับคำชี้แจงดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการทำรายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงว่าผู้ประกอบการดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงานหรือไม่ด้วย ถ้าปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบการดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อผู้ประกอบการไปยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็ว

ในปัจจุบันระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แต่ฉบับแก้ไขที่สำคัญคือ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งข้อ ๔ แห่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕) และยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงโทษผู้ทำงานในส่วนที่ ๘ ข้อ ๑๔๕ ถึงข้อ ๑๔๕ สัตต^{๑๙๖}

^{๑๙๖} โปรดอ่านรายละเอียดใน วรพันธ์ เยนทรัพย์, คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม ๑) ว่าด้วยเรื่องวิธีการซื้อและการจ้าง พร้อมด้วยระเบียบและหนังสือเวียนข้อความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง, บริษัท เอ็ม จำกัด, ๒๕๔๘, หน้า ๑๕๑-๑๕๔.

โดยในข้อ ๑๔๕ วรรคสี่^{๑๔๕} แห่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ทางราชการได้ แต่ในภายหลังปรากฏผลการพิจารณาว่าผู้รักษาการตามระเบียบได้สั่งให้ผู้นั้นเป็นผู้ทำงาน ปลัดกระทรวงจึงมีอำนาจตัดรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาจ้างที่ได้กระทำขึ้นก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ ยกเว้นในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ก็จะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกไป

ส่วนในกรณีที่ปรากฏว่างานที่จ้างเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลารับประกันผลงานตามที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าแก้ไขให้ถูกต้อง หรือในกรณีที่เหตุแห่งความชำรุดบกพร่องอย่างร้ายแรงเกิดจากผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๔๕} หรือในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่ทำโดยผู้รับจ้างที่ทางราชการอนุญาตให้รับจ้างช่วงเนื่องจากการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔)^{๑๔๕} ในกรณีดังกล่าวมาแล้วนี้ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างอาจเสนอชื่อผู้รับจ้างช่วง

^{๑๔๗-๑๔๙} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕

ฯลฯ

ฯลฯ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามข้อกำหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมาผู้รักษาการตามระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่กระทำก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบก็ได้

(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒)

ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) พัส্তুที่ซื้อหรือจ้างทำให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัส্তুที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทำให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง

(๔) สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัส্তুหรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้างหรือใช้โดยผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (๓)

ที่กระทำการผิดสัญญาให้เป็นผู้ทำงานได้ โดยหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะรายงานไปยัง ปลัดกระทรวงให้พิจารณารายชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ปลัดกระทรวงด้วย หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ากระทำการผิดสัญญาของผู้รับจ้างช่วงที่ ทางราชการอนุญาตให้รับจ้างช่วงได้เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและสมควรเป็น ผู้ทำงานแล้ว ปลัดกระทรวงจะส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณา สั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็วตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสอง และวรรคสาม^{๑๙๐}

สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าราย ชื่อที่ถูกเสนอให้เป็นผู้ทำงานดังกล่าวยังไม่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ก็จะต้องรายงาน ให้ กวพ. ทราบด้วย หลังจากที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ฟังความเห็นของ กวพ. และพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ก็ให้ส่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน โดยระบุชื่อผู้ทำงาน ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานให้ส่วนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้งให้ ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย แต่ในกรณีที่เห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควร เป็นผู้ทำงาน ก็ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวงทราบตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก^{๑๙๑} แต่ถ้ามีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดมาแล้วตามข้อ ๑๔๕ ทวิ หรือมีความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาหรือสัญญาจ้างออกแบบ

^{๑๙๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้หัวหน้าส่วนราชการทำรายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการ คัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยัง ผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็ว

^{๑๙๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕ ทวิ

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่เป็นการโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กำหนด หากปลัดกระทรวง พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบด้วย

เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ ๑๒ (๖) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ทำงาน โดยระบุชื่อผู้ทำงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานให้ส่วนราชการอื่น ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

ในกรณีที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทำงาน ให้แจ้งผลการ พิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบ

หรือควบคุมงานที่ก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการตามข้อ ๑๔๕ ตรี หรือการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือการกระทำโดยไม่สุจริตตามข้อ ๑๔๕ จัตวา ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นเป็นผู้ทำงาน และในกรณีดังกล่าวนี้หากปลัดกระทรวงยังไม่ได้รายงานไปยังผู้รักษาตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจมีหนังสือให้ผู้รับจ้างที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ากระทำการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ จากนั้นเมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาคำชี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ก็ให้พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย ส่วนในกรณีที่ไม่มี การชี้แจงภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่ามีความผิดอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอันไม่สุจริต และให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้เป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวงทราบด้วยตามข้อ ๑๔๕ สัตต^{๑๙๒}

ผลของการสั่งลงโทษเป็นผู้ทำงานถือว่ารุนแรงสำหรับผู้รับจ้างที่ถูกสั่งลงโทษ เพราะเมื่อผู้รับจ้างถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามนัยข้อ ๑๔๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ จะต้องมีการแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ ซึ่งจะทำให้ผู้รับจ้างรายดังกล่าวถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้าก่อนนิติสัมพันธ์ในสัญญาซื้อและสัญญาจ้างกับ

^{๑๙๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้รายงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุให้ผู้รักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ

เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้รับคำชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาคำชี้แจงดังกล่าว หากคำชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย

หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบจะได้กำหนดไว้ ให้ถือว่ามีความผิดอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทำโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย

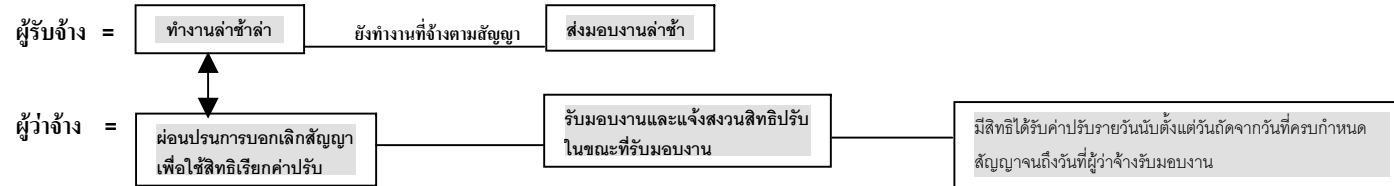
(ความในข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี ข้อ ๑๔๕ จัตวา ข้อ ๑๔๕ จัตวา ข้อ ๑๔๕ เบญจ ข้อ ๑๔๕ ฉ และข้อ ๑๔๕ สัตต เพิ่มเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ส่วนราชการใดๆ ได้ จนกว่าจะถูกเพิกถอนการเป็นผู้ทำงานอันจะทำให้ผู้รับจ้างรายดังกล่าว นอกจากจะถูกบันทึกประวัติไม่ดีแล้ว ยังต้องสูญเสียผลประโยชน์ในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการของส่วนราชการต่างๆ ในขณะที่ส่วนราชการเองก็ต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่ ค้างแทนผู้รับจ้างรายเดิมที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน สำหรับในแง่อำนาจเกี่ยวกับการ สั่งลงโทษเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดเป็น กรณีหนึ่งที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นแก่คู่กรณีในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่แก่คู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานจึงเป็น คำสั่งทางปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙^{๑๙๓} และในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็กำหนดให้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการสั่งการให้เป็นผู้ทำงานเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น คำสั่งทางปกครองในลักษณะนี้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง อย่างหนึ่งนั่นเอง ซึ่งตามแนวคิดของฝรั่งเศสจะถือว่าเป็นนิติกรรมทางปกครองที่สามารถแยกออกจากสัญญาทางปกครองได้ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวจะต้องฟ้องขอให้ ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นๆ

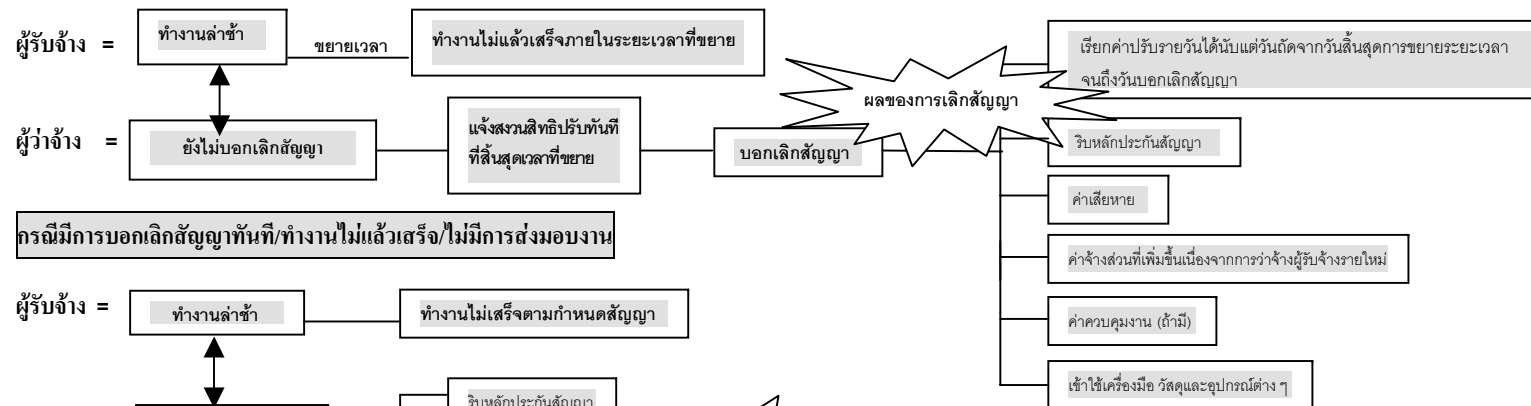
^{๑๙๓} เรื่องเสร็จที่ ๑๓/๒๕๔๓ บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามข้อหารือ ของสำนักนายกรัฐมนตรี นร (กวพ) ๑๓๐๕/๕๙๖๖ ลงวัน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๑

การใช้สิทธิเรียกค่าปรับในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

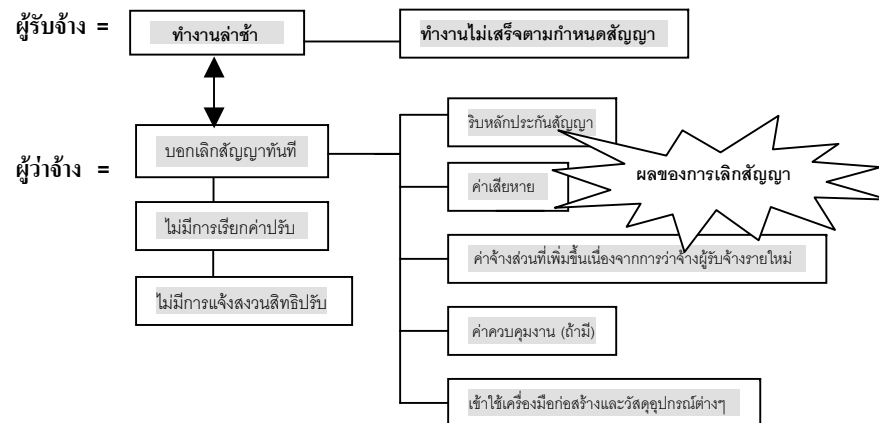
การปรับในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา/ส่งมอบงานล่าช้า



กรณีเลิกสัญญาในระหว่างที่มีการปรับ/ทำงานไม่แล้วเสร็จ/ไม่มีการส่งมอบงาน



กรณีมีการบอกเลิกสัญญาทันที/ทำงานไม่แล้วเสร็จ/ไม่มีการส่งมอบงาน



บทที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ

สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครองกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ในการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น อาคารเรียน อาคารสำนักงาน ถนน การวางท่อประปา คันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการทางวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น จัดเป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงจะสามารถสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีทั้งผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและผู้รับจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลเอกชนฟ้องคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่า เป็นผู้กระทำผิดสัญญาและขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่สัญญาฝ่ายที่กระทำผิดสัญญาชดใช้เงิน เช่น กรณีที่ผู้ว่าจ้างฟ้องว่าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานตามกำหนดเวลาหรือทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หรือส่งมอบงานล่าช้าล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญา หรือทำงานไม่เรียบร้อยหรือไม่แก้ไขงานที่ส่งมอบชำรุดบกพร่อง โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้รับจ้างชดใช้เงินค่าปรับ ค่าเสียหาย เป็นต้น ส่วนผู้รับจ้างอาจนำคดีมาฟ้องว่าผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบกพร่องหรือมีอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าจ้างปรับลดค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจฟ้องว่าผู้ว่าจ้างไม่ชำระค่าจ้างและขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชำระค่าจ้าง หรือในบางกรณีผู้รับจ้าง อาจฟ้องว่าผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยที่รายงานการศึกษาระดับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงาน ทางปกครอง ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างในกรณีที่เอกชนผู้รับจ้างผิดสัญญาเป็นสำคัญ ดังนั้น เนื้อหาในบทที่สามนี้จึงเน้นศึกษาเฉพาะคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่หน่วยงานทางปกครองฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้องที่หน่วยงานทางปกครองมีอยู่ อันเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจของศาลที่จะออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) ข้างต้น เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานทางปกครองจะมีสิทธิเรียกร้องต่างๆ ต่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เมื่อมีการทำผิดสัญญาเกิดขึ้นก็ตาม แต่ก็มีในบางกรณีที่การกระทำผิดสัญญานั้นเป็นผลมาจากพฤติการณ์ที่คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบอยู่ด้วย ซึ่งจากการศึกษาคำวินิจฉัยของศาลปกครองพบว่ามีตัวอย่างปรากฏให้เห็นทั้งกรณีที่เป็นสิทธิเรียกร้องของฝ่ายปกครองและกรณีที่เป็นพฤติการณ์ ซึ่งหน่วย

งานทางปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น โดยจะได้กล่าวถึงทั้งสองกรณีในส่วนของตัวอย่าง คำวินิจฉัยของศาลปกครองต่อไป

อนึ่ง ในการนำเสนอคำวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น ได้เน้นการนำเสนอคำวินิจฉัยของ ศาลปกครองสูงสุดเป็นลำดับแรก เว้นแต่ในกรณีที่ยังไม่ปรากฏคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องนั้นๆ จึงจะนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่เกี่ยวข้องมานำเสนอเพื่อให้ได้ทราบ แนวทางการวินิจฉัยของศาลปกครองเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อน

- กรณีที่เป็นสิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง

สำหรับสิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครองในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ตามที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น ได้แก่ สิทธิต่างๆ ดังนี้

๑. สิทธิเรียกค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า โดยผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา

๑.๑ กรณีผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง อันเนื่องมาจากการจงใจไม่ใช้วัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้การส่งมอบงาน ล่าช้า ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิปรับผู้รับจ้างด้วยเหตุดังกล่าวโดยผู้รับจ้างไม่อาจกล่าวอ้างว่า ความล่าช้าเกิดจากการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้เอี่ยมจวนตันหยงมัส (ผู้รับจ้าง) กับกรมอนามัย (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งแบ่งงาน ออกเป็น ๑๙ งวด ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๘ ภายในกำหนดอายุ สัญญาจ้าง แต่ในงานงวดสุดท้าย ปรากฏว่ายังมีงานที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหลายรายการ เช่น งานระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นการก่อสร้างที่ผิดรูปแบบและรายการ ทำให้ ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซึ่ง ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานดังกล่าวถึงสองครั้ง ต่อมา เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ในครั้งหลังและออกไปรับรองผลการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ใช้สิทธิหักค่าจ้างส่วนหนึ่ง เป็นค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาในสัญญา แต่ผู้รับจ้างเห็นว่า ผู้ ว่าจ้างใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากระยะเวลานับแต่วัน สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้แก้ไขงานระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างใช้ ในการตรวจรับงาน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า สัญญาจ้างที่กำหนดวันชำระหนี้ไว้ ตามวันแห่งปฏิทิน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ในวันดังกล่าวย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดย มิพักต้องเตือนเลยตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง^{๑๙๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

^{๑๙๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ไร ท่านว่า ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด โดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

ส่วนผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการและสัญญาภายในกำหนดเวลาตามสัญญา แต่ในคดีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบในภายหลังว่า ผู้รับจ้างใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ผิดไปจากแบบที่กำหนด อันมิใช่เพียงข้อบกพร่องผิดพลาดในการทำงาน แต่เป็นการจงใจปฏิบัติผิดสัญญาจ้างโดยรู้ดีอยู่แล้วว่างานที่ทำไม่ถูกต้องตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานที่ผิดแบบและบกพร่อง ทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ผู้รับจ้างก็ไม่อาจอ้างว่ามีเหตุมาจากความล่าช้าในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเพราะผู้รับจ้างย่อมรู้ว่าตนปฏิบัติไม่ถูกต้องและมีหน้าที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนส่งมอบงานไม่ใช่รอให้คณะกรรมการฯ ตรวจผลแล้วจึงแก้ไข ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรับผู้รับจ้างเพราะส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แก้ไขแล้วเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒/๒๕๔๖)

๑.๒ กรณีผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานล่าช้า ทำให้ส่งมอบงานล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างย่อมไม่อาจกล่าวอ้างเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นภายหลังกำหนดส่งมอบงานเพื่อให้ได้รับการลดหรือยกเว้นค่าปรับ

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงถนนเสริมดินลงลูกรังเสริมคันคลองจำนวนสองโครงการ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธุ์รักษ์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานโครงการที่สองล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานล่าช้ากว่ากำหนดและหยุดงานเป็นระยะๆ ด้วยเหตุมีฝนตกและพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ งานที่แล้วเสร็จยังมีข้อบกพร่อง ผู้ว่าจ้างจึงไม่ตรวจรับงานและสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไข รวมทั้งใช้สิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาในระหว่างที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าโดยไม่ขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาให้เนื่องจากผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่มีเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๔๔} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อผู้รับจ้างได้แก้ไขและส่งมอบงานแล้ว ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานและเรียกค่าปรับโดยหักเอาจากค่าจ้าง แต่ผู้รับจ้างเห็นว่า การปรับดังกล่าวไม่ควรรวมวันที่มีน้ำท่วมเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมได้เกิดขึ้นหลังจากพ้นกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้างแล้ว และเห็นว่าช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย เพราะหากผู้รับจ้างเข้าทำงานตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาก็อาจทำงานให้แล้ว

^{๑๔๔} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๖๑ การลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาการทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อนตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑	๑.๑
(๒) เหตุสุดวิสัย	
๑.๑	๑.๑

เสร็จภายในเวลาตามที่กำหนดในสัญญาได้ ซึ่งเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ดังนั้น การเกิดฝนตกที่จะถือเป็นเหตุสุดวิสัยได้จะต้องเป็นกรณีที่ฝนตกหนักมากผิดไปจากปกติที่เคยเกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าเท่านั้น และการเกิดน้ำท่วมในบริเวณก่อสร้างต้องพึงได้ว่าไม่อาจหาทางป้องกันได้ แม้จะได้หาทางจัดการระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้รับจ้างมีส่วนผิดด้วย สำหรับในกรณีที่ผู้รับจ้างอ้างถึงอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้างนั้น เห็นว่า ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง สอบราคาจ้างฯ ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างไม่ไปดูสถานที่ก่อนตามประกาศ จึงถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถอ้างเป็นเหตุให้พ้นความรับผิดชอบได้และไม่ถือเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างที่จะทำให้ผู้รับจ้างได้รับการลดหรือตัดเว้นค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ตามข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๙๖} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ส่วนการที่ผู้ว่าจ้างไม่ตรวจรับงานของผู้รับจ้างในการส่งมอบครั้งก่อน เนื่องจากผู้รับจ้างมิได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีจึงเป็นผลมาจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าเงินค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างปรับสูงเกินส่วน ศาลสามารถปรับลดลงบางส่วนตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง^{๑๙๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/๒๕๔๘)

^{๑๙๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๖๑ การลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อนตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสภาตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๙๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๓ ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป

ฯลฯ

ฯลฯ

๑.๓ กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าทั้งที่มีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างอันมีผลเป็นการลดเนื้อหาผลงาน จึงไม่มีเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงต้องชำระค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ระหว่างบริษัท รัฐพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด (ผู้รับจ้าง) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เดิม) (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ประกาศสอบราคาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วย เพื่อให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้โดยไม่มีปัญหาภายหลัง และต้องเสนอหลักฐานการดูสถานที่ก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างได้รับรองแล้วเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานสำคัญประกอบการเสนอราคา เมื่อผู้รับจ้างได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาและเข้าทำสัญญาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างได้ให้วิศวกรควบคุมงานซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมเข้าทำการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินในพื้นที่ก่อสร้างและเห็นว่าสามารถทำการก่อสร้างฐานรากแบบแผ่โดยไม่ต้องตอกเข็มได้ผู้รับจ้างจึงนำเหตุผลดังกล่าวมาขอแก้ไขสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง โดยจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างให้ก่อสร้างอาคารโดยงดตอกเข็ม และยินยอมคืนเงินค่าเข็มให้ผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังได้ขอให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดทำการทดสอบและออกใบรับรองสภาพการรับน้ำหนักดินบริเวณที่จะก่อสร้างด้วย จากนั้นผู้รับจ้างได้ขออนุมัติเข้าทำการก่อสร้างต่อไป โดยผู้ว่าจ้างมิได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการทำงานหรือห้ามปรามมิให้ผู้รับจ้างทำงาน ต่อมาผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาทำงานในระหว่างที่ต้องรอผลการรับรองให้ก่อสร้างโดยงดตอกเข็มจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัด แต่ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตและยังแจ้งสงวนสิทธิปรับเมื่อครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้หักค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าจากเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างเนื่องจากผู้ว่าจ้างเห็นว่าได้แก้ไขสัญญาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารโดยงดตอกเข็มแล้ว และได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน จึงไม่มีเหตุผลที่จะขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า แม้ว่าในระหว่างที่ผู้รับจ้างทำงานตอกเข็ม จะไม่สามารถทำงานในส่วนอื่นได้เพราะงานก่อสร้างอาคารในส่วนอื่นจะทำได้เมื่องานตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างต้องใช้เวลาในการแก้ไขสัญญาให้งดตอกเข็มก็ตาม แต่เมื่อมีการแก้ไขสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องทำงานตอกเข็มอีกต่อไป ดังนั้น เวลาที่ผู้รับจ้างจะใช้ทำงานส่วนอื่นที่มีช่างงานตอกเข็มยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จึงไม่มีเหตุที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาออกไป ดังนั้น เมื่อ ครบกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้แล้ว ผู้รับจ้างจึงต้อง

ชำระค่าปรับ อันเนื่องมาจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเอาเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายได้ (คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ ๕๒๕/๒๕๔๙^{๑๔๘})

จากตัวอย่างคำพิพากษาทั้งสามฉบับดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญาในทันทีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญา หากแต่ให้โอกาสผู้รับจ้างทำงานต่อให้แล้วเสร็จโดยได้สงวนการใช้สิทธิเรียกค่าปรับไว้ก่อน ซึ่งทั้งสามคดีดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ามีสาเหตุมาจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ว่าจ้างมีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแต่ประการใด หากแต่เป็นความบกพร่องในการทำงานของผู้รับจ้างเองหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับได้ (เมื่อได้มีการแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้แล้ว) โดยหักจากค่าจ้างที่ต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

๒. สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

๒.๑ กรณีที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้างให้แล้ว โดยระบุในหนังสือดังกล่าวให้มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกำหนดเร่งรัดนั้น เมื่อสัญญาเลิกกันด้วยเหตุข้างต้น ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิเรียกค่าปรับและค่าเสียหายอื่น ๆ ตามสัญญาได้

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ว่าจ้าง) กับห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคนิคก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) ซึ่งสัญญาพิพาทมีข้อกำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้างเนื่องจากการบอกเลิกสัญญามีได้ นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังการบอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกินกว่าจำนวนหลักประกันดังกล่าว รวมทั้งเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะต้องทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามสัญญา ในระหว่างสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างโดยทำเป็นบันทึกต่อท้ายสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้ว ๗ ครั้ง แต่ในระหว่างรอผลการขออนุญาตขยายระยะเวลาครั้งใหม่ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ว่าจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือบอกปิดการเลิกสัญญาพร้อมกับเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือ หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้ว่าจ้างขอถือเอาหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา

^{๑๔๘} คดีนี้ไม่มีอุทธรณ์

ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้เข้าทำงานอีกต่อไป ผู้ว่าจ้างจึงจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานที่เหลือแทนและต่อมาผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้รับจ้างชำระเงินค่าเสียหายในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานต่อจนแล้วเสร็จ รวมทั้งค่าปรับรายวันที่ผู้รับจ้างต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ยอมชำระ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีผู้ว่าจ้างมีหนังสือเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้ว่าจ้างถือเอาหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญานั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำงานให้แล้วเสร็จ จึงถือว่าการบอกเลิกสัญญามีผลนับถัดจากวันที่ครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้วและได้สงวนสิทธิปรับและเรียกค่าเสียหายต่างๆ ตามสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิบังคับให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่และเรียกค่าปรับ รวมทั้งค่าเสียหายจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ โดยสิทธิของผู้ว่าจ้างเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑/๒๕๔๙)

๒.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเพียงบางส่วนและเป็นผลงานที่ชำรุดบกพร่องโดยไม่ยอมเข้าแก้ไขงานดังกล่าวจนล่วงเลยระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างขยายให้ ต่อมาเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้รับจ้างรายอื่นให้ทำงานแทน ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าปรับ รับผิดประกันสัญญาและสิทธิอื่น ๆ ตามกฎหมายจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งเรียกค่าเสียหายในส่วน of ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นจากผู้รับจ้างรายเดิม

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจดับเพลิงและอาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท กุลอรินญชัย วิศวกรรม จำกัด (ผู้รับจ้าง) ซึ่งมีกำหนดการจ่ายเงินตามงวดงานเป็น ๓ งาน รวม ๒๔ งวด ในระหว่างสัญญา ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาการทำงานให้แก่ผู้รับจ้างรวมสองครั้ง และมีการแก้ไขปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจากเดิม ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเพียงบางส่วนและบางงานมีความบกพร่องไม่เป็นไปตามรูปแบบ ผู้ว่าจ้างจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขงาน แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าแก้ไข จนล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาออกไป ผู้ว่าจ้างจึงแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ รับผิดประกันสัญญา และสิทธิอื่นๆ ที่พึงมีตามกฎหมาย ต่อมาได้บอกเลิกสัญญาจ้างและได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานส่วนที่เหลือ โดยมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นกว่าจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเดิม ผู้ว่าจ้างจึงเรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามสัญญาพิพาท หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายปกครองมีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามสัญญา โดยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวและแม้ว่าผู้รับจ้างจะยังทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะ

เวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะยังไม่บอกเลิกสัญญาก็ได้ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับรายวันได้ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการบอกเลิกสัญญา และต้องมีการปรับนั้น ถ้าจำนวนเงินค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับรายวันได้ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิจ้างผู้อื่นเข้าทำงานต่อจนแล้วเสร็จ โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายอื่นด้วย ดังนั้น ทั้งค่าปรับรายวันและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานต่อจากผู้รับจ้างจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาอันทำให้สัญญานั้นสิ้นสุดลง การนำคดีมาฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจึงต้องเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๔๘)

๒.๓ กรณีผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจนสัญญาสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาโดยต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทน ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิเรียกค่าปรับตั้งแต่วันครบกำหนดจนถึงวันบอกเลิกสัญญา รวมทั้งมีสิทธิริบหลักประกัน เรียกค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าหลักประกัน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานต่อจนแล้วเสร็จ ตลอดจนมีสิทธิใช้เครื่องมือในการก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่ผู้รับจ้างเดิมได้จัดหาไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำงานซ่อมเสริมหลังคันคลองส่งน้ำระหว่างกรมชลประทาน (ผู้ว่าจ้าง) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมจักร อยู่ คง สุข คุ่มครอง พัฒนา ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) โดยผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานตามสัญญา แม้อต่อมาผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือเร่งรัดให้เข้าทำงานอีกหลายครั้ง แต่ผู้รับจ้างก็ยังเพิกเฉย เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิในการริบหลักประกันสัญญาและเรียก ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ ต่อมา เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วผู้ว่าจ้างได้เรียกค่าปรับ และแจ้งริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเรียกค่าเสียหายในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ยอมชำระเงินดังกล่าว ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับตามข้อสัญญาซึ่งกำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจำต้องชำระค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนับถัดจากวันที่

ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา และหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิภายหลังการบอกเลิกสัญญาได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานตามใบรับฝากบริการไปรษณีย์ในประเทศ ป. ๒๑๑ ว่าหนังสือดังกล่าวได้รับไว้ เพื่อนำส่งแก่ผู้รับจ้าง กรณีต้องถือว่าผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งแล้ว เมื่อครบกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งทางไปรษณีย์ภายในประเทศ การบอกเลิกสัญญาจึงมีผลตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ๗ วันดังกล่าว และเมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิปรับไว้แล้ว จึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับโดยระบุจำนวนเงินที่แน่นอนไว้ พร้อมกับหนังสือบอกเลิกสัญญา กรณีจึงต้องถือว่าผู้ว่าจ้างประสงค์จะเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเพียงจำนวนเงินเท่าที่ระบุไว้ เมื่อผู้รับจ้างมิได้นำเงินไปชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างจึงเรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิตามข้อสัญญาซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่มีสิทธิใช้เครื่องมือในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร และผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าหลักประกันดังกล่าว รวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓๐/๒๕๔๙)^{๑๙๙}

จากตัวอย่างคำวินิจฉัยทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้นเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาในขณะที่มีการปรับ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยทั้งสามคดีนี้ปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้แจ้งเรียกค่าปรับและสงวนสิทธิปรับก่อนบอกเลิกสัญญา อันมีผลทำให้เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจึงสามารถเรียกค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา รวมทั้งสามารถเรียกค่าเสียหายและรับหลักประกันสัญญาได้ นอกจากนั้น ยังมีคำวินิจฉัยที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานต่อจนแล้วเสร็จ ซึ่งการใช้สิทธิเรียกเงินดังกล่าวนั้นศาลได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่า ทั้งค่าปรับรายวันและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ้างบุคคลอื่นเข้าทำงานต่อจากผู้รับจ้างเดิมเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับให้ผู้รับจ้าง

^{๑๙๙} คดีนี้ไม่มีอุทธรณ์

ชำระค่าเสียหายดังกล่าวได้เมื่อผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาอันทำให้สัญญานั้นสิ้นสุดลง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๔๘)

ทั้งนี้ นอกจากการเรียกค่าปรับและค่าเสียหายต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในกรณีที่มีข้อสัญญากำหนดไว้ ผู้รับจ้างรายใหม่ที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้เข้าทำงานแทนผู้รับจ้างเดิมซึ่งกระทำผิดสัญญา ยังมีสิทธิใช้เครื่องมือในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่ผู้รับจ้างเดิมจัดหาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอีกด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓๐/๑๕๔๙)

นอกจากนั้น ยังมีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเกี่ยวกับผลทางกฎหมาย ภายหลังการบอกเลิกสัญญาด้วยว่าเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วจะต้องให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑^{๒๐๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้เมื่อไม่มีสัญญาอยู่ หนี้ตามสัญญาย่อมระงับไปด้วย ความผูกพันระหว่าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงสิ้นสุดลง ผลผูกพันลง ทำให้คู่สัญญาไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอีกต่อไป แต่กระนั้นคู่สัญญายังคงมีความรับผิดชอบต่อกัน โดยคู่สัญญาฝ่ายเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเรียกร้อง ภายหลังการบอกเลิกสัญญาได้ เช่น เรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ อันนอกเหนือไปจากสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ซึ่งมีอยู่แล้วก่อนการบอกเลิกสัญญา เช่น การเรียกค่าปรับ รับผิดชอบประกันสัญญา ค่าควบคุมงาน (ถ้ามี) เป็นต้น โดยปรากฏตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำหรับจัดแสดงนิทรรศการของทางราชการระหว่างกรมทรัพยากรธรณี (ผู้ว่าจ้าง) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญฤทธิ์การค้า (ผู้รับจ้าง) ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แม้ผู้ว่าจ้างจะได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างแล้วก็ตาม ผู้ว่าจ้างจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและชำระค่าปรับเป็นรายวันนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันส่งมอบครบถ้วน แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง ประธานกรรมการตรวจการจ้างจึงเห็นควรบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานอีกครั้ง แต่ผู้รับจ้างยังเพิกเฉยอันเป็นการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับรายวันและเรียกให้ผู้จำประกันชำระเงิน ต่อมา ผู้ว่าจ้างได้ทำ

^{๒๐๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้นท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่วันที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้นการที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอนแทนก็ให้ใช้ตามนั้น

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

สัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จากนั้นผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อหักจากเงินค้ำประกันแล้ว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้คัดค้านการดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่แต่ประการใด จึงถือว่าผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยาย มีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้และถือว่าวันที่ทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ คือ วันที่ผู้ว่าจ้างรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีการที่ผู้ว่าจ้างทำหนังสือบอกเลิกสัญญาถึงผู้รับจ้างเพื่อบอกเลิกสัญญาอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังจากวันที่ทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ ย่อมไม่ทำให้วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙/๒๕๔๗)

หมายเหตุ ตุลาการเสียงข้างน้อยในองค์คณะพิจารณาพิพากษา (นายเฉลิมชัย วสินนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด) มีความเห็นแย้งว่า คดีนี้เป็นการฟ้องเรียกให้ชำระค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามกำหนดเวลาในสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๑๘๐ วันภายหลังครบกำหนดตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจึงตกเป็น ผู้ผิดนัดและผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกให้ชำระค่าปรับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดขยายเวลาส่งมอบงานโดยถือว่าผู้ว่าจ้างรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันดังกล่าว

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างชุดลอกอ่างเก็บน้ำระหว่างกรมชลประทาน (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท พินุลย์มหาสารคาม จำกัด (ผู้รับจ้าง) ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและมีได้ใช้เครื่องมือตามแผนงานที่เสนอไว้ โดยผู้ว่าจ้างได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะบอกเลิกสัญญา แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉย ผู้ว่าจ้างจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา ระบุหลักประกันสัญญาและเรียกค่าปรับ โดยผู้รับจ้างได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ยอมนำเงินมาชำระ ทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องบังคับตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^{๒๐๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงทำสัญญากัน แต่การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไม่กระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่^{๒๐๒} ในคดีนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิตามข้อสัญญาที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระเบี้ยปรับตามสัญญาได้อีก แต่การใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายของผู้ว่าจ้าง การเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้างจึงเป็นกรณีที่ถือว่าผู้ว่าจ้างประสงค์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

^{๒๐๑-๒๐๒} อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒๐๐ หน้า ๑๒๗

แห่งค่าเสียหายซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง^{๒๐๓}
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่))

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการการสื่อสารโทรคมนาคม
ระหว่าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท เบสท์เฮาส์ จำกัด
(ผู้รับจ้าง) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวด
ที่ ๑ ถึงที่ ๕ และงานงวดสุดท้ายบางส่วน แต่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำการก่อสร้างแทน
จนแล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากส่วนต่างของค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ แต่ผู้รับจ้างไม่ชำระเงินดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัยว่า ผลแห่งการบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้างทำให้สัญญาเลิกกัน กรณีจึงต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ ซึ่งจะมีผลตามกฎหมายให้คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
กลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่การใช้สิทธิเลิกสัญญาหากกระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายไม่สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายของผู้ว่าจ้างจึงเกิดขึ้นตั้งแต่สัญญาระหว่างคู่สัญญาเลิกกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๙๙/๒๕๔๘)

จากตัวอย่างคำวินิจฉัยทั้งสามคำวินิจฉัยดังกล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้ว่าจ้าง
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง
ซึ่งบัญญัติให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงทำสัญญากัน
แต่การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหากกระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่
ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ โดยในคำวินิจฉัยแรก คือ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๙/๒๕๔๗
เป็นกรณีผู้ว่าจ้างได้เรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเนื่องจากทำงานล่าช้าล่วงเลยกำหนดเวลาใน
สัญญาไว้ก่อนที่จะบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานต่อให้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจึงได้ ว่า
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทน โดยผู้รับจ้างรายเดิมมิได้คัดค้านแต่ประการใด กรณีจึง
เป็นการบอกเลิกสัญญากันโดยปริยาย มีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายได้ ส่วน
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) และคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๙๙/๒๕๔๘ เป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างมิได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับและแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ก่อนบอกเลิก
สัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ย่อมไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระเบี้ยปรับ
ได้ แต่การที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาไม่กระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากผู้รับจ้าง

^{๒๐๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับ
นั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้

กระทำผิดสัญญา โดยใน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) ศาลได้วินิจฉัยด้วยว่าการเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้างเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้กับผู้ว่าจ้างประสงค์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งค่าเสียหายที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในส่วนที่เกี่ยวกับการกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ได้มีคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับผลของการบอกเลิกสัญญาที่ทำให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตราดังกล่าวไว้เช่นกัน แต่มีความแตกต่างจากคำวินิจฉัยทั้งสามคำวินิจฉัยข้างต้นตรงที่การบอกเลิกสัญญาตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการเลิกสัญญากันโดยปริยาย ดังนี้

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางวิชาการและการประชุมนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ว่าจ้างได้ทำสัญญาจ้างบริษัทอื่นให้ออกแบบ โดยในขณะที่ออกแบบยังไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ในบริเวณก่อสร้าง แต่หลังจากการออกแบบแล้วเสร็จกระทรวงการคลังได้ดำเนินการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับการก่อสร้างสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ แต่ผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขแบบอาคารดังกล่าวก่อนดำเนินการประกวดราคา ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญาจ้างจึงพบว่าพื้นที่ก่อสร้างมีบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินทำให้ค่าระดับดินต่ำกว่าที่ระบุไว้ในแบบอาคาร ผู้รับจ้างได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวภายในหนึ่งเดือน หากไม่มีการแก้ไขให้สัญญาเลิกกัน แต่ผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขและมีได้ขยายระยะเวลาทำงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถลงมือก่อสร้างตามสัญญาได้ ต่อมาผู้ว่าจ้างได้ให้บริษัทรับจ้างออกแบบฯ แก้ไขรูปแบบและรายการ และให้ผู้รับจ้างปรับค่าระดับดินให้สูงเท่าที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างในงานส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่มิได้แก้ไขสัญญาจ้างในส่วนงานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ต่อมาผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเพราะผู้รับจ้างมิได้ลงมือก่อสร้างภายในเวลาที่กำหนด หากให้ทำต่อไปก็มีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด โดยผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่าจากข้อเท็จจริงแสดงว่าผู้รับจ้างลงมือทำงานตามสัญญาแล้ว แต่มีปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ซึ่งผู้รับจ้างได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น แต่ผู้ว่าจ้างมิได้เข้าแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวก่อนจะมีหนังสือบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ว่าจ้างจะได้มีการแก้ไขแบบอาคารใหม่และจ้างผู้รับจ้างปรับระดับค่าดินอันเป็นงานพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างก็ตาม แต่ก็มิได้แก้ไขสัญญาโดยนำแบบอาคารที่แก้ไขใหม่มาแทนแบบอาคารเก่าที่ตั้งข้อชนบ่อบำบัดน้ำเสียและมีได้แก้ไขสัญญาในส่วนการปรับระดับค่าดิน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากผู้ว่าจ้างแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้างต้นแล้วก็ต้องขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา

ให้แก่ผู้รับจ้างตามนัยข้อ ๑๓๙^{๒๐๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ เนื่องจากเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจอ้างว่าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยข้อสัญญาและไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ได้ เมื่อการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับจ้างและผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามก็ดี คดีนี้ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเพราะไม่ต้องการให้ผู้รับจ้างทำงานต่อไป และก่อนหน้านี้ผู้รับจ้างก็มีความประสงค์จะเลิกสัญญากับผู้ว่าจ้างเพราะไม่ประสงค์จะก่อสร้างอาคารดังกล่าวอีกต่อไป จึงถือว่ามี การเลิกสัญญากันโดยปริยาย โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๕๒๘/๒๕๔๙)^{๒๐๕}

จากคำวินิจฉัยข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีส่วนต้องรับผิดชอบเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างบกพร่อง ทำให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานตามกำหนดไม่ได้ ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ว่าจ้างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีข้อสังเกตว่าแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมีหลักว่า คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ตามข้อสัญญา แต่เอกชนคู่สัญญาไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อน ในคดีนี้ แม้เอกชนคู่สัญญาขอเลิกสัญญาไว้ก่อนแล้วก็ได้มีผลให้สัญญาเลิกกัน เพราะคู่สัญญาฝ่ายปกครองยังประสงค์ให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาต่อไปให้แล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อเอกชนคู่สัญญาไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จ คู่สัญญาฝ่ายปกครองจึงบอกเลิกสัญญา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคู่สัญญาฝ่ายปกครองยังคงเป็นฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งโดยปกติตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ก็จะกำหนดไว้เช่นนั้น แต่ด้วยในคดีนี้คู่สัญญาฝ่ายปกครองส่งมอบพื้นที่บกพร่องและต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว ทำให้การบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ ศาลจึงวินิจฉัยว่า การที่เอกชนคู่สัญญาได้แจ้งความประสงค์

^{๒๐๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือส่วนราชการทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

^{๒๐๕} คดีนี้อยู่ในระหว่างอุทธรณ์

ขอเลิกสัญญาไว้ก่อนแล้วเพราะไม่ประสงค์จะทำงานต่อไป กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการเลิกสัญญากันโดยปริยาย โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓. สิทธิไม่จ่ายค่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ถือว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิไม่ตรวจรับงานและไม่ชำระค่าจ้างตามสัญญาได้

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างปรับปรุงห้องสุขาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ว่าจ้าง) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ที-สแควร์ ซัพพลายส์ (ผู้รับจ้าง) ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างไม่ตรวจรับงานเนื่องจากงานที่ทำไม่เรียบร้อยตามแบบรูปและรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ดำเนินการแล้ว ยกเว้นปัญหาการวางท่อระบายน้ำออกจากถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผู้รับจ้างชี้แจงว่าไม่สามารถทำตามขั้นตอนการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิตถังบำบัดน้ำเสียได้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างรับที่จะแก้ไขให้โดยขอให้ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานก่อน ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ผู้รับจ้างมีหน้าที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามขั้นตอนการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิตถังบำบัดน้ำเสีย หากมีปัญหาในระหว่างการติดตั้งก็ควรแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังกล่าว การที่ผู้รับจ้างติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต ถือว่าผู้รับจ้างยังดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจตรวจรับงานได้และไม่ต้องชำระค่าจ้างตามสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๒๔๔/๒๕๔๙)^{๒๐๖}

กรณีดังกล่าวข้างต้นมีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะทำงานต่อไปจนแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ในขณะที่ผู้ว่าจ้างเองก็ยังไม่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ดังนั้น ผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการและส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยตามสัญญา โดยหากเป็นการส่งมอบงานล่าช้า ผู้ว่าจ้างย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกค่าปรับได้หากได้แจ้ง สวณสิทธิปรับไว้แล้วในขณะที่มีการส่งมอบงาน

๔. สิทธิเรียกค่าเสียหายกรณีทีมงานซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบเกิดความชำรุดบกพร่อง

การที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในค่าเสียหายจากการที่ต้องซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าว

^{๒๐๖} คดีนี้ไม่มีอุทธรณ์

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างหอประชุมกองทัพเรือพร้อมงานสถาปัตยกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างกองทัพเรือ (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท กิรสิทธิ์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้ว ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่างานดังกล่าวมีความชำรุดบกพร่องหลายรายการ จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้รับจ้างได้แก้ไขเพียงบางรายการเท่านั้น ผู้ว่าจ้างจึงเรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่อง ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า การที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องเพียงบางรายการ แสดงว่าผู้รับจ้างยอมรับว่างานมีความชำรุดบกพร่องจริงตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้แก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสองปีนับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องของงานดังกล่าวร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ค้าประกัน โดยนำค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างได้ใช้เพื่อซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องไปแล้วบางรายการมาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๕๐๖/๒๕๔๙)^{๒๐๗}

กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาโดยมีระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่อง คู่สัญญาสามารถตกลงกันให้แตกต่างกันไปจากที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับผิดชอบภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบงานตามมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ เพราะมิใช่เรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น หากผู้รับจ้างไม่รับผิดชอบหรือไม่ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างย่อมต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๕. สิทธิสั่งลงโทษผู้รับจ้างให้เป็นผู้ทำงาน

แม้ว่าผู้รับจ้างจะได้เข้าแก้ไขข้อบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง แต่เมื่อไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างทราบ กรณีจึงเข้าหลักเกณฑ์ที่จะถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓)^{๒๐๘} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๒๐๗} คดีนี้ไม่มีอุทธรณ์

^{๒๐๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑.ลข

๑.ลข

(๓) พัสดู้ที่ซื้อหรือจ้างทำ เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดู้ที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐานหรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทำให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ

๑.ลข

๑.ลข

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการสั่งให้เป็นผู้ทำงานระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญวิศวกรรม (ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งทำไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ว่าจ้างซึ่งในข้อ ๖ ของสัญญาจ้างได้กำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบการจ้างไว้ว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายในกำหนดสองปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว โดยความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเนื่องจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกระทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้กระทำการนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบและจ่ายค่าจ้างครบถ้วนแล้ว ผู้ว่าจ้างได้จัดให้ส่วนราชการเข้าปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวจึงพบว่าอาคารที่ผู้รับจ้างก่อสร้างมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามสัญญารวม ๔ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๒ และที่ ๔ ได้แจ้งด้วยว่า หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขความบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกลงโทษให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ส่วนในครั้งที่ ๓ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างไปชี้แจงเหตุผลที่ไม่เข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ไปชี้แจงจะถือว่าไม่มีเหตุผลอันควรและจะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงของทางราชการเพียงฝ่ายเดียว ต่อมา ผู้รับจ้างได้แต่งตั้งบุคคลเข้าดูและรับผิดชอบซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องแต่ไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจึงมีหนังสือเป็นครั้งที่ ๔ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการจะถูกแจ้งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้างต้น แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉย ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจึงรายงานข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาลงโทษให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน โดยเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้รับจ้างที่ไม่เข้าแก้ไขความ ชำรุดบกพร่องให้แล้วเสร็จและไม่แจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ทราบ เป็นการแสดงเจตนาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างในข้อ ๖ ข้างต้น

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๒๐๘ หน้า ๑๓๑)

ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้ผู้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเสนอความเห็นและส่งชื่อผู้รับจ้างเพื่อให้พิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานต่อไปตามนัยข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม^{๒๐๙} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อมาที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงาน (อทง.) พิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้รับจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษให้เป็นผู้ทำงานได้ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จึงเสนอความเห็นให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานและระบุชื่อผู้ทำงานไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้รับจ้างให้ส่วนราชการอื่นทราบต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเห็นชอบตามความเห็นของ อทง. ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ และในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดียังได้พิจารณามีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้เป็นผู้ทำงาน จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องตามสัญญาผู้รับจ้างได้แต่งตั้งบุคคลของตนขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่อง จึงเท่ากับว่าผู้รับจ้างได้ยอมรับแล้วว่างานที่ชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ทั้งนี้ แม้ว่าผู้รับจ้างจะได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่ผู้รับจ้างก็ยังคงมีภาระผูกพันตามข้อสัญญาที่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนดสองปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานจ้าง เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเพียงบางส่วนโดยไม่ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ ทั้งที่ ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าแก้ไขงานแล้วหลายครั้งโดยผู้รับจ้างมิได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ว่าจ้างทราบ จึงเป็นกรณีงานจ้างเกิดข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้าง ไม่เข้าแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้รับจ้างจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๓๕๐/๒๕๕๔^{๒๑๐})

จากคำวินิจฉัยดังกล่าว เห็นได้ว่าสัญญาจ้างในข้อ ๖ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในกำหนดสองปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว นั้น เป็นการกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุด

^{๒๐๙} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๕ ทวิ ๗๗ ๗๗

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็ว

๗๗ ๗๗

^{๒๑๐} คดีนี้ไม่มีอุทธรณ์

บกพร่องแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบตามมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันส่งมอบ ผู้รับจ้างจึงต้องรับผิดชอบด้วยการเข้าแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการตามข้อสัญญา เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาลงโทษให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ

- กรณีที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครอง

จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองตามประเด็นต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นกรณี que แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทางปกครองมีสิทธิเรียกร้องในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยงานทางปกครองจะมีสิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชน แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางกรณีที่หน่วยงานทางปกครองมีส่วนที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับเอกชนในผลอันเกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเองด้วยเช่นกัน ได้แก่

๑. กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเดิมภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแล้วจะถือว่าวันสิ้นสุดอายุสัญญาตามวันสิ้นสุดสัญญาเดิมไม่ได้

กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างภายหลังจากที่กำหนดเวลาตามสัญญาสิ้นสุดแล้วเพื่อให้ข้อสัญญาตรงกับข้อเท็จจริงที่ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตามแผนผังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับจ้าง แม้สัญญาที่แก้ไขใหม่จะไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาขึ้นใหม่หรือยกเลิกกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างเดิมก็ตาม แต่เมื่อมีการส่งมอบงานล่าช้าภายหลังจากวันที่มีการแก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างย่อมไม่อาจรวมเอาระยะเวลานับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างเดิมจนถึงวันที่มีการแก้ไขสัญญาไว้ในระยะเวลาในการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างกรณีส่งมอบล่าช้า เพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างยังคงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้ เนื่องจากในกรณีนี้ต้องถือว่าวันที่มีการแก้ไขสัญญาเป็นวันสิ้นสุดตามสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างทัศนสถานบำบัดพิเศษระหว่างบริษัท เจริญทอง (๑๙๙๘) จำกัด (ผู้รับจ้าง) กับกรมราชทัณฑ์ (ผู้ว่าจ้าง) โดยในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างได้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนผังที่มีการปรับเปลี่ยนดังกล่าวโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขสัญญาจ้างเดิม ต่อมาภายหลังจากที่สัญญาฉบับเดิมสิ้นสุดลงแล้ว จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิมเพื่อให้ตรงกับงานที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างไปแล้วโดยมิได้ระบุข้อความให้นับวันแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างฉบับใหม่หรือให้ยกเลิกกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเดิมแล้วกำหนดวันแล้วเสร็จขึ้นใหม่แต่อย่างใด ซึ่งในวันที่มีการ

แก้ไขสัญญา นั้น ผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน แต่ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาต ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างได้ปรับผู้รับจ้างเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าใน อัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมจนถึงวันทำงานเสร็จสมบูรณ์ โดยหักจากเงินค่าจ้างของงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างเห็นว่าตนไม่ได้กระทำผิดสัญญาและการแก้ไขสัญญา มีผลทำให้ระยะเวลาก่อสร้างขยายออกไปนับแต่วันที่มีการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้าง จึงขอให้ผู้ว่าจ้างคืนค่าปรับ แต่ผู้ว่าจ้างปฏิเสธ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารของผู้ว่าจ้างซึ่งดำเนินการภายหลังจากครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญานั้น แม้จะไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดในสัญญาให้นับวันแล้วเสร็จตามสัญญาใหม่ เป็นนับถัดจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา หรือให้ยกเลิกกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา เดิม แต่เนื่องจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม ซึ่งในการพิจารณาตรวจ รับงาน ผู้ว่าจ้างย่อมต้องพิจารณาจากเงื่อนไขของสัญญาเดิมและสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น สาระสำคัญ ดังนั้น เมื่อมีการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมจึงจะถือว่าวันสิ้นสุดอายุสัญญาตามวันสิ้นสุดสัญญาเดิมไม่ได้ ฉะนั้น ระยะเวลาตั้งแต่กำหนดเวลาสิ้นสุดตาม สัญญาเดิมจนถึงวันที่มีการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างจึงยังคงสามารถส่งมอบงานตามสัญญา ในช่วง เวลานั้น จึงถือว่าวันที่มีการแก้ไขสัญญาเป็นวันสิ้นสุดสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้าง จึงมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการแก้ไขสัญญาจนถึงวันที่มีการส่งมอบงาน งวดสุดท้าย การที่ผู้ว่าจ้างปรับผู้รับจ้างโดยนับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนด ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเดิมจนถึงวันแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาไว้ด้วย จึงเป็นการปรับที่ไม่ถูกต้อง ผู้ ว่าจ้างจึงต้องคืนเงินค่าปรับส่วนที่หักไว้เกินให้แก่ผู้รับจ้าง รวมทั้งต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นดอก เบี้ยวในต้นเงินดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙/๒๕๔๗)

จากคำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลา ที่กำหนดในสัญญา ทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิปรับในขณะที่รับมอบงานงวดสุดท้าย ไว้แล้วตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ว่าจ้างจึงสามารถหักค่าจ้าง ที่ต้องชำระไว้เป็นค่าปรับได้ อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ศาลวินิจฉัยว่า ผู้ว่าจ้างมีส่วนต้องรับผิดชอบ ในความล่าช้าในการส่งมอบงานของผู้รับจ้างและต้องปรับลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างบางส่วน เนื่องจากผู้ว่าจ้างได้สั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการก่อสร้างโดยที่ยังไม่มี การแก้ไขสัญญา ต่อมาเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้วจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อให้สอดคล้อง กับงานที่ผู้รับจ้างได้ทำไปจริง ทำให้ไม่สามารถถือเอาวันสิ้นสุดสัญญาตามกำหนดเดิมเป็นวันสิ้นสุด สัญญาได้อีกต่อไป ดังนั้น ในระหว่างวันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมจนถึงวันที่ลงนาม ในสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างยังสามารถส่งมอบงานได้โดยไม่ผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจปรับผู้รับจ้างกรณีส่งมอบงานล่าช้าโดยรวมเอาระยะเวลาดังกล่าวไว้ในการคำนวณ ค่าปรับ

๒. กรณีที่ความล่าช้าในการส่งมอบงานเกิดจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย แต่มีเหตุส่วนหนึ่งอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีอุปสรรคต่อการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงต้องลดค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งมอบงานล่าช้าให้แก่ผู้รับจ้างตามสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๘๗ บ่อและก่อสร้างทางเท้าพร้อมคันดิน ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลชีพพลาย (ผู้รับจ้าง) กับเทศบาลตำบลวังสะพุง (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและทางเท้าโดยกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างก่อนการยื่นซองประกวดราคา แต่ไม่มีผู้ใดเดินทางไปดูสถานที่ก่อสร้าง ต่อมาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไปได้ระยะหนึ่งก็ต้องหยุดงานเนื่องจากติดแนวเสาไฟฟ้าและท่อประปา ผู้รับจ้างจึงแจ้งให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าและท่อประปาออกไป โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ผู้รับจ้างได้แจ้งขอหยุดงาน ต่อมาเมื่อมีการย้ายเสาไฟฟ้าแล้ว ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือแจ้งขอกลับเข้าทำงานต่อไปพร้อมทั้งขอขยายอายุสัญญาโดยอ้างเหตุเกี่ยวกับอุปสรรคจากแนวเสาไฟฟ้าและจากกรณีที่มีฝนตกหนักเนื่องจากมีพายุโซนร้อนพัดผ่าน แต่ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาต ต่อมา เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานพร้อมแจ้งสงวนสิทธิปรับและได้หักค่าจ้างบางส่วนเป็นค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า แต่ผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยกับการหักค่าปรับดังกล่าว เพราะเห็นว่าการส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุสุดวิสัยและการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีอุปสรรค จึงได้ฟ้องขอให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาพร้อมคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ว่าจ้างได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและทางเท้าโดยให้ผู้เข้าประกวดราคาไปดูสถานที่ก่อสร้าง หากผู้ใดไม่ไปดูถือว่าทราบปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงแล้ว หากเกิดปัญหาใดๆจะยกมาอ้างไม่ได้ แต่ผู้รับจ้างมิได้ไปดูสถานที่ เมื่อผู้รับจ้างเข้าทำงานได้พบอุปสรรคในพื้นที่เนื่องจากมีแนวเสาไฟฟ้าตั้งอยู่จึงต้องหยุดงานชั่วคราว และต่อมายังมีฝนตกหนักเนื่องจากมีพายุโซนร้อนพัดผ่านทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าจึงเป็นความผิดของผู้รับจ้างส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อน แต่โดยที่ผู้ว่าจ้างเองก็คาดหมายได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคและย่อมทราบดีตั้งแต่กำหนดแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างแล้วโดยปัญหาดังกล่าวผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นความบกพร่องของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างควรต้องรับผิดชอบ ก็คือ ระยะเวลาระหว่างวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอหยุดงานชั่วคราว จนถึงวันที่ได้มีการย้ายเสาไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาขอหยุดงานดังกล่าวเป็นการ

ใช้สิทธิตามข้อสัญญา เมื่อระยะเวลาที่ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาเกิดจากความบกพร่องในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและเป็นเหตุที่ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังตนเอง จึงถือได้ว่าเป็นเหตุจากความบกพร่องของผู้ว่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องพิจารณาขยายระยะเวลาปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้างและต้องงดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับคู่สัญญาต่างยอมรับตรงกันว่าแนวเสาไฟฟ้ากีดขวางแนวการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดังนั้น ช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างขอหยุดปฏิบัติงานจึงมิได้เกิดจากความบกพร่องของ ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงต้องหักจำนวนวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกจากจำนวนวันทั้งหมดที่ ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าและต้องคืนค่าปรับในส่วนที่หักไว้คืนให้แก่ผู้รับจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐/๒๕๔๗)

หมายเหตุ คดีนี้ผู้รับจ้างไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นที่ว่าในระหว่างก่อสร้างมีเหตุสุดวิสัยเนื่องจากฝนตกหนักเพราะมีพายุโซนร้อนพัดผ่าน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ จึงไม่ปรากฏประเด็นดังกล่าวในคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด แต่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไว้ด้วยว่า พายุโซนร้อนเป็นเหตุให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันมากกว่าปกติทำให้เกิดอุทกภัยได้ ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีจึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดผลพิบัติที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคล ในภาวะเช่นนั้น เพราะผู้รับจ้างไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดพายุโซนร้อนที่รุนแรงขนาดนั้น จึงถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างสามารถขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปได้ด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเหตุและพฤติการณ์ให้ ผู้ว่าจ้างทราบพร้อมขอขยายระยะเวลาทำงานเกินกว่า ๑๕ วันนับจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงและเหตุสุดวิสัยดังกล่าวมิใช่เหตุที่ผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ดังนั้น จึงถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นการที่ผู้ว่าจ้างไม่ขยายเวลาทำงานในช่วงดังกล่าวจึงชอบแล้ว

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุมชนบ้านบึงไสลจำนวน ๑๒ โครงการ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย (ผู้รับจ้าง) กับเทศบาลตำบลวังสะพุง (ผู้ว่าจ้าง) ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถเริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างได้เพราะมีท่อเมนประปาและท่อจ่ายน้ำประปาอยู่ในแนวเขตก่อสร้างโดยตลอด ผู้รับจ้างจึงได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการย้ายท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างและขอต่ออายุสัญญา ซึ่งในระหว่างรอการดำเนินการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างได้ระงับการก่อสร้างโดยผู้ว่าจ้างมิได้ขยายระยะเวลาให้ ทำให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ต่อมาในการตรวจรับงานผู้ว่าจ้างได้ส่งวนสิทธิปรับผู้รับจ้างกรณีส่งมอบงานล่าช้านับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานโดยได้หักค่าจ้างบางส่วนเป็นค่าปรับ ผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยกับการหักค่าปรับดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าสาเหตุในการส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง จึงฟ้องขอให้ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาพร้อมคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างได้เนื่องจากมีท่อเมนประปา วางอยู่ตลอดแนวก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการแก้ไข และขอขยาย ระยะเวลาออกไป กรณีจึงถือได้ว่าผู้รับจ้างได้แจ้งเหตุขัดข้องและขอขยายระยะเวลาตาม ข้อ ๑๓๒^{๒๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าจ้างใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดัง กล่าวนานถึง ๒๘ วัน กรณีจึงถือเป็นความล่าช้าอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้ว่าจ้างที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ แม้ในสัญญาจ้างจะไม่ได้กำหนดเรื่องการส่ง มอบพื้นที่ก่อสร้างไว้ แต่ผู้ว่าจ้างในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ จัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมส่งมอบเพื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตามสัญญา ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงต้องขยาย ระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างและต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนวันที่ความล่าช้าในการส่ง มอบงานเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๗/๒๕๔๘)

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ระหว่าง บริษัทสามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด (ผู้รับจ้าง) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ผู้ว่าจ้าง) โดยในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายการผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาคัดเลือก แต่ด้วยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและประธานคณะ กรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างหลายครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่องในการตรวจการจ้างและ การเลือกผลิตภัณฑ์ในส่วนของลิฟท์โดยสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ ในการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียและถังน้ำใต้ดิน ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจัดหาสถานที่ ทั้ง ดินที่เพียงพอรองรับปริมาณดินทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอมที่จะจัดหาให้ได้ จึง ต้องใช้เวลาในการจัดหาเพิ่มเติม ส่วนการทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารในงวดที่ ๑๗ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างประสบปัญหาในการก่อสร้างเนื่องจากมีบางส่วนของตัวอาคารล่า

^{๒๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการ สั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี ตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

เข้ามาในบริเวณก่อสร้าง แต่ผู้ว่าจ้างไม่รู้ถือนอาคารดังกล่าวตามที่ผู้รับจ้างเรียกร้องเพราะเห็นว่าบริเวณที่ก่อสร้างมีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเดินรถและพื้นที่จอดรถแล้ว ต่อมาเมื่อมีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานพร้อมแจ้งสงวนสิทธิปรับและได้หักค่าจ้างบางส่วนเป็นค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า แต่ผู้รับจ้างไม่เห็นด้วยกับการหักค่าปรับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าสาเหตุในการส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความล่าช้าในการจัดหาสถานที่ที่ดินและการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีปัญหาของผู้ว่าจ้าง จึงได้ฟ้องขอให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาพร้อมคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี โดยจะต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้างเลือกกว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด อาทิ ผลิตภัณฑ์ลิฟท์โดยสาร ซึ่งแม้ผู้ว่าจ้างจะใช้เวลาในการคัดเลือกค่อนข้างนาน แต่ก็มีได้กระทบต่อวงงาน เนื่องจากการติดตั้งลิฟท์เป็นงานที่ต้องดำเนินการในงานงวดที่ ๑๓ และผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบผลการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ลิฟท์โดยสารดังกล่าวก่อนวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ประมาณหกเดือนเศษ จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างสามารถส่งนำเข้าลิฟท์โดยสารจากต่างประเทศได้โดยไม่ทำให้งาน งวดที่ ๑๓ ล่าช้าแต่ประการใด ส่วนการเลือกวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานวางท่อ ร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินการในงานงวดที่ ๑๓ ผู้ว่าจ้างใช้เวลาเลือกนาน ๖ เดือน และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบผลการเลือกผลิตภัณฑ์ประมาณสองเดือนเศษก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ จึงมิได้เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างดำเนินการในงานงวดที่ ๑๓ ล่าช้าแต่ประการใด ผู้ว่าจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการส่งมอบงานล่าช้าของผู้รับจ้าง ส่วนความล่าช้าในการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียและถังน้ำใต้ดิน เนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่สามารถจัดหาสถานที่ที่ดินให้แก่ผู้รับจ้างได้อย่างเพียงพอ ทำให้ต้องจัดหาสถานที่ที่ดินเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ผู้ว่าจ้างจึงต้องขยายระยะเวลาในการทำงานดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง สำหรับในส่วนของการก่อสร้างถนนและที่จอดรถหน้าอาคารที่ก่อสร้างซึ่งเป็นงานงวดสุดท้ายนั้น ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างแล้วแต่ต้องประสบอุปสรรคเนื่องจากตัวอาคารบางส่วนล้ำเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่ยินยอมรื้อถอนอาคารดังกล่าวตามที่ผู้รับจ้างเสนอเพราะเห็นว่าพื้นที่ก่อสร้างและที่จอดรถในบริเวณดังกล่าวมีเนื้อที่เพียงพอใช้งาน จึงได้รับมอบงานในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างไปแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าของงานที่ส่งมอบนับตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบปัญหาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ดังนั้น เมื่อรวมระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะต้องขยายให้แก่ผู้รับจ้างยาวกว่าระยะเวลาที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ผู้ว่าจ้างจึงต้องคืนค่าปรับตามจำนวนวันที่ต้องขยายเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๗/๒๕๔๘)

- ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพี่น้องธุรกิจ (ผู้รับจ้าง) กับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (ผู้ว่าจ้าง) ผู้รับจ้างประสบปัญหาในการลำเลียงเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นไปยังเนินเขาซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากเส้นทางในการลำเลียงกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับเอกชนราย

อื่น ประกอบกับงานวางท่อประปาในบางจุดยังไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางทำให้ต้องระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาแล้วแต่ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาต ต่อมาผู้ว่าจ้างได้ปรับผู้รับจ้างเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา แต่ผู้รับจ้างเห็นว่าความล่าช้าในการส่งมอบงานอันเนื่องมาจากสาเหตุทั้งสองประการข้างต้นไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง จึงฟ้องขอให้ผู้ว่าจ้างคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับอุปสรรคจากการก่อสร้างถนนนั้น ตามข้อสัญญากำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้รับจ้างสามารถใช้สิทธิขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปได้ โดยต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปภายในสิบห้าวันนับถัดจากวันที่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความดังกล่าว ให้ถือว่า ผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการขยายระยะเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้การลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาการทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างก่อนตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสภาตำบล (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายในสิบห้าวันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลด หรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้รับจ้างได้ยื่นขอขยายระยะเวลาทำงานต่อผู้ว่าจ้างเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับถัดจากวันที่เหตุขัดข้องสิ้นสุดลงตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างประกอบข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งได้แก่วันที่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนระหว่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลกับผู้รับจ้างรายอื่นสิ้นสุดลง ประกอบกับในหนังสือยื่นขอขยายระยะเวลามีได้ระบุเหตุขัดข้องในกรณีข้างต้นไว้ จึงถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา นอกจากนั้น ยังปรากฏว่าเส้นทางลำเลียงเครื่องมือและอุปกรณ์มิได้มีเพียงเส้นทางที่กำลังก่อสร้างเท่านั้น กรณีจึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างที่จะต้องขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไป เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่มีสิทธิยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาขอลดค่าปรับได้ ส่วนกรณีที่อุปสรรคในการก่อสร้างตามสัญญาเกิดจากการที่งานวางท่อประปาต้องถูกระงับชั่วคราว

เพราะยังมิได้รับอนุญาตจากแขวงทางนั้น เป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ที่มีอุปสรรคและรบกวนสิทธิให้ผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาและเป็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้น เพราะสภาพแห่งงานที่จ้างซึ่งผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นตามข้อสัญญาประกอบข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ การที่ผู้ว่าจ้างมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาทำงานให้แก่ผู้รับจ้างอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการก่อสร้างในส่วนนี้ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้สิทธิปรับผู้รับจ้างโดยลดค่าปรับลงเพราะเหตุขัดข้องอันเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง การปรับผู้รับจ้างเต็มจำนวนจึงไม่ชอบ ศาลพิพากษาให้ ผู้ว่าจ้างคืนค่าปรับบางส่วนตามจำนวนวันที่การก่อสร้างถูกระงับชั่วคราวข้างต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑/๒๕๕๙)

จากคำวินิจฉัยทั้งสี่คดีดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต่างต้องรับผิดชอบร่วมกันในการที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยในส่วนของผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความล่าช้าในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง แต่ไม่ต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนหากพึงได้ว่าความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่บกพร่องอันเป็นการไม่ทำหน้าที่ในฐานะผู้ว่าจ้างให้ถูกต้อง จึงต้องปรับลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากจำนวนวันที่ผู้รับจ้างควรได้รับสิทธิขยายเวลาในการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาหรือข้อกฎหมาย แต่ผู้ว่าจ้างกลับไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทำงาน โดยเฉพาะในกรณีที่การขอขยายเวลานั้นเกิดจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างซึ่งศาลถือว่าเป็นความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง โดยมีพฤติการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ได้แก่

(ก) การมีแนวเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างคาดหมายได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรค และทราบดีตั้งแต่ในชั้นการกำหนดแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างแล้ว อันเป็นปัญหาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้เอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๐/๒๕๕๗)

(ข) การที่ผู้รับจ้างได้แจ้งเหตุขัดข้องในการก่อสร้างและขอขยายระยะเวลาตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อสัญญาแล้ว แต่ผู้ว่าจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้า ผู้ว่าจ้างจึงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือบกพร่องของตนที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมส่งมอบเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถทำการก่อสร้างตามสัญญา แม้ว่าในสัญญาจ้างจะไม่ได้กำหนดเรื่องการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไว้ก็ตาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๕๘)

(ค) การที่ผู้ว่าจ้างจัดหาที่ที่ดินที่เกิดจากการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหาสถานที่ที่ดินเพิ่ม เป็นเหตุให้การทำงานล่าช้า และการประสบอุปสรรคในการก่อสร้าง

เนื่องจากตัวอาคารบางส่วนล้ำเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง แต่ผู้ว่าจ้างไม่ยินยอมรื้อถอนอาคารดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๙/๒๕๕๘)

(ง) การที่การดำเนินการในพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างตามสัญญายังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ยังไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงในการที่จะดำเนินการวางท่อประปาตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นความบกพร่องเพราะสภาพแห่งงานที่จ้างซึ่งผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๑/๒๕๕๙)

บทที่ ๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ในฐานะผู้ว่าจ้างและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลเอกชนในฐานะผู้รับจ้าง จัดเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจึงอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องกำหนดคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชดใช้เงิน ให้ส่งมอบทรัพย์สิน ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

แม้คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจัดเป็นสัญญาทางปกครอง มิใช่สัญญาทางแพ่ง แต่กระนั้น ในชั้นการพิจารณาคดี นอกจากศาลปกครองจะนำข้อสัญญาและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ประกอบการพิจารณาคดีแล้วยังนำหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วย เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ศาลปกครองสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีได้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การนำหลักกฎหมายแพ่งมาบังคับใช้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างมิใช่เรื่องใหม่แต่ประการใด เพราะก่อนหน้านี้จะมีการจัดตั้งศาลปกครองคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของทางราชการได้เคยอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมมาก่อน และศาลยุติธรรมก็ได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้แก่คดีควบคู่กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ รวมทั้งข้อกำหนดตามระเบียบดังกล่าว ก็พบว่ามี การนำหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับทั้งในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา และความรับผิดตามสัญญา ดังเช่น หลักในการเรียกค่าปรับและการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับ การบอกเลิกสัญญาและผลภายหลังการบอกเลิกสัญญา การรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา การเรียกค่าเสียหาย ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานที่ส่งมอบ เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คดีประเภทนี้ได้ถูกพิจารณาว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเหนือคดีพิพาทจากเดิมซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมมาอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการพิจารณาคดีพิพาทประเภทสัญญาจ้างก่อสร้างของทางราชการอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างใด เนื่อง

จากศาลปกครองยังคงนำหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาอนุโลมใช้วินิจฉัยคดีควบคู่กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยเช่นกัน

ลักษณะการนำหลักกฎหมายแพ่งมาใช้วินิจฉัยคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองดังที่ได้กล่าวข้างต้น มิได้มีปรากฏเพียงในระบบกฎหมายไทยเท่านั้น หากแต่ยังมีปรากฏในระบบกฎหมายและระบบศาลของประเทศที่ถือว่าเป็นต้นแบบด้านกฎหมายปกครองดังเช่นเยอรมนี มาเป็นเวลานานแล้ว โดยในการพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของเยอรมนีจะมีการนำหลักกฎหมายแพ่งมาใช้ในฐานะที่เป็นบทเสริมกฎหมายปกครอง เนื่องจากเยอรมนีมีกฎหมายปกครองที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองค่อนข้างน้อยหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของบทบัญญัติเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง แต่กระนั้น ทั้งไทยและเยอรมนีก็ยังคงมีความแตกต่างกันในแง่ของการแบ่งเขตอำนาจศาลเหนือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ ในส่วนของระบบกฎหมายไทยกำหนดให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งรวมถึงสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การเลิกสัญญา หรือการเรียกค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญาทางปกครอง เป็นต้น ล้วนอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเพียงศาลเดียวเช่นเดียวกับฝรั่งเศส ดังนั้น ทั้งศาลปกครองของไทยและฝรั่งเศสจึงต่างมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ในขณะที่ระบบกฎหมายของเยอรมนีจะมีการแบ่งประเภทของข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (สัญญาตามกฎหมายมหาชน) ออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรก ซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อสัญญา เช่น การตีความ การปฏิบัติตามสัญญา การปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญา และการเลิกสัญญา เป็นต้น จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง แต่ข้อพิพาทส่วนที่สอง ซึ่งเกี่ยวกับการเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการผิดสัญญาหรือเนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขข้อสัญญาและการเลิกสัญญาจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตาม รูปแบบของระบบศาลและระบบกฎหมายปกครองของเยอรมนีซึ่งมีพัฒนาการมายาวนานแล้วอาจมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองสภาพความเป็นนิติรัฐของเยอรมนีได้อย่างดี แต่การจะนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับสภาพสังคมอื่นก็จะต้องคำนึงด้วยว่าระหว่างภาระกับประโยชน์ที่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายจะได้รับอย่างใดจะมีมากกว่ากัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาพิพาทประสงค์จะฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติตามสัญญา หรือการเลิกสัญญา พร้อมกับฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยควบคู่กัน ก็จะต้องนำคดีพิพาทไปฟ้องยังศาลถึงสองแห่ง ทำให้คดีพิพาทไม่สามารถยุติที่ศาลแห่งใดเพียงแห่งเดียว ผลที่ตามมาก็คือ ผู้เสียหายจะไม่ได้ได้รับความสะดวกและอาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายตามมา

จากการศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของ ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญานั้น ปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่จะมีความสอดคล้อง

คล้องกับแนวการวินิจฉัยของศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด (ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ) ซึ่งมีมาก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ทั้งนี้ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่มีการนำมาฟ้องต่อศาลปกครองส่วนใหญ่จะเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีต่างๆ ดังนี้ ๑) การไม่ชำระค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุสุดวิสัยและผู้ว่าจ้างมีการแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับก่อนการบอกเลิกสัญญา ๒) การไม่ชำระค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากพฤติการณ์ต่างๆ ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ เช่น ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับก่อนบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างไม่เข้าเริ่มงานตามสัญญาจนสัญญาสิ้นสุดลงทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้รับจ้างรายอื่นในราคาที่สูงขึ้น ผู้รับจ้างไม่เข้าแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องให้เรียบร้อยและถูกต้องตามแบบรูปและรายการในข้อกำหนดตามสัญญา เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายในการใช้สิทธิเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและปกป้องประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนี้ จากการศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองและศาลยุติธรรม รวมทั้งความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้วินิจฉัยหรือให้ความเห็นไว้ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ พบว่า มีการวางหลักเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่สำคัญๆ ได้แก่ การเรียกค่าปรับ การรับหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา การเรียกค่าเสียหายในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีที่มีค่าจ้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนผู้รับจ้างรายเดิม และกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่อง เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ว่าจ้างควรให้ความสำคัญดังนี้

ประการแรก การใช้สิทธิเรียกค่าปรับ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองกรณี คือ กรณีแรก การใช้สิทธิเรียกค่าปรับเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าโดยที่ไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ เมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้าจนล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้างต้องใช้สิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันไว้ก่อนในระหว่างที่มีการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับเมื่อมีการส่งมอบงาน ผู้ว่าจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าปรับเป็นรายวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบงาน ส่วนกรณีที่สอง เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าจนล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาแล้ว และต่อมาเมื่อเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ ผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญา ซึ่งกรณีนี้ ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกค่าปรับได้ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งสงวนสิทธิปรับไว้ก่อนบอกเลิกสัญญา จึงจะมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับในช่วงเวลาดังที่กล่าวมาได้

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกค่าปรับได้เมื่อผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดจนกระทั่งล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญา เช่น กรณีตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ ๑๒๓๐/๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าทำงาน ผู้ว่าจ้างจึงได้แจ้งสงวนสิทธิในการรับหลักประกันสัญญา เรียกค่าปรับและค่าเสียหายต่างๆ และได้บอกเลิกสัญญาในเวลาต่อมา ซึ่งในกรณีนี้เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งสงวนสิทธิปรับไว้แล้ว จึงย่อมมีสิทธิได้รับค่าปรับจากผู้รับจ้างนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าทำงานเลยนับแต่วันทำสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญานั้น สำนักงานอัยการสูงสุด (กรมอัยการเดิม) ได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ใช่เรื่องทำการก่อสร้างล่าช้า จึงไม่มีช่วงเวลาที่ให้นำมาคำนวณค่าปรับได้ ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิปรับตามสัญญา แต่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย (การตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุดเลขรับที่ ท.๕๒/๒๕๒๕ โดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๘๕/๒๕๑๗)

ทั้งนี้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกค่าปรับภายหลังการบอกเลิกสัญญานี้ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยไว้ในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๔๘ (ประชุมใหญ่) ว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^{๒๑๒} กล่าวคือ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนที่จะมีการทำสัญญากัน แต่การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายของ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย ดังนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วย่อมไม่มีสิทธิตามสัญญาที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระเบี้ยปรับตามสัญญาได้อีก แต่ยังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ ฉะนั้น การฟ้องเรียกค่าปรับในคดีนี้จึงเป็นกรณีที่ถือว่าผู้ว่าจ้างประสงค์จะเรียกร้องเอาเบี้ยปรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งค่าเสียหายซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่^{๒๑๓} ประกอบกับมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง^{๒๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๒๑๒-๒๑๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้พิสูจน์ได้

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

ฯลฯ

ฯลฯ

การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

ประการที่สอง การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าไปแล้วเสร็จตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาย่อมมีผลทำให้สัญญาที่เคยมีอยู่สิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกค่าเสียหายต่างๆ อันเนื่องจากการเลิกสัญญาและรับหลักประกันสัญญาได้ แต่มีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจว่า ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาได้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาไม่ยอมชำระหนี้เท่านั้นหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาโดยที่ผู้รับจ้างมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาได้หรือไม่ กรณีหนึ่ง กับอีกกรณีหนึ่ง คือ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนล่วงเลยกำหนดสัญญาเท่านั้นหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาก่อนที่สัญญาจ้างจะครบกำหนดได้หรือไม่

เกี่ยวกับปัญหาในทั้งสองกรณีข้างต้นนั้น อาจกล่าวได้ว่า ในกรณีแรก ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทำผิดสัญญาเกิดขึ้นก่อนก็ได้ เพราะผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากไม่ประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำงานที่ล่าช้าอีกต่อไป แม้ผู้รับจ้างจะมีได้ผิดสัญญาก็ตาม เช่น งานที่ล่าช้านั้นหมดประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ที่จะต้องดำเนินการตามสัญญาจ้างอีกต่อไป โดยอาจเป็นผลมาจากการที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอย่างเช่น ในกรณีที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ผู้ว่าจ้างมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างยุติการก่อสร้างงานโยธาโครงการเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำคลองกะวัตทองใหญ่ไว้ชั่วคราว เนื่องจากกรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยผู้ว่าจ้างสามารถเรียกเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบคืนจากผู้รับจ้างได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ด้วยการเลิกจ้างในกรณีนี้มีใช้ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง^{๒๔} โดยกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งที่ผู้รับจ้างไม่ได้กระทำผิดสัญญานี้ ตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองถือว่าเป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองที่จะบอกเลิกสัญญาได้เมื่อไม่ต้องการให้ผู้รับจ้างทำงานที่ล่าช้าอีกต่อไป หรือเมื่อเห็นว่างานที่จ้างไม่เอื้อต่อประโยชน์สาธารณะอีกต่อไป เพียงแต่ผลที่ตามมาภายหลังการบอกเลิกสัญญา ก็คือ คู่สัญญาฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างด้วย ส่วนในกรณีที่สอง ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาจ้างครบกำหนดได้ หากในสัญญาจ้างมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในเรื่องนี้ได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๐๘/๒๕๒๔ วินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาตามที่มีข้อสัญญาให้สิทธิเลิกจ้างได้นั้น ถือเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้างก่อนและไม่ต้องบอกให้ผู้รับจ้างแก้ไขงาน

^{๒๔} การตอบข้อหารือของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๓๖ กรณีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน หรือ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้รับจ้างกรณีผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่ได้ผิดสัญญา

ให้ถูกต้อง หรือรอให้ครบกำหนดตามสัญญาก่อนแต่ประการใด สำหรับในส่วนของสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งเป็นสัญญาสำเร็จรูป ได้มีการกำหนดไว้ในข้อ ๗ ข. ของสัญญาว่า ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา ซึ่งย่อมแสดงว่าผู้ว่าจ้างสามารถใช้เหตุที่ผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานเพื่อบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดสัญญาก่อน อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการบอกเลิกสัญญาว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะการบอกเลิกสัญญาโดยทันทีจะมีผลพวงตามมาหลายประการที่ไม่เป็นผลดีต่อทางราชการ เช่น โครงการของทางราชการจะต้องชะลอออกไปและหน่วยงานทางปกครองจะต้องจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานแทนซึ่งอาจต้องเสียค่าจ้างที่สูงขึ้น ตลอดจนต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลและเข้าสู่คดีในชั้นศาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างระหว่างคู่สัญญาฝ่ายปกครองและคู่สัญญาฝ่ายเอกชน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างควรต้องร่างข้อสัญญาให้มีความรัดกุมและละเอียดรอบคอบ รวมทั้งต้องมีการบริหารสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่สาม สิทธิของผู้ว่าจ้างในการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานให้แล้วเสร็จเมื่อมีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม โดยผู้รับจ้างรายเดิมต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ โดยค่าจ้างส่วนที่สูงขึ้นนี้ถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิได้รับการชดเชยจากผู้รับจ้างรายเดิม

ประการที่สี่ สิทธิของผู้ว่าจ้างในแก้ไขแบบรูปและรายการก่อสร้าง สิทธิในเรื่องนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายปกครองในการสั่งให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างแก้ไขแบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือสั่งให้ทำงานพิเศษเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากสัญญาจ้างได้ หากเป็นงานที่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดทำบริการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคู่สัญญาฝ่ายปกครองจะต้องชดเชยค่าจ้างให้ หากเป็นการแก้ไขที่ทำให้มีเนื้องานเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้เดิม แต่ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพื่อปรับลดเนื้องานลงจากเดิม คู่สัญญาฝ่ายปกครองมีสิทธิที่จะปรับลดค่าจ้างลงตามสัดส่วนของเนื้องานที่ลดลง

ประการที่ห้า สิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความเสียหายของงานที่ทำหรือความชำรุดบกพร่องของงานที่ส่งมอบ ในกรณีที่ความเสียหายของงานที่ก่อสร้างเกิดขึ้นในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้มีการส่งมอบงานทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วยการเข้าซ่อมแซมแก้ไขหรือดำเนินการจัดทำให้ เป็นไปตามแบบรูปและรายการที่กำหนดในสัญญา รวมทั้งต้องใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญาด้วย และหากมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากความเสียหายดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายนั่นเอง ดังนั้น ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แม้จะเกิดเพราะเหตุสุด

วิสัย นอกเหนือจากกรณีที่เกิดจากความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่ให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ส่วนในเรื่องความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วหรืออยู่ในระยะประกันผลงานนั้น ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่คู่สัญญาได้จัดทำไว้ในสัญญา ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลา ๑ หรือ ๒ ปี ก็ได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาหลายครั้งและหลายรายการแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ตรวจพบ ผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาแยกนับอายุความตามแต่ละวันที่ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น แต่ถ้าผู้ว่าจ้างละเลยมิได้สำรวจความชำรุดบกพร่องเมื่อรับมอบงาน หรือเมื่อตรวจพบความชำรุดบกพร่องแล้วมิได้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไขความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องดังกล่าว

ประการที่หก ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ในงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน รวมทั้งเครื่องมือก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้จัดหาไว้ ทั้งนี้ แม้ว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างจะมีผลให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ก็มีปัญหาว่างานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ทำไปแล้วในที่ดินของผู้ว่าจ้างไม่อาจทำให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ดังนั้น หากงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง ก็จะทำให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างได้โดยผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าแห่งการงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ถ้าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่วงหน้าไปแล้วงานก่อสร้างดังกล่าวก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทันที ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างรับเอาผลงานที่ก่อสร้างไว้แล้วเป็นเบี่ยงปรับ กรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าแห่งการงานที่ทำนั้นทั้งหมดโดยอาจจ่ายเพียงบางส่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าศาลจะมีการปรับลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่ แต่ในกรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างเพราะก่อสร้างผิดไปจากแบบรูปและรายการหรือใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับจ้าง เพราะเท่ากับว่าไม่มีงานที่คู่สัญญาต้องชดใช้คืนต่อกัน

ส่วนการเข้าใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้จัดหาไว้แล้วนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุเหล่านั้นได้หากกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุดังกล่าวเป็นของผู้รับจ้างมิใช่กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยผู้ว่าจ้างจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้น เพราะผู้ว่าจ้างเพียงแต่มีสิทธิยืมหน่วงสิ่งเหล่านั้นไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือเพื่อให้ผู้รับจ้างรายใหม่ใช้เพื่อทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ กรณีนี้มีใช้เรื่องของการใช้สิทธิยืมหน่วงตามมาตรา ๒๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะมิได้เป็นการยืมหน่วงทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อการชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าว

ตามสมควรเช่นที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะเช่นนั้น ดังนั้น หากผู้ว่าจ้างมิได้ดูแลรักษาโดยใช้ความระมัดระวังในระดับดังที่กล่าว ก็อาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และในกรณีที่เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าวัสดุดังกล่าวคืนให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาท้องตลาดในขณะที่ใช้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีข้างต้นอาจมีข้อยกเว้นในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำข้อตกลงยอมให้สิ่งก่อสร้างบางส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำแล้วและสิ่งของต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้จัดหามาเพื่อใช้ในสถานที่ก่อสร้างและเพื่องานที่จ้างโดยเฉพาะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างได้โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นการให้สัญญาว่าผู้รับจ้างจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นให้แก่ผู้ว่าจ้างที่มีใช้จำนวนเงินเพื่อเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๘๒^{๒๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลทำให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับผลงานนั้นได้โดยไม่ต้องใช้ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง

^{๒๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๘๒ ถ้าสัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นให้เป็นเบี้ยปรับไม่ใช่ใช้เป็นจำนวนเงินไซ้ร่ทำนให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๗๙ ถึง ๓๘๑ มาใช้บังคับ แต่ถ้เจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็เป็นอันขาดไป

บรรณานุกรม

หนังสือ

กองที่ปรึกษา กรมอัยการ, คำวินิจฉัยกรมอัยการ ข้อยกเว้นปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เล่มที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๕

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ รัชชน พิมพ์ครั้งที่ ๕ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม), ๒๕๔๓

จำปี โสติพันธ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน), ๒๕๔๘

ชาญชัย แสวงศักดิ์ “ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครองตามแนวคิดของฝรั่งเศส,” ในอมร จันทรสมบูรณ์, นิติกรรมทางแพ่ง-นิติกรรมทางปกครอง-สัญญาทางปกครอง, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดาราพร ธีระวัฒน์, “หลักและขอบเขตความรับผิดทางสัญญา,” อาจารย์บุชา หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน), ๒๕๓๘

นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน), ๒๕๔๖

พนม เอี่ยมประยูร, “ผลของสัญญาทางปกครอง,” รวมบทความในโอกาสเกษียณอายุราชการ ๖๐ ปีของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน), ๒๕๓๑

เพ็ญศรี วงศ์เสรี, สัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน, เอกสารประกอบการสัมมนาตุลาการศาลปกครองภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, ๒๕๔๗

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, ๒๕๔๘

วรพันธ์ เ็นทร์พิชัย, คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม ๑) ว่าด้วยเรื่องวิธีการซื้อและการจ้าง พร้อมด้วยระเบียบและหนังสือเวียนข้อความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง (กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม จำกัด), ๒๕๔๘

ศักดิ์ สอนงชาติ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา, (แก้ไขเพิ่มเติม) พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ), ๒๕๒๗

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อยกเว้นปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เล่มที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด, คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อยกเว้นปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เล่มที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔

เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม ๒
(กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ), ๒๕๐๕

บทความและเอกสารทางวิชาการ

กมลชัย รัตนสกาวงศ์, “ความพยายามในการนำแนวคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองของต่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทยในภาพรวม,” วารสารกฎหมายป
ครอง, เล่มที่ ๑๗ ตอน ๓ (ธันวาคม ๒๕๕๑), หน้า ๑๔-๓๘

คัมภีร์ แก้วเจริญ, “เบี้ยปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่
๑๒๙ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๓๑), หน้า ๘๐-๘๘

จิตติ เจริญน้ำ, “พฤติการณ์ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับ,” วารสารอัยการ,
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๔ (เมษายน ๒๕๓๗), หน้า ๙๙-๑๐๖

จิตติ เจริญน้ำ, “เบี้ยปรับกับหลักประกันสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๕
(พฤษภาคม ๒๕๓๗), หน้า ๓๐-๓๕

จิตติ เจริญน้ำ, “การเลิกสัญญาที่มีสิทธิเข้าใช้งาน,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๕
(พฤษภาคม ๒๕๓๗), หน้า ๓๑-๔๓

จิตติ เจริญน้ำ, “มีสิทธิเลิกสัญญาได้ แต่ต้องใช้ค่าเสียหาย,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๗
ฉบับที่ ๑๙๖ (มิถุนายน ๒๕๓๗), หน้า ๒๐-๒๖

จิตติ เจริญน้ำ, “ข้อตกลงที่ให้รับเอาผลงานที่ทำไปแล้วเป็นเบี้ยปรับ,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘
ฉบับที่ ๒๐๖ (เมษายน ๒๕๓๘), หน้า ๔๗-๕๒

จิตติ เจริญน้ำ, “ผลของการใช้สิทธิเลิกสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๗
(พฤษภาคม ๒๕๓๘), หน้า ๗๗-๘๕

จิตติ เจริญน้ำ, “การปรับตามสัญญา ที่มีพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ,” วารสาร
อัยการ, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๑ (กันยายน ๒๕๓๘), หน้า ๓๔-๔๒

จิตติ เจริญน้ำ, “การแจ้งสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับตามสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘
ฉบับที่ ๒๑๒ (ตุลาคม ๒๕๓๘), หน้า ๓๕-๔๓

บรรศักดิ์ อวรรณโณ, สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๕
(๒๕๒๙), หน้า ๗๓-๑๒๐

รชฏ เจริญน้ำ, “ทำงานไม่เสร็จตามสัญญา บอกเลิกสัญญาได้,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘
ฉบับที่ ๒๒๐ (มิถุนายน ๒๕๓๙), หน้า ๓๗-๔๗

รชฏ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาที่ยอมจ่ายค่าจ้างบางส่วน,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘
ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๙), หน้า ๕๑-๕๘

รชฏ เจริญน้ำ, “งานที่ได้ทำไปแล้วเมื่อเลิกสัญญา,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๑๘
ฉบับที่ ๒๒๓ (กันยายน ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๕-๑๑๕

รชฏ เจริญน้ำ, “เลิกสัญญาแล้ว ยังยึดเครื่องมือไว้ได้,” วารสารอัยการ, ปีที่ ๒๐
ฉบับที่ ๒๓๔ (สิงหาคม ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๘-๑๑๕

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, เอกสารประกอบคำบรรยายวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง, บัณฑิต
ศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กันยายน ๒๕๕๙

อื่น ๆ

เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

เรื่องเสร็จที่ ๑๓/๒๕๕๓ บันทึกของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ตามข้อหารือของสำนักนายกรัฐมนตรี นร (กวพ) ๑๓๐๕/๕๙๖๖ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑

(ก)

ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙

คดีหมายเลขแดง ที่	ผู้ฟ้องคดี	หน้า
อ.๓๒/๒๕๔๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้เอื้อะจวันตันหยงมัส	๑๑๘
อ.๑๑๙/๒๕๔๗	บริษัท เจริญทอง (๑๙๙๘) จำกัด	๑๓๕
อ.๑๗๐/๒๕๔๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย	๑๓๗, ๑๔๑
อ.๔๔/๒๕๔๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธรัักษ์ก่อสร้าง	๑๑๙
อ.๗๙/๒๕๔๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย	๑๓๘, ๑๔๑
อ.๑๗๙/๒๕๔๘	บริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด	๑๓๙, ๑๔๒
อ.๙๑/๒๕๔๙	การประปาส่วนภูมิภาค	๑๒๒
อ.๑๑๑/๒๕๔๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองพี่น้องธุรกิจ	๑๔๑, ๑๔๒

ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

คำสั่งที่	ผู้ฟ้องคดี	หน้า
๖๓๙/๒๕๔๗	กรมทรัพยากรธรณี	๑๒๖, ๑๒๗
๖๐/๒๕๔๘ (ป.)	กรมชลประทาน	๑๒๗, ๑๒๘, ๑๔๖
๑๑๕/๒๕๔๘	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๒๓, ๑๒๕
๑๙๙/๒๕๔๘	บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	๑๒๗

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองกลาง พ.ศ. ๒๕๔๙

คดีหมายเลขแดง ที่	ผู้ฟ้องคดี	หน้า
๒๔๔/๒๕๔๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที – สแควร์ ซัพพลายส์	๑๓๐
๓๕๐/๒๕๔๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญวิศวกรรม	๑๓๓
๕๐๖/๒๕๔๙	กองทัพเรือ	๑๓๑
๕๒๕/๒๕๔๙	บริษัท รัฐพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด	๑๒๑
๕๒๘/๒๕๔๙	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๒๙
๑๒๓๐/๒๕๔๙	กรมชลประทาน	๑๒๔, ๑๒๕, ๑๔๖

(๒)

ดัชนีคำพิพากษาศาลฎีกา

ฎีกาที่	โจทก์	หน้า
๔๖๒/๒๔๗๘	นายชัตตารีน เทรเลอร์ (บังคับอเมริกัน)	๗๓
๑๐๙๑/๒๔๘๒	พระยาศรีบัญชา	๗๙
๑๗๓/๒๔๘๘	นายปั่น แสงวิทย์ กับนายทรัพย์ ภาณุทัต	๗๓
๑๐๗๘/๒๔๙๖	บริษัท เอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด	๔๖, ๕๑, ๕๒
๑๓๖๔/๒๕๐๓	กรมทางหลวงแผ่นดิน	๖๘
๑๘๑๘/๒๕๑๑	กรมป่าไม้	๘๕
๗๔๕/๒๕๑๒	นายวิญญู วัฒนศิริ	๘๔
๖๔๙/๒๕๑๓	เทศบาลนครกรุงเทพ	๘๔
๙๘๒/๒๕๑๓	บริษัท กรุงธนสถาปัตย์ จำกัด	๘๔
๘๑๓/๒๕๑๔	พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต	๕๒
๑๐๔๔/๒๕๑๔	พระยาบุรณศิริพงษ์ (โดยนายเว้ง แซ่จิ้ว ผู้รับมอบอำนาจ)	๕๒
๑๘๗๓/๒๕๑๔	พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก	๕๒
๒๑๐๐/๒๕๑๔	การพลังงานแห่งชาติ	๕๒
๒๕๒๙/๒๕๑๗	กรมทางหลวง	๗๙
๒๙๘๕/๒๕๑๗	กรมทรัพยากรธรณี	๖๕, ๑๔๖
๓๐๐๕-๓๐๐๖/ ๒๕๑๗	บริษัท ประพันธ์ จำกัด	๗๗
๒๙๒/๒๕๑๘	นางศิริวัฒนา เสนาขันธ์	๘๓
๒๗๖๙/๒๕๑๙	นายรอบ การสุทธิ	๘๔
๑๗๕/๒๕๒๑	นางชะโลม เทพพิไสย กับพวก	๗๖, ๘๔
๒๒๖๙/๒๕๒๑	บริษัท โรงเลื่อยจักรลำพูน จำกัด	๘๕
๒๔๖/๒๕๒๒	นายโกศล ศิริธัญญะรัตน์	๕๒
๒๘๒๑/๒๕๒๒	บริษัท วรกิจ จำกัด	๕๕, ๘๔, ๘๕
๒๒๑๕-๒๒๑๖/ ๒๕๒๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ดีก่อสร้าง	๘๕

(ค)

ฎีกาที่	โจทก์	หน้า
๑๒๙๗/๒๕๒๓	นายมิตรา บุรพานนท์	๓๗
๒๐๑๔/๒๕๒๓	นายชีวะ นิมวารี	๙๖
๓๐๖๔/๒๕๒๓	นายสมเกียรติ ศิริโชติวณิชย์	๗๙
๔/๒๕๒๔	เรือเอกเฉลิมศักดิ์ สุขประเสริฐ	๗๓, ๙๕
๒๙๗/๒๕๒๔	นายเอี่ยมบึ้ง แซ่เฮ้ง	๙๔
๔๕๘-๔๕๙/๒๕๒๔	บริษัท ส.นิมิตรก่อสร้าง จำกัด	๙๙, ๙๕
๑๓๐๘/๒๕๒๔	บริษัท ลักษณะขนส่งและก่อสร้าง จำกัด	๖๖, ๙๕, ๑๔๗
๓๘๒๑/๒๕๒๔	นางสาวยุ่นจิ้น แซ่ไล่	๕๕
๕๗๒/๒๕๒๕	นายวิเชียร วรปิยะวัฒน์	๙๔, ๙๕
๙๔๘/๒๕๒๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์	๗๐
๒๒๑๕/๒๕๒๖	นางสำอาน นิลกำแพง	๕๓
๒๙๔๗/๒๕๒๖	นายเกียรติชัย อภิรมย์ยานนท์	๕๓
๓๓๒๒/๒๕๒๘	นายไสว อนันตเมฆ	๓๘, ๗๖
๗๕๘/๒๕๓๐	กองทัพเรือ	๖๐
๑๖๖/๒๕๓๒	มหาวิทยาลัยมหิดล	๖๑, ๙๙
๓๘๕๖/๒๕๓๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลการช่าง	๕๓
๕๒๕๗/๒๕๓๓	กรมสามัญศึกษา	๑๐๔
๔๕๘/๒๕๓๕	บริษัท นพดารา จำกัด	๕๓
๗๙๙/๒๕๓๖	สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	๔๖
๓๖๐๔/๒๕๓๖	บริษัท สหศักดิ์พาณิชย์ (๑๔๗๕) จำกัด	๕๖
๒๐๒๖/๒๕๓๗	กรมส่งเสริมสหกรณ์	๔๘, ๗๗, ๗๘, ๙๘
๒๗๙๔/๒๕๓๗	กรมส่งเสริมการเกษตร	๙๘, ๙๙
๖๑๗/๒๕๓๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหการเชียงราย	๙๘
๒๑๑๖/๒๕๓๘	มหาวิทยาลัยมหิดล	๔๖
๕๔๙๐/๒๕๓๘	กรมสามัญศึกษา	๖๔
๕๙๐๔/๒๕๓๘	กรมตำรวจ	๗๘
๖๕๔๘/๒๕๓๘	สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	๑๐๕
๓๗๐/๒๕๓๙	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสมบูรณ์	๕๗, ๙๘

(ง)

ฎีกาที่	โจทก์	หน้า
๒๘๓๑/๒๕๓๙	บริษัท ขวัญกิจไทยการก่อสร้างและการเคหะ จำกัด	๖๑
๔๓๗/๒๕๔๐	กรมชลประทาน	๗๘, ๘๒
๗๔๙๗/๒๕๔๐	กองทัพบก	๕๙, ๘๐
๗๘๐๙/๒๕๔๐	นายสมทรง ศรีเสริมวงศ์	๖๗
๗๒๒๑/๒๕๔๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนะจินดา	๘๙
๒๙๘๓/๒๕๔๑	กรมการแพทย์	๘๘
๓๑๘๐/๒๕๔๑	ธนาคารแห่งประเทศไทย กับพวก	๕๙, ๖๕, ๘๐
๖๖/๒๕๔๒	สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	๘๒
๓๓๕๒/๒๕๔๒	สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	๕๕, ๘๐
๗๘๙๓/๒๕๔๒	กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	๕๗
๒๔๓๘/๒๕๔๕	กรมสามัญศึกษา	๖๘

(จ)

ดัชนีคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด

เลขรับที่	หน่วยงานที่หารือ	หน้า
ท.๑๔๖/๒๕๑๗	เทศบาลนครกรุงเทพ – เทศบาลนครธนบุรี	๘๐
ท.๔๔/๒๕๒๐	กรมอาชีวศึกษา	๘๓
ท.๖๑/๒๕๒๐	กรมประมง	๘๑
ท.๒๑/๒๕๒๑	องค์การสะพานปลา	๕๓
ท.๗๘/๒๕๒๑	กระทรวงสาธารณสุข	๖๑
ท.๘๒/๒๕๒๒	มหาวิทยาลัยศิลปากร	๖๐, ๗๑
ท.๑๗๓/๒๕๒๒	กองทัพเรือ	๗๒
ท.๕๓/๒๕๒๓	กรมการปกครอง (เทศบาลเมืองพิจิตร)	๕๔, ๗๑
ท.๑๖๖/๒๕๒๓	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	๘๗
ท.๖๓/๒๕๒๔	กรมการปกครอง (จังหวัดอุดรธานี)	๘๗
ท.๗๑/๒๕๒๔	กรมทางหลวง	๑๐๖
ท.๑๕๖/๒๕๒๔	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	๘๒
ท.๑๗๙/๒๕๒๔	สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	๙๘
ท.๓๔/๒๕๒๕	กรมประชาสัมพันธ์	๘๒
ท.๕๒/๒๕๒๕	กรมสามัญศึกษา	๖๕, ๑๔๖
ท.๑๐๕/๒๕๒๕	กรมอาชีวศึกษา	๕๒
ท.๒๐๓/๒๕๒๕	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๙๑, ๙๒
๖๖/๒๕๒๖	กรมชลประทาน	๑๐๓
๙๐/๒๕๒๖	การสื่อสารแห่งประเทศไทย	๙๓
๙๑/๒๕๒๖	กรมประมง	๑๐๘
๙๗/๒๕๒๖	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๑๐๔
๑๒๗/๒๕๒๖	สำนักงานพลังงานแห่งชาติ	๕๙
๑๔๕/๒๕๒๖	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	๙๙
๑๖๐/๒๕๒๗	จังหวัดยโสธร	๕๔
๓๔/๒๕๒๘	สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	๑๐๐
๑๔๑/๒๕๒๘	กรมสามัญศึกษา	๑๐๐
๑๖๑/๒๕๒๘	องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย	๑๐๙

(ณ)

เลขรับที่	หน่วยงานที่หารือ	หน้า
๘๓/๒๕๒๙	กองทัพอากาศ	๑๐๑
๑๔๐/๒๕๒๙	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	๑๐๑
๕๖/๒๕๓๐	องค์การสุรา	๙๐
๑๓๕/๒๕๓๐	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	๑๐๕
๓/๒๕๓๑	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	๑๐๖
๔/๒๕๓๑	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	๖๒
๑๑๐/๒๕๓๑	กรมการบินพาณิชย์	๖๒
๑๔๘/๒๕๓๑	กรมชลประทาน	๑๐๒
๖๔/๒๕๓๒	กรมสรรพสามิต	๕๔
๘๗/๒๕๓๒	สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพช.)	๖๖
๑๗๗/๒๕๓๒	กองทัพเรือ	๙๓
๙/๒๕๓๔	สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท	๑๐๓
๘/๒๕๓๖	กองทัพเรือ	๘๗
๙๗/๒๕๓๖	กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	๗๓
๘๐/๒๕๓๗	การประปาส่วนภูมิภาค	๖๕
๔๑/๒๕๓๘	กรมเจ้าท่า	๗๔
๙๒/๒๕๓๘	กรมเจ้าท่า	๗๕
๓๕/๒๕๓๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๗๕, ๗๙
๙๕/๒๕๓๙	กองทัพเรือ โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ	๙๕

ที่ปรึกษา

นางสมฤดี ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง

คณะผู้จัดทำ

นายสมชัย จารุจินดา

พนักงานคดีปกครอง ๘

นางสาวปัทมา วชิรเมธารัตน์

พนักงานคดีปกครอง ๗

นางสาวจิตติมา แซ่หลิม

พนักงานคดีปกครอง ๔

นางสาวปารวี พิสิฐเสนากุล

พนักงานคดีปกครอง ๓

ผู้พิมพ์

นางสุกัญญา สวัสดิ์ดวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑